

الاحكام المستحدثة للشيك في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م

تمهيد

تعريف الشيك:

صدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م دون ان يتضمن تعريفا للشيك- تاركا ذلك للفقه ولذلك يمكن تعريف الشيك .

الشيك صك محرر وفقا لبيانات معينة نص عليها القانون يتضمن امرا غير معلق علي شرط من شخص يسمى الساحب الي المسحوب عليه البنك بوفاء مبلغ معين من النقود الي شخص ثالث يسمى المستفيد او لحامله بمجرد الاطلاع.

من التعريف السابق يتضح لنا وجود علاقتين سابقتين:

العلاقة الأولى ← بين (الساحب والمستفيد) وهي اساس اصدار الشيك .

العلاقة الثانية ← بين (الساحب والبنك المسحوب عليه) واساسها مقابل الوفاء او الرصيد.

الفرق بين الشيك والكمبيالة :

الشيك يجب ان يتضمن في متن الصك كلمة "شيك" وكذلك الكمبيالة يجب ان تتضمن في متن الصك كلمة "كمبيالة" كما ان الشيك لا يجوز سحبه الا علي بنك والشيك دائما مستحق الدفع لدي الاطلاع لأنه اداة وفاء فقط، وايضا يجب ان يكون للشيك مقابل وفاء مقدم او موجود وقت اصداره، كما ان الشيك لا يجوز تقديمه للمسحوب عليه للقبول حيث لا قبول في الشيك واذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع وتقديمه للمسحوب عليه البنك يعني الوفاء بقيمته.

تجارية الشيك:

الكمبيالة والسند لأمر والشيك اوراقا تجارية تخضع لأحكام القانون التجاري بحسب الشكل بصرف النظر عن صفة ذوي الشأن فيها او طبيعة العملية التي حررت من اجلها، وعلي ذلك يتبر الشيك تجاريا بحسب الشكل.

الفصل الاول : انشاء الشيك

المبحث الاول : الشروط الموضوعية

📌 يجب ان يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي:
الأهلية والرضا والمحل والسبب:

١) الأهلية:

📌 يجب ان يكون الشيك صادرا عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للالتزام، حيث يجب ان يكون بالغ **سن الرشد** او بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذونا له بالإيجار.
📌 اما التزامات ناقص الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامين احتياطيين او بأية صفة اخري فإنها تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، وقد اشارت الي ذلك المادة ٤٧٩ تجاري، ويتضمن نص المادة ٤٧٩ تجاري حكمين.

الحكم الأول:

📌 يتعلق بناقص الأهلية وهذا الحكم يحتوي علي **شقين** احدهما يتفق مع القواعد العامة والثاني يعتبر **استثناء** علي احكام قانون الصرف.

📌 **الشق الاول** ← إنه يجوز طبقا للقواعد العامة للقاصر اذا بلغ **سن الثامنة عشر** ان يزاوّل التجارة بعد الحصول علي إذن من المحكمة ويعد القاصر في هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الأذن، اما اذا خرج عن حدود هذا الأذن او لم يحصل علي اذن مطلقا فإنه يأخذ حكم القاصر غير المأذون له بمباشرة التجارة ويأخذ حكم ناقص الأهلية الذين ليسوا تجارا حيث يكون التصرف **باطلا بالنسبة لهم** ويندرج تحت ذلك ايضا السفه وذو الغفلة.

📌 **الشق الثاني** ← فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن **استثناء** علي احكام قانون الصرف حيث ان الأصل ان تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تطهير الورقة من جميع اسباب البطلان (**كالغلط والإكراه والتدليس وانعدام السبب او عدم مشروعيته**) وغيرها من الأسباب- وذلك حماية للحامل حسن النية الذي لم يقصد وقت حصوله علي الورقة التجارية الإضرار بالمدين، ولكن المشرع خرج علي هذا حماية لناقص الأهلية واجاز له التمسك بالبطلان حتي في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث انه اولي بالرعاية من الحامل حسن النية.

الحكم الثاني:

📌 يتعلق بعديم الأهلية وهذا الحكم يعتبر **استثناء** علي القواعد العامة وايضا علي احكام قانون الصرف.
📌 فمن المعلوم ان تصرفات عديم الأهلية وفقا للقواعد العامة تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويستطيع ان يتمسك بهذا البطلان جميع اطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة .

📌 **ولكن جاء نص المادة ٤٧٩ تجاري وخرج علي هذه القواعد العامة.**

📌 **حيث ساوا المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية، وقرر بأن توقيع عديم الأهلية علي الشيك يكون قابلا للبطلان بالنسبة له فقط، فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوي المصلحة، او اطراف العلاقة القانونية .**

📌 **ولكننا نري ان المشرع قصد من هذا الحكم قصر طلب البطلان فقط علي عديم الأهلية دون باقي الموقعين علي الشيك، مع بقاء القاعدة العامة بالنسبة لعديم الأهلية، حيث يجوز لكل ذي مصلحة من خارج التصرف القانوني اي من خارج الموقعين علي الشيك التمسك ببطلان التزام عديم الأهلية كما يجوز للمحكمة التمسك ببطلان التزامه من تلقاء نفسها.**

🌟 وايضا اجازت المادة ٤٧٩ تجاري استثناء من احكام قانون الصرف

🌟 **لعدم الأهلية التمسك بالبطلان في مواجهة حامل حسن النية خروجاً علي قاعدة التطهير يظهر الورقة من الدفع.**

🌟 **والجدير بالذكر** ان بطلان الالتزام بالنسبة لناقصي الأهلية الذي ليسو تجارا وعديمي الأهلية لا يمتد الي بقية التوقيعات الثابتة علي الشيك- تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .

🌟 ويستطيع ناقصي الأهلية الذي ليس تاجرا وعديم الأهلية التمسك بهذا البطلان عن طريق رفع دعوي اصلية او بمقتضي دفع عند مطالبته بقيمة الورقة التجارية.

اهلية الأجنبي في التوقيع علي الشيك والالتزام به:

🌟 نصت المادة ٣٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م علي ان يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الي قانون الدولة الذي ينتمي اليها بجنسيته، واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقي صحيحاً اذا وضع توقيعه علي الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية وهذه المادة تنطبق علي الشيك، لان المشرع في المادة ٤٧٢ تجاري نص علي انه في المسائل لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري علي الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته.

🌟 معني ذلك انه اذا كان هناك شخصا اجنبيا سوف يلتزم بموجب شيك فإن قانون دولته هو الذي يحدد اهليته في ذلك واذا كان قانون دولته لا يعتبره كامل الأهلية مثلاً الا في سن ٢٣ سنة ووضع توقيعه علي الشيك في سن ٢١ سنة في دولة مثل مصر يعتبره قانونها كامل الأهلية، لأنها تعتبر الشخص كامل الأهلية في سن ٢١ سنة فإن التزامه يبقي صحيحاً.

(٢) الرضا:

🌟 يجب ان يكون اصدار الشيك وتسليمه الي المستفيد معبرا عن ارادة حقيقية للساحب خالية من العيوب، فإذا شاب رضاء الساحب للشيك عيب من عيوب الإرادة **كالغلط او الإكراه او التدليس** فإنه يجوز للساحب ان يدفع ببطلان التزامه في علاقته بدائنة المباشرة وفي علاقته بالحامل الاخير اذا كان سيء النية قاصدا الإضرار بالساحب اما اذا كان الحامل حسن النية لم يقصد هذا الإضرار فإنه لا يجوز للساحب الدفع بالبطلان وهذا يعتبر من تطبيقات قاعدة تطهير الدفع.

(٣) المحل:

🌟 محل الشيك يجب ان يكون دائماً مبلغاً من النقود، حيث يجب ان يشتمل الشيك علي امر غير معلق شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وطالما ان محل الشيك مبلغاً من النقود فإنه دائماً يكون مشروعاً وموجوداً ويمكن تنفيذه.

(٤) السبب

🌟 والسبب هو اساس التزام الساحب في الشيك ، ووفقاً للقواعد العامة يجب ان يكون هذا السبب **مشروعاً وموجوداً** والا كان الالتزام باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب ، **غير ان هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر**، اي انه اذا طالب المستفيد المحرر بالوفاء استطاع هذا الاخير ان يتمسك في مواجهته بالبطلان، واذا تداول الشيك واستقر في يد حامل سيئ النية اي يعلم بعدم وجود السبب او عدم مشروعيته وكان قاصدا الإضرار بالساحب ، استطاع هذا الأخير التمسك في مواجهة الحامل سيئ النية بالبطلان، اما اذا كان الحامل حسن النية لم يقصد الإضرار بالساحب فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان تطبيقاً لقاعدة تطهير الدفع اما اذا كانت الدعوي جنائية فإن المسؤولية الجنائية لا تتأثر بالسبب او الباعث الذي اعطي من اجله الشيك، لان القانون يحمي الشيك باعتباره اداة وفاء كالنقود.

- يجب ان يكون الشيك مكتوبا مثله في ذلك مثل باقي الأوراق التجارية، ويجب ان يتضمن الشيك الكفاية الذاتية بألا يحيل الي وقائع خارجية او اتفاقات تحدد مضمونه.
- وشروط الكتابة يفهم من تطلب المشرع وجوب ان يشتمل الشيك علي بيانات محددة تكتب بصلب الشيك .
- هذا وقد تطلب المشرع ان تكون الكتابة علي نماذج مطبوعة للبنك المسحوب عليه لذلك فإنه منذ تاريخ العم بأحكام التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بالنسبة للشيك وهو اول اكتوبر سنة ٢٠٠٥، لا يجوز ان يصدر الشيك الا علي نماذج شيكات البنك المسحوب عليه والا خرج من عداد الأوراق التجارية .
- لذلك ألزم المشرع البنوك عند موافقتها منح دفاتر شيكات لعملائها ان يكتب علي كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه .

ب) البيانات الإلزامية وجزاء خلفها:

نصت المادة ٤٧٣ من قانون التجارة علي انه: " يجب ان يشتمل الشيك علي البيانات الآتية:

١- ذكر كلمة " شيك" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها:

- استحدث المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م هذا البيان، حيث يجب كتابة كلمة " شيك" في متن الصك حتي يتم تميزه عن غيره من الأوراق التجارية الأخرى، خاصة ان المشرع فتح المجال لاستحداث اوراق تجارية جديدة، كما ان الهدف من ذلك هو تعيين ما هيه الصك صراحة ولفت نظر الموقعين عليه علي طبيعته ومدي الالتزام الذي نشأ عن توقيعهم.

ذهب البعض إلى انه يجب ذكر كلمة " شيك" في متن الصك ذاته فلا تكفي كتابتها في اعلي الورقة كعنوان لها ولا في نهايتها وانما ينبغي اثباتها في عبارة الأمر.

بينما ذهب البعض الآخر إلى انه لا يجب الإغراق في الشكلية ما دامت كلمة شيك تضمنها الصك بوضوح ونحن نؤيد هذا الرأي الأخير.

- ويجب ان تكتب عبارة " شيك" باللغة الصادر بها الشيك.
- ولا يشترط كتابة الشيك باللغة العربية فيجوز كتابته بلغة اجنبية.
- والصك الخالي من عبارة " شيك" مكتوبة في متن الصك لا يعتبر شيكا ولا يخضع لأحكام قانون التجارة وانما يخضع للقواعد العامة حيث يمكن اعتباره اقرار بالدين.

٢- امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام:

- يجب ان يشتمل الشيك علي امر موجه من الساحب الي البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب الا يكون هذا الأمر معلقا علي شرط سواء كان شرطا فاسخا او واقفا، حتي لا يعوق تداول الشيك ويفقده شرط الكفاية الذاتية.
- ويجب الا يتعلق تحديد المبلغ علي اوراق خارجية أو وقائع خارجية حتي لا يفقده شرط الكفاية الذاتية.
- ويجب ان يكون موضوع الشيك الالتزام بدفع مبلغ من النقود، فلا يجوز ان يكون موضوعه تسلم شئ او بضاعة او الالتزام بأداة عمل، واذا اشتمل الشيك علي ذلك فإنه يخرج من عداد الاوراق التجارية.
- ويجب ان يكون مبلغ الشيك محدد بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيه ، لذلك ابطال المشرع شرط العائد في الشيك، واذا اشتمل الشيك علي شرط العائد فإنه يعتبر كأن لم يكن، والسبب في بطلان هذا الشرط هو ان الشيك يعتبر اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع وازافة هذا الشرط يجعل مبلغ الشيك محلا للشك وغير واضح وغير معين تعينا دقيقا عند سحب الشيك.
- واشترط المشرع في الشيك ان يكون المبلغ مكتوبا بالحروف والارقام، واذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا العبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
- يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها اذ يجب ذكر ما اذا كان العملة محل مبلغ الشيك هي الجنية المصري او الدولار الأمريكي او عملة اجنبية اخرى، علي انه اذا لم يذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها فالمفروض انه الجنية المصري الي ان يتم اثبات العكس.

- ويشترط اغلب الفقه ان يكون مبلغ الشيك واحدا وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ او وحدة الدين في الشيك. فلا يجوز ان يتضمن صك الشيك الوفاء بعدة مبالغ متفرقة او يتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث ان ذلك يتعارض مع اعتبار الشيك ادارة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع كما ان من شأن ذلك عرقلة تداول الشيك.

٣- اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء به:

(أ) اسم البنك المسحوب عليه :

يجب ان يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب عليه، واذا كان الشيك مسحوبا علي غير بنك فإنه لا يعتبر شيكا وانما يخضع للقواعد العامة.

(ب) مكان الوفاء به :

لا يجوز سحب الشيك علي ساحة الا اذا كان ساحة بنكا وقام بسحبه علي احد فروعه او تم السحب من احد الفروع علي فرع اخر ولكن يشترط في هذه الحالة الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .

ويجب علي البنك عند موافقته علي اعطاء شيكات الي عملية ان يكتب علي كل نموذج منها اسم البنك او احد فروعه الموجود به رصيد الساحب علي وجه الدقة ومكانه.

ويجب ان يذكر بجانب اسم البنك المسحوب عليه او احد فروعه الموجود به رصيد للساحب مكان وفاته، اي المكان الذي يوجد فيه البنك او المكان الذي يوجد فيه احد فروعه، واذا لم يكتب مكان الوفاء اعتبر الشيك مستحق في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.

٤- تاريخ ومكان اصدار الشيك:

(أ) تاريخ اصدار الشيك :

يجب ان يتضمن الشيك تاريخ اصداره فإذا خلا الشيك من تاريخ اصداره عند تقديمه للبنك فإنه لا يعد شيكا طبقا لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وقد يترك الساحب هذا البيان علي **بياض** مفوضا المستفيد في تحريره وقتما يشاء، وفي هذه الحالة يجب علي المستفيد كتابة تاريخ الإصدار قبل التقدم للبنك للوفاء بقيمته.

اما اذا كان الشيك مؤخر التاريخ اي يحمل تاريخا لاحقا علي تاريخ تحريره (**والذي كان يطلق عليه شيك الضمان**) فإن هذا الشيك وفقا لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م لا يعد باطلا، وانما يستحق الوفاء فور تقديمه للبنك المسحوب عليه .

وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة ٥١٥ من هذا القانون والشيكات الحكومية .

فلا تكون مستحقة الوفاء الا في التاريخ المبين بها كتاريخ إصدارها" .

يتضح من ذلك ان المشرع استثنى **الشيكات الحكومية** المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فهذه الشيكات لا تستحق الوفاء فور تقديمها وانما طبقا لتاريخ إصدارها، وهذا الحق مخول للحكومة يجوز لها ان تتنازل عنه وتعطي أوامرها للبنك بصرف هذه الشيكات بمجرد تقديمها دون انتظار تاريخ إصدارها .

الشيكات المسطرة لتلبية احتياجات التجارة والصناعة الي اداة ائتمان مستحقة الدفع في التاريخ المبين بها وتخضع في الوقت ذاته لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، كما ان الشيك المسطر تسطيرا خاصا لا يدفع قيمته الا الي البنك المكتوب اسمه بين الخططين، كما ان الشيك المسطر تسطير عام لا تدفع قيمته الا الي بنك او احد عملاء البنك المسحوب عليه.

(ب) اهمية تاريخ الاصدار:

١- تحديد ما اذا صدر الشيك خلال فترة الريبة من عدمه في حالة إفلاس الساحب.

٢- التأكد من وجود مقابل الوفاء وقت الإصدار.

٣- احتساب وقت تقديم الشيك للوفاء وفي تحديد بداية التقادم الصرفي.

(ج) مكان الاصدار :

يجب ان يتضمن الشيك مكان اصداره ولكن لا يترتب علي اغفال هذا البيان بطلان الشيك وانما يعتبر الشيك صادرا في موطن الساحب.

٥- اسم المستفيد:

لا يعتبر اسم المستفيد من البيانات الإلزامية للشيك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م لذلك يعتبر الشيك صحيحا ولو صدر بدون اسم المستفيد **ويعتبر شيكا لحاملة**

قد يكون الشيك اسميا، اي صادرا باسم شخص معين دون ان يسبقه شرط الامر، وهذا الشيك يكون قابلا للتداول بالتظهير.

وقد يكون الشيك إذنيا أو لأمر شخص معين، حيث يذكر اسم المستفيد مقترن بشرط الامر أو الأذن.

وقد يكون الشيك لحاملة حيث لا يذكر اسم المستفيد وانما يذكر انه لحامله **وهذا الشيك يتداول بمجرد التسليم.**

ويمكن ان يكون اسم المستفيد من الشيك خليطا من الصور السابقة كأن يصدر الشيك لصالح شخص مسمي مع عبارة او لحاملة حيث يعتبر في هذه الحالة شيكا لحاملة .
واذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر وكان مشتملا علي شرط غير قابل للتداول فإنه لا يدفع الا للمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط .

ويجوز اصدار الشيك لأمر الساحب نفسه، فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كان يقال : " ادفعوا لأمرى " وفي هذه الحالة يعتبر الشيك اداة لسحب نقود الساحب لدي البنك المسحوب عليه .

وفي حالة تحديد اسم المستفيد فإنه يجب تحديده بكل دقة حتي لا يقع لبس في تحديد شخصيته عند تظهير الشيك او الوفاء له بقيمته ، وليس هناك ما يمنع من ان يعين المستفيد بصفته او بوظيفته بشرط الا يدع مثل هذا البيان مجالا للشك في تحديد اسم وشخصية المستفيدين ويحدث ذلك اذا كان الشيك قد سحب لمصلحة شخص اعتباري يمثله صاحب صفة كان يقال مثلا:
ادفعوا لأمر رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب.

ويجوز ان يكون المستفيد من الشيك اكثر من شخص سواء علي سبيل الجمع كأن يقال: " ادفعوا لأمر عمر او حسن " وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه في حالة **الجمع** الا بالوفاء لهم جميعا وفي حالة التخيير لأي منهما.

٦- امر بالدفع لدي الاطلاع:

الشيك يجب ان يكون واجب الدفع بمجرد الاطلاع واي بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
ومما لا شك فيه ان المشرع باشتراطه ذلك اعاد للشيك وظيفته التي خلق من اجلها وهي انه اداة الائتمان، وبذلك اعاد المشرع للشيك الوضع الصحيح المتعارف عليه في العالم اجمع.

بناء علي ذلك اذا فرض وذكر علي الشيك انه: " يدفع بالإخطار " اي الذي يعلق دفعه علي وصول اخطار من الساحب الي البنك المسحوب عليه، او ورقة مرفقة بالشيك تفيد تأجيل الوفاء الي تاريخ معين، فهذه الورقة لا قيمة لها من الناحية القانونية علي صفة الشيك، وتدفع قيمة الشيك بمجرد تقديمه الي البنك.
اي انه يجب ان يكون امر الدفع لدي الاطلاع غير معلق علي شرط معين او مضاف الي اجل .

٧- اسم وتوقيع الساحب:

يجب ان يتضمن الشيك اسم الساحب وتوقيعه ، فهذا التوقيع هو الذي يفيد عنصر المديونية وبدونه يفقد الشيك قيمته القانونية.

واشترط المشرع ذكر اسم الساحب يسهل للحامل الاهتداء اليه، فلا يكفي التوقيع فقط نظرا لاحتمال ان يكون التوقيع غامضا وانما يجب ذكر اسم الساحب بجانب توقيعه .

يجب ان يكون هذا التوقيع علي نحو مقروء لكي يدل علي شخصية صاحبه .

توقيع الساحب قد يكون بخط يده فإذا لم يستطع ذلك جاز التوقيع بالختم او ببصمة الإصبع وجري العمل لدي البنوك بأن يضع العميل صورة توقيعه لدي البنك ليستطيع هذا الأخير اجراء المضاهاه بين توقيع الساحب لديه وتوقيعه علي الشيكات التي يحررها

لا يشترط ان يكتب التوقيع باللغة العربية او الأجنبية وان كان الاصل ان يدون التوقيع باللغة التي حرر بها الشيك.

٨- سحب الشيك لحساب شخص اخر :

أ) من الناحية التجارية :

يجوز سحب الشيك لحساب شخص اخر كما في **حالة الوكالة في سحب الشيك** " في هذه الحالة يجب ان يكون للوكيل سند وكالة، وفي حالة تكليف الساحب احد الأشخاص للتوقيع نيابة عنه علي صك الشيك يوقع الوكيل بصفته وكيلا وليس اصيلا، كما عليه ان يبرز صفته هذه عند توقيع الشيك والا كان ملتزما شخصيا بقيمة الشيك بوصفه اصيلا ، ويسري هذا الحكم علي النائب اذا تجاوز حدود سلطته، هذا من الناحية التجارية.

ب) من الناحية الجنائية :

من ناحية المسؤولية الجنائية اذا خرج الوكيل عن حدود الوكالة واعطي شيكا ليس له مقابل وفاء دون موافقة الموكل او خلافا لتعليماته فلا مسؤولية للموكل لانتفاء القصد الجنائي وانما يتحمل الوكيل نتيجة تصرفاته وتحق عليه المسؤولية الجنائية ويعتبر هو الساحب الفعلي للشيك ولا اعتبار لصفته كوكيل، واذا التزم الوكيل حدود وكالته فسحب الشيك وفقا لتعليمات الموكل، فإذا تبين ان الشيك لا يقابله رصيد او انه غير كاف **وثبت انه كان يعلم** بذلك قبل سحبه الشيك كان مسؤوليته الجنائية بوصفه فاعلا، اذ لا محل لفكرة النيابة في المسائل الجنائية ويعاقب الموكل باعتباره شريكا.

❖ قضت محكمة النقض تأكيدا لذلك بأنه "متى كان الثابت انالطاعني هو الذي اصدر الشيك بوصفه وكيلًا عن زوجته صاحبة الحساب دون ان يكون له وصيد قائم وقابل للسحب فأه، يكون مسئولًا ويحق عقابه بوصفه فاعلا اصليا للجريمة لان وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا ينفي انه هو الذي قارف الجريمة التي دين من اجلها.

٩- اصدار الشيك بدون توقيع او تزوير التوقيع :

❖ اذا صدر الشيك بدون توقيع الساحب فلا يعد التزاما في مواجهته ويلحق بعدم توقيع الساحب اصدار شيك بتوقيع مزور اذ يعتبر الشيك في هذه الحالة باطلاً لانه يحمل امر بالدفع من صاحبه الذي زور توقيعاه وفي هذه الحالة تقع علي البنك تبعه الوفاء بالشيك الذي يحمل توقيعاً مزوراً علي الساحب اذ علي البنك واجب التحري والفحص الدقيق لإمضاء المحرر، بل ان عليه تبعه هذا الوفاء ولو كان التزوير متقناً ويصعب اكتشافه وذلك علي اساس مخاطر المهنة طالما لم يصدر خطأ من الساحب في هذا الشأن.

❖ يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب علي وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اي خطأ الي الساحب، وكل شرط علي خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

١٠- تحريف الشيك وصورته بياناته :

❖ اذا وقع تحريف في متن الشيك **التزم الموقعون اللاحقون للتحريف** بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلي.

❖ وجوز الرجوع علي من قام بالتحريف وفقا للقواعد العامة سواء قواعد الإثراء بلا سبب او رد غير مستحق.

❖ يجب ملاحظة ان صورية بيانات الشيك لا تبطله الا اذا قصد منها اخفاء بيان او اكثر من البيانات الإلزامية لصحة الشيك، وعلي من يدعي هذه الصورية اثباتها وله في ذلك كافة طرق الإثبات وغالبا ما ترد الصورية في الشيك علي تاريخه اما بتقديمه او بتأخير.

❖ قد كان قانون التجارة صريحا عندما نص علي ان يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. باستثناء الشيكات المسطرة .

١١- التوقيع علي بياض :

❖ قد يتم الاكتفاء بتوقيع الساحب وذكر اسمه دون ذكر باقي بيانات الشيك حيث يعتبر ذلك تفويضا من الساحب الي المستفيد في ملئ بياناته، فإذا قام المستفيد بملئ البيانات فإن الشيك يصبح شيكا صحيحا .

ج) البيانات الاختيارية:

❖ كما يجوز اضافة بيانات اختيارية في الكمبيالة يجوز ايضا في صك الشيك اضافة بيانات اختيارية، ولكن يجب الا تتعارض هذه البيانات مع طبيعة الكمبيالة وحكم القانون.

❖ لذلك يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر .

❖ يجوز اشتراط عدم تظهير الشيك بوضع عبارة " ليس للأمر" او اية عبارة اخري بهذا المعني، وفي هذه الحالة لا يجوز تداوله الا بإتباع اجراءات حواله الحق .

❖ **يجوز للمظهر وضع شرط عدم الضمان.** وهذا الشرط لا يسري الا علي المظهر الذي وضعه فقط ويسري في مواجهة الموقعين اللاحقين له، ولكن لا يجوز للساحب وضع شرط عدم الضمان حيث ان الساحب يضمن وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .

❖ **كما لا يجوز وضع شرط "التقدم للقبول"** او شرط "عدم التقدم للقبول لأنه لا قبول في الشيك .

❖ كما يجوز ان يتضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف حيث يعفي الحامل من عمل الاحتجاج ولكن لا يعفي من عمل الاخطارات اللازمة للرجوع.

❖ وشرط الرجوع بلا مصاريف يجوز ان يضعه الساحب وفي هذه الحالة تسري اثار هذا الشرط علي كل الموقعين ، اما اذا كتب احد المظهرين او الضامين الاحتياطين سرت اثاره عليه وحده .

❖ كما يجوز لساحب الشيك او حاملة ان يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع علي صدره عبارة (**للقيد في الحساب**) او اية عبارة اخري تفيد هذا المعني، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة، وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.

❖ كما لا يجوز للمسحوب عليه في حالة اشتراط عدم الوفاء نقدا او وجود عبارة (**للقيد في الحساب**) شطب هذه العبارة، **واذا شطب** فلا يعتد بهذا الشطب ويعمل الشرط .

س/ اكتب في مقابل الوفاء (الرصيد) الذي يوجب القانون وجوده عند انشاء الشيك ؟

المبحث الثالث: مقابل الوفاء في الشيك (الرصيد):

- المقصود بمقابل الوفاء ← دين نقدي مساوي على الأقل مبلغ الشيك يكون للساحب عند المسحوب عليه (البنك) عند الاطلاع والذي يدفع منه هذا الأخير قيمة الشيك.
- سحب الشيك يفترض وجود علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تجعل الأول دائناً للثاني أيا كان طبيعة الدين تجاري أو مدني.

المطلب الأول: شروط مقابل الوفاء

الشرط الأول: يجب ان يكون مقابل الوفاء (الرصيد) ديناً نقدياً:

- يشترط حتى يعتبر مقابل الوفاء موجود ان يكون الساحب دائناً للبنك المسحوب عليه بمبلغ نقدي، ولا اهمية لمصدر هذا الدين فقد يكون وديعة نقدية يلتزم المسحوب عليه بردها عند الطلب، او حساب جاري مفتوح للساحب او اوراقاً تجارية للمسحوب عليه البنك لتحصيل قيمتها اذا تم تحصيل قيمتها فعلاً، وقد يكون اوراقاً مالية مفوض البنك المسحوب عليه في بيعها للساحب اذا تم بيعها بالفعل.
- لا تعتبر الأوراق التجارية او الأوراق المالية المسلمة للبنك للتصرف فيها صالحة لأن تكون مقابل الوفاء فهي ليست رصيда حاضراً الا اذا تم التصرف فيها او تحصيلها بالفعل.

الشرط الثاني: يجب ان يكون مقابل الوفاء (الرصيد) موجوداً عند سحب الشيك:

- هذا الشرط بديهي في الشيك، فطالما ان الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع فإنه يجب علي الساحب ان يعمل علي وجود مقابل الوفاء قبل اصدار الشيك، والا كان معرضاً للعقوبة المقررة لإصدار شيك ليس له مقابل وفاء .
- واذا لم يتوافر مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه، او وجد بعد تاريخ تقديم الشيك اعتبر مقابل الوفاء غير موجود.
- يجب ملاحظة ان عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر علي صحة الشيك فلا يترتب علي عدم وجوده بطلان الشيك حيث يظل الساحب ضامناً للوفاء بقيمة الشيك وكل شرط يعفيه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ويقع علي الساحب دون غيره ان يثبت عند الإنكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك، فإذا لم يقيم البنك بصرف الشيك بحجة عدم وجود مقابل وفاء كان علي الساحب اثبات وجود هذا المقابل والا تعرض لعقوبة إصدار شيك بدون وجود مقابل وفاء، ويعتبر تحمل الساحب القيام بهذا العبء تطبيقاً للقواعد العامة.
- واذا لم يقيم الساحب بإثبات مقابل الوفاء فإنه لا يستطيع ان يتمسك بسقوط حق الحامل الذي لم يقيم بعمل الاحتجاج او قام بعمله بعد الميعاد في الرجوع عليه وتبرء ذمة الساحب في هذه الحالة بمقدار مقابل الوفاء الذي اثبت وجوده لدي البنك المسحوب عليه الا اذا كان الساحب قد استعمل هذا المقابل في مصلحته حيث يعتبر مقابل الوفاء غير موجوداً في هذه الحالة .

الشرط الثالث: يجب ان يكون مقابل الوفاء (الرصيد) قابلاً للتصرف فيه:

- من الجائز ان يقدم الشيك في يوم اصداره للبنك المسحوب عليه لدفع قيمته لأنه مستحق الدفع لدي الاطلاع، لذلك يجب ان يكون مقابل الوفاء موجوداً وقابلاً للتصرف فيه وقت سحبه، اي يجب ان يكون دين الساحب لدي المسحوب عليه محقق الوجود وحال الاداء ومعين المقدار وخالي من اي نزاع حتي يستطيع الساحب التصرف فيه ويجب ان يكون مقابل الوفاء (الرصيد) قابلاً للتصرف فيه بموجب شيك ويفترض ذلك وجود اتفاق صريح او ضمني بين الساحب والمسحوب عليه علي اعطاء الساحب حق التصرف في هذا الدين بمقتضى شيكات، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق فلا يلزم الشيك المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك.
- إذا كان للساحب مبالغ لدي البنك المسحوب عليه متمثلة في ودائع لأجل او شهادات استثمار او غير ذلك من الصور المصرفية بين العميل والبنك المسحوب عليه فإنه لا بد من وجود تعليمات بين العميل والبنك سواء كانت صريحة، او ضمنية بصرف قيمة الشيك من هذه المبالغ عند عدم وجود رصيد سائل.
- اذا اصدار الساحب او امره للبنك المسحوب عليه بعدم الوفاء للمستفيد بقيمة الشيك في غير الحالات التي قررها القانون للمعارضة في الوفاء، فإن ذلك يعد بمثابة عدم وجود رصيد يوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها.

🔴 **والحالات التي يجوز فيها للساحب المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك محددة علي سبيل الحصر .**

- ١- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حاملة او الحجر عليه.
 - ٢- واذا حصل الاعتراض علي الرغم من هذا الحظر لأسباب اخري تعين علي محكمة الأمور المستعجلة بناء علي طلب الحامل ان تقضي بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوي أصلية.
- 🔴 **حسنا فعل المشرع ذلك في الفقرة الثانية منعا من التلاعب بين العميل والبنك المسحوب عليه حيث يستطيع حامل الشيك في حالة اصدار الساحب اوامر للبنك المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير حالات ضياع الشيك او افلاس الحامل او الحجر عليه ان يتقدم بطلب الي قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه طلب الاعتراض علي صرف الشيك، ويتعين علي القاضي في هذه الحالة اجابة الحامل الي طلبه ويقضي بشطب الاعتراض علي صرف الشيك، حتي ولو كانت هناك منازعة موضوعية منظورة امام قاضي الموضوع تتعلق بهذا الشيك.**

الشرط الرابع : يجب ان يكون مقابل الوفاء (الرصيد) مساويا بالاقل لمبلغ الشيك:

- 🔴 **تتوافر العقوبة المقررة في المادة ٥٣٤ تجاري سواء عند اصدار شيك ليس له مقابل وفاء او كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك، ويتحقق ذلك من خلال استرداد الساحب كل الرصيد او بعضه او تصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.**
- 🔴 **كان هناك رأي في ظل احكام المجموعة التجارية الملغاة، انه لا يجوز اعتبار الرصيد الناقص في حكم الرصيد المنعدم .**

🔴 **قد جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بنصوص صريحة في هذا الشأن حيث نص في المادة ٢/٤٩٩ علي انه:**

- 🔴 **اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان للحامل علي المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له علي المقابل الكامل" واذن في الفقرة الثالثة من ذات المادة ان " للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل ان يقبضه وفي هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مكانه عن الجزء الباقي".**
- 🔴 **مما لا شك فيه ان قيام الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي يعد امرا ضروريا لتوقيع العقوبة المقررة لاصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. وبالتالي لا اثر للوفاء الجزئي علي جريمة اصدار شيك بدون رصيد بالنسبة لباقي قيمة الشيك .**
- 🔴 **لكن يجب ملاحظة ان الوفاء الجزئي يبرأ ذمة الساحب او المظهرين والضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص اذا تم التأشير به علي الشيك .**

المطلب الثاني: ملكية مقابل الوفاء (الرصيد)

🔴 **نصت المادة ٧/٤٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م علي ان " تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الي حمله الشيك المتعاقبين، وبالتالي يعتبر حامل الشيك مالكا لمقابل الوفاء وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد اصدار الشيك.**

ويترتب علي ملكية الحامل لمقابل الوفاء (الرصيد) النتائج الآتية:

- ١- **اذا افلس الساحب بعد اصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فلا يجوز لسندك التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه، ويطبق ذات الحكم في حالة وفاة الساحب او الحجر عليه بعد اصدار الشيك حيث يكون مقابل الوفاء ملكا للحامل، ولا يجوز للورثة او القيم استرداده .**
- ٢- **لا يجوز للساحب بعد اصدار الشيك استرداد مقابل الوفاء كله او بعضه من البنك المسحوب عليه طالما ان الباقي من الرصيد لن يفي بقيمة الشيك .**
- ٣- **لا يجوز لدائي الساحب توقيع حجز للمدين لدي الغير علي مقابل الوفاء الموجود تحت يد البنك المسحوب عليه لانه اصبح ملكا للحامل.**
- ٤- **اذا سحبت عدة شيكات علي مقابل وفاء واحد لم يكن كافيا للوفاء بها جميعا، قدم حامل الشيك الأسبق في تاريخ السحب واذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل نفس التاريخ قدم الأسبق في الرقم الذي يحمله الشيك، واذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر شيكات مختلفة وتحمل نفس التاريخ وجب الوفاء اولا بالشيك الأقل مبلغا.**

الفصل الثاني: تداول الشيك

تتوقف طريقة تداول الشيك علي ما اذا كان شيكا اسميا او لأمر او لحامله، فالشيك المشروط دفعة لشخص مسمي سواء نص فيه علي شرط الأمر- حيث يعتبر شيكا لأمر- او لم ينص فيه علي شرط الأمر- حيث يعتبر شيكا اسميا- او لم ينص فيه علي شرط الأمر - حيث يعتبر شيكا اسميا- يكون قابلا للتداول بالتظهير، وقد اشارت الي ذلك المادة ٢/٤٨٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م ونصت علي ان: "الشيك المشروط دفعة لشخص مسمي سواء نص فيه علي شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير" يتضح من ذلك ان الشيك سواء كان شيكا اسميا او شيكا لأمر يتداول بالتظهير.

الشيك لحامله فإنه يتداول بمجرد المناولة والتسليم من يد الي يد. ولكن الشيك المشروط دفعة لشخص مسمي ولكن كتب فيه عبارة ليس للأمر او اي عبارة اخري تفيد هذا المعني، فإنه لا يجوز تداوله الا بإتباع حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب علي هذه الحوالة من آثار (المادة ٣/٤٨٦)،

كما يجوز تظهير الشيك للساحب او لأي ملتزم آخر، كما يجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد (المادة ٤/٤٨٦) ويعد التظهير الي المسحوب عليه في حكم المخالصة.

التظهير في الشيك قد يكون تظهيراً ناقلاً للملكية، وقد يكون تظهيراً توكيلياً ولم ينص المشرع في الشيك علي النوع الثالث، وهو التظهير التأميني نظراً لان طبيعة الشيك لا تتناسب مع هذا النوع من التظهير في الغالب فالتظهير التأميني في الكمبيالة يتحقق عندما يكون المظهر في حاجة الي نقود عاجلة وتكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة ، فيلجأ المظهر الي الاقراض ورهن الورقة بتظهيرها بما يفيد رهنها، وهذا غير متحقق في الشيك لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع.

لذلك سوف نقتصر في شرحنا لأحكام تداول الشيك علي التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي مع الرجوع لاحكام الكمبيالة فيما يلم يرد به نص خاص في أحكام تداول الشيك المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م وبما لا يتعارض مع احكام الشيك.

المبحث الاول: التظهير الناقل للملكية

المقصود بالتظهير الناقل للملكية ← نقل الحق الثابت بالكمبيالة من المظهر الي المظهر اليه.

في ذلك ذهب محكمة النقض الي ان التظهير التام والتظهير التأميني الذي يعد في حكم التظهير الناقل للملكية- اثره- نقل ملكية الحق الثابت في الورقة الي المظهر اليه، وتظهيرها من الدفوع، للمظهر اليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان هذا التظهير صحيحاً.

كما ذهب ايضا الي ان صلاحية الورقة التجارية للتداول عن طريق التظهير. لازمة. ان تكون مستقلة بذاتها ويتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي عدم جواز الرجوع في هذا الشأن الي وقائع او اتفاقات خارجة عنها".

لم يضع المشرع صيغة معينة يكتب بها التظهير الناقل للملكية، ولكن من المتفق عليه ان المقصود بالتظهير هو صيغة او عبارة تكتب علي الشيك نفس يقصد به تصرف المستفيد ويسمي المظهر نقل الحق الثابت في الشيك من شخصي الي اخر يسمي المظهر اليه وقد يقوم هذا المظهر اليه بدوره بتظهير الكمبيالة الي شخص اخر فيصبح هذا هو المظهر اليه ويصير الاول هو المظهر، وهكذا يتداول الشيك بالتظهير من شخص الي اخر حتي يستقر في يد المظهر اليه الاخير الذي يصبح بدوره هو الحامل الذي له الحق بالمطالبة بقيمة الشيك، وكلما زادت عدد التظهيرات كلما تضخم الضمان في الشيك وتبدو اهمية تظهير الشيك في الشيكات المسطرة لأنها اطول عمراً من الشيكات العادية.

التظهير يعتبر تصرفاً يعتبر تصرفاً قانونياً يترتب التزاماً في ذمة المظهر، لذلك يجب ان تتوافر فيه شوط موضوعية تستخلص من القواعد العامة ومن طبيعة هذا الالتزام، وشوك شكلية نص عليها المشرع.

لذلك سوف نتكلم عن الشروط الموضوعية في مطلب اول ثم نتكلم عن الشروط الشكلية في مطلب ثان، ثم نضيف مطلباً ثالثاً نتكلم فيه عن الآثار التي يترتب علي التظهير بعد توافر شروطه.

المطلب الاول: الشروط الموضوعية

اولا: الشروط الموضوعية العامة:

١- الأهلية:

يجب ان تتوافر في المظهر الأهلية التي يطلبها القانون في الساحب -أهلية التوقيع في علي الشيك- اي اهلية القيم بالأعمال التجارية نظرا لان المظهر ازاء المظهر اليه يعتبر في نفس مركز الساحب ازاء المستفيد. نظرا لأن المشرع قدر ان الالتزام الصرفي يعرض المدين به لأحكام اشد مما تقى به القواعد العامة، ويجب ان يبتعد عنه الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الأهلية الكاملة، لذلك قرر المشرع ان التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او بأية صفة اخري باطلة بالنسبة اليهم فقط. ويعتبر التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقي مع ذلك صحيحة.

٢- الرضا:

يجب ان يصدر التظهير عن رضا صحيح خالي من العيوب القانونية فيجب ان يكون التظهير منزها عن عيوب الرضا، فإذا وقع المظهر تحت تأثير **غلط او اكراه او تدليس او استغلال** كان التظهير باطلا بالنسبة اليه وجاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة المظهر اليه المباشر وفي مواجهة الحامل سيء النية الذي يعلم وقت حصوله علي الشيك بالظروف التي تم فيها التظهير قاصدا الإضرار بالمدين، اما في مواجهة الحامل حسن النية فلا يجوز التمسك بالبطلان لأن التظهير يظهر الكمبيالة من الدفع.

٣- المحل:

محل التزام المظهر في الشيك اي المبلغ الثابت فيها، لذلك فإن محل التظهير هو دائما ممكن ومشروع.

٤- السبب:

سبب التزام المظهر هو العلاقة بين المظهر والمظهر اليه التي علي اساسها تم تظهير الشيك. يشترط في سبب التزام المظهر ان يكون **مشروعا وموجودا** حيث يجب ان لا يكون سبب التظهير مخالفا للنظام العام والآداب، فالتظهير الحاصل وفاء لدين قمار يقع باطلا ولا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان علي الحامل حسن النية، كما هو الشأن في الدفع الناشئ عن عيوب الرضا، ويجب ان يكون سبب التظهير حقيقيا وليس سوريا والا وقع باطلا. سبب التزام المظهر مفترض انه مشروع وموجود، من يدعي خلاف ذلك عليه اثبات السبب الحقيقي بكافة طرق الإثبات.

ثانيا: شروط موضوعية خاصة بطبيعة التظهير:

الشرط الأول : الصفة في التوقيع:

يشترط في التظهير ان يصدر عن شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع وذلك بأن يكون المظهر هو مالك الحق الثابت في الشيك او وكيله عنه.

فالوكيل العام عن شخص في ادارة تجارته سلطة تظهير الشيك **ولمدير الشركة** تظهير الشيك الذي تحمله الشركة ولكن اذا ظهره بعد انقضاء الشركة فإنه يلتزم به شخصيا لان هذه السلطة تنتقل الي المصفي .

بطبيعة الحال الوكيل الخاص له صفة في اجراء التظهير عن الموكل، **وهناك حكم بأن للوكيل ، بعقد عرفي ان يقوم بتظهير الأوراق التجارية لموكله**، فينصرف الي موكله اثر ذلك التحويل وذلك لان رسمية التوكيل تتطلب اذا كان العقد المراد ابرامه رسميا . ويجوز ان يقتصر التظهير علي توقيع المظهر ويشترط لصحة هذا التظهير ان يكتب علي ظهر الشيك .

علي ذلك اذا وقع تزوير في توقيع الحامل الشرعي للشيك فإن التظهير يعد باطلا لصدوره من غير صفة. اذا صدر التظهير نيابة عن حامل الشيك بغير تفويض منه، او اذا تجاوز الوكيل حدود السلطة المخولة له، فإن من قام بهذا التوقيع يلتزم شخصيا بموجب الشيك.

بعض الطوائف التي يحظر عليها المشرع الاشتغال بالتجارة بالرغم من بلوغهم سن الرشد مثل المحامين والقضاة والموظفين واعضاء النيابة العامة وغيرهم فإن تظهيرهم للشيك لا يعتبر سببا لبطلان التزامهم بل يكون هذا التوقيع صحيحا وما يترتب عليه من التزامات.

تظهير المفلس للشيك بعد صدور حكم الإفلاس :

❖ لا يجوز للمفلس تظهير الشيك بعد صدور حكم الإفلاس فإن فعل ذلك فلا يحتج به علي جماعة الدائنين، وتصرفات المفلس صحيحة في العلاقة بينه وبين المظهر اليه، ولكن لا تنفذ بالنسبة لجماعة الدائنين، لان شهر الإفلاس لا يعتبر من قبيل نقص الأهلية او انعدامها وانما هي رفع يد المدين عن ادارة امواله او التصرف فيها لان الذي يتولي ذلك هو السنديك.

❖ قد اضاف المشرع انه اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق الا اذا عارض امين التفليسة في هذا الوفاء.

❖ لا يجوز للمدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس تظهير الشيك وفاءا للديون قبل حلول اجلها، حيث لا يحتج بهذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين .

❖ يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعية الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس (المادة ٦٠٣ تجاري) واذا حكم بعدم نفاذ اي تصرف فيحق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الي التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضي هذا التصرف.

الشرط الثاني : شرعية حق المظهر :

❖ شرعية حق المظهر او الحامل هي شرط لاستعمال جميع حقوقه المصرفية.

❖ ذهب رأي الي ان المقصود بالحامل الشرعي هو المستفيد الأصلي او من الت اليه الورقة بمقتضي سلسلة متصلة غير منقطعة من التظهيرات.

❖ اذا اعقب التظهير علي بياض تظهير اخر اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الشيك بالتظهير علي بياض.

❖ اذا حوي الشيك تظهيرات مشطوبة فإنها تعتبر كأن لم يكن .

❖ الواقع ان شرعية الحامل ليست قاصرة علي هذه الفروض فقط بل هناك من يكون مالكا للحق الثابت في الشيك دون ان يكون هو المستفيد الأصلي ودون ان تصل اليه عن طريق التظهير الصحيح كما لو اكتسب ملكية الحق الثابت فيه بالميراث او الوصية ويسمي تظهيراً قانونياً.

❖ اذا فقد احد الأشخاص حياة شيك (للحامل او قابل للتظهير) ووصل الي الحامل عن طريق سلسلة من التظهيرات غير المنقطعة، فإن هذا الحامل لا يلتزم بالتخلي عن الشيك الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية

الشرط الثالث : ان يكون التظهير باتا غير معلق علي شرط :

❖ يجب ان يكون التظهير غير معلق علي شرط فاسخ او واقف، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقي التظهير صحيحا.

❖ لا يعتبر تظهيراً ناقلا للملكية التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه، وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك، حيث لا يترتب علي هذا التظهير الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .

الشرط الرابع : ان يكون التظهير كلياً :

❖ يشترط في التظهير ان يرد علي مبلغ الشيك بالكامل، فالتظهير يجب ان يكون كلياً.

حكم التظهير الجزئي

❖ يكون التظهير الجزئي باطلا، والحجة في ذلك ان التظهير الجزئي من شأنه ان يعرقل تداول الشيك، لان المظهر لا يتخلى عادة عن الشيك طالما ان التظهير يرد علي جزء من مبلغه والتظهير يقتضي تسليم الشيك للمظهر اليه حتي يستطيع الرجوع علي البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتها والمسحوب عليه لن يقوم بذلك الا اذا استرد الشيك من الحامل هذا بالإضافة ان عدم وجود الشيك مع الحامل لن يمكنه من القيام بالإجراءات التي تطلبها قانون الصرف.

🌟 كان لنا رأيا خاصا يبقي علي صحة التظهير الجزئي، وكنا نود من المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م تقرير

صحة التظهير الجزئي للأسباب الآتية:

رأينا الخاص في التظهير الجزئي :

🌟 التظهير الجزئي يذهب بنا الي معنيين:

🌟 المعني الأول : ان يرد التظهير علي جزء من مبلغ الورقة التجارية.

بالنسبة للتظهير الجزئي الذي يرد علي جزء من مبلغ الورقة التجارية :

🌟 كنا نري- قبل صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩- ان هذا التظهير صحيح ناقلا للملكية بالنسبة لجزء المبلغ المظهر من اجله، اما باقي المبلغ فإنني اعتبر التظهير بالنسبة له تظهيراً توكيلياً في قبض الباقي ، وبالتالي يستطيع المظهر اليه ان يتسلم الشيك . بناء علي ذلك وبالتالي يستطيع البنك المسحوب عليه ان يوفي بقيمة الشيك للحامل واذا امتنع كان في استطاعة الحامل اتخاذ اجراءات قانون الصرف من تحرير الاحتجاج والرجوع علي الي الضامين واقامة الدعوي.

المعني الثاني : التظهير الذي لا يتم من جميع المالكين للورقة التجارية:

🌟 الغرض هنا ان الحق الثابت في الشيك مملوكا لأكثر من شخص ولكن التظهير وقع من البعض دون البعض الآخر.

🌟 كنا نري- قبل صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م- ان التظهير الحاصل من البعض دون البعض الآخر يعد تظهيراً صحيحاً في مواجهة الموقعين فقط،

🌟 ويعتبر المظهر اليه مالكا لهذا الجزء وكيلا في قبض الجزء الباقي نيابة عن الآخرين، كما يستطيع المسحوب عليه ان يوفي بكل المبلغ الي المظهر اليه بناء علي ذلك، او ان يوفي بجزء فقط من مبلغ الشيك يعادل ما يملكه الموقعين علي التظهير والذي اصبح مملوكا للمظهر اليه والامتناع عن دفع الجزء الباقي للمظهر اليه وتسليمه للآخرين الذين لم يوقعوا علي التظهير ويستطيع البنك المسحوب عليه ان يفعل ذلك حتي لو كان اعتماده شاملا لكل مبلغ الشيك.

الوفاء الجزئي :

🌟 اجاز قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الوفاء الجزئي حيث نصت المادة ٤٩٩ تجاري في فقرتها الثانية انه " اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان للحامل علي المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له علي المقابل الكامل. وازافت في فقرتها الثانية ان للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل ان يقبضه، وفي هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي وازافت الفقرة الثالثة بأن: تبرأ ذمة الساحب او المظهرين والضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتأشير بذلك علي الشيك" من قيمته" وعلي الحامل عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع(المادة ٤٢٧/٤،٤ تجاري).

🌟 علي ذلك يستطيع حامل الشيك في حالة تظهيره من بعض المالكين دون البعض الآخر ان يأخذ من قيمته ما يعادل ما يملكه الموقعون، وان يعمل احتجاج عدم الدفع عن الجزء الباقي باعتباره وكيلا عن الآخرين.

المطلب الثاني: الشروط الشكلية

الشرط الأول: أن يتم التظهير بالكتابة:

- يجب أن يتم التظهير بالكتابة ، وعلي ذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهه .
- يعد الشيك قابلة للتداول بالتظهير لو لم يضع الساحب **عبارة لأمر** في متن الصك، وإذا أراد الساحب أو أحد المظهرين عدم تداوله بالتظهير تعين عليه كتابة عبارة ليس للأمر " أو أي عبارة أخرى تقيد هذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يتداول الشيك إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليه من آثار .

الشرط الثاني: أن يرد التظهير على الشيك نفسه:

- يجب أن يرد التظهير على ذات الشيك حتى يتفق له الاستقلال والكفاية الذاتية وينبئ بذاته عن مضمونه **ولم يجيز المشرع أن يكتب التظهير على وصلة** مثلما فعل بالنسبة للكمبيالة نظرا لأن حياة الشيك غالبا ما تكون قصيرة واحكام تظهير الشيك قليلة الاستعمال لذلك لا يحتاج غالبا الي وصلة لتكملة التظهير
- يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر " **التظهير على بياض** ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم علي ظهر الشيك ، فإذا اكتفي المظهر بمجرد توقيعه فقط وتم ذلك علي صدر الشيك فإن هذا المظهر يعتبر في هذه الحالة **ضامنا احتياطيا** وبما انه لم يذكر اسم المضمون فإنه يعتبر ضامنا احتياطيا للساحب .

الشرط الثالث: توقيع المظهر:

- يشترط المشرع أن يضع المظهر توقيعه علي التظهير والا اعتبر كأن لم يكن، حيث لا يحدث للتظهير اثره القانوني اذا خلا من توقيع المظهر، بل ان المشرع اجاز ان يقتصر التظهير علي توقيع المظهر دون ذكر بيانات أخرى، وفي هذه الحالة يسمى التظهير علي بياض.
- هذا التظهير علي بياض لا يكون صحاحا الا اذا كتب علي ظهر الشيك .
- السبب في اشتراط المشرع وقوع التظهير علي بياض علي ظهر الشيك هو عدم وقوع لبس او غموض مع باقي التوقيعات التي يحملها الشيك مثل التوقيع بالاعتماد، أو الضمان الاحتياطي أو غير ذلك.
- التظهير علي وجه الشيك فإنه يكون صحيحا اذا اشتمل علي اسم المظهر اليه وتاريخ التظهير وتوقيع المظهر حيث لا يثير لبس او غموض في هذه الحالة.
- لكننا نري انه اذا اقتصر التظهير علي توقيع المظهر (التظهير علي بياض) ووقع علي صدر الشيك واشتمل علي أي عبارة تفيد نقل ملكية الحق الثابت في الشيك فإنه يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وينتج أثره ولا يعتبر للضمان.**
- توقيع المظهر قد يكون بالإمضاء أو الختم أو البصمة، وكلما انتقل الشيك من يد الي يد فإنه يحمل توقيعاً جديداً لأحد المظهرين الضامنين والجدد، وكلما زادت التوقيعات زادت قيمة الشيك وساعد ذلك علي تداوله والثقة فيه.

- إذا كان التظهير علي بياض بأن اقتصر علي توقيع المظهر علي ظهر الشيك جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر باعتباره مظهر اليه كما يجوز أن يظهر الشيك من جديد علي بياض بأن يكتفي بوضع توقيعه علي ظهر الشيك، أو يظهر الشيك الي شخص آخر سواء وقع هذا التظهير علي صدر الشيك أو علي ظهره طالما تضمن اسم هذا الشخص الآخر، كما يجوز للحامل أن يسلم الشيك الي شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهر أي حتي ولو لم يضع توقيعه عليه وفي هذه الحالة ينتقل الحق الثابت في الشيك **بالمناولة** (من يد الي يد)

الشرط الرابع: اسم المظهر اليه:

- في حالة وقوع التظهير علي **صدر الشيك** فإن بالإضافة الي توقيع المظهر يجب ذكر اسم المظهر اليه، الا اعتبر توقيع المظهر بمثابة ضمنا احتياطيا للساحب.
- لكن يجوز الا يذكر اسم المظهر اليه في التظهير ويقتصر علي توقع المظهر ولكن يشترط لصحة هذا التظهير أن يكتب علي ظهر الشيك، ويسمى التظهير في هذه الحالة " **التظهير علي بياض** " كما سبق أن ذكرنا ويجوز تظهير الشيك للساحب أو لأي ملتزم آخر مثل الضامن الاحتياطي أو المسحوب عليه، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

الشرط الخامس : تاريخ التظهير:

يتضمن التظهير عادة تاريخه، فلا شك في أهمية تاريخ التظهير حيث يفيد تاريخ التظهير في التحقق من اهلية المظهر وقت التظهير، وكذلك في معرفة ما اذا كان التظهير قد تم خلال فترة الرتبة او بعد شهر الإفلاس اذا كان المظهر تاجرا اشهر إفلاسه وكذلك لمعرفة ما اذا كان التظهير قد تم قبل احتجاج عدم الوفاء او لاحقا عليه.

المفروض في التاريخ المذكور في التظهير انه صحيح بغير إثبات اخر وعلي من يدعي عدم صحته اقامة الدليل علي ذل ، فتاريخ التظهير مفترض انه صحيح الي ان يقوم الدليل علي اثبات العكس.

المشرع في قانو التجارة رقم التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م افتراض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل **قبل انقضاء المحدد لعمل الاحتجاج** او ما يقوم مقام الاحتجاج وقبل انقضاء معاد تقديم الشيك، وبالتالي التظهير الخالي من التاريخ ينتج اثار التظهير الحاصل قبل الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج وقبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك، حيث ينقل ملكية الحق الثابت في الشيك ويظهر الورقة من الدفع، الا اذا ثبت ان التظهير الخالي من التاريخ حاصل بعد هذه المواعيد حيث يعتبر حواله حق ينتج اثارها .

بيانات التظهير الاختيارية:

يجوز للمظهر أن يدون بيانات اختيارية في صيغة التظهير، وضعه في ذلك مثل وضع الساحب عند انشاء الشيك، فيجوز للمظهر اضافة ما يشاء من بيانات طالما ان هذه الشروط لا تؤثر علي تحديد مضمون التظهير ووضوحه والا تؤثر علي مبدأ الكفاية الذاتية للورقة.

بناء علي ذلك يجوز للمظهر ان يضع **شرط عدم الضمان او شرط الوفاء الاحتياطي او شرط الرجوع بلا مصاريف وغير ذلك من الشروط** التي جري العرف علي ادراجها عند تظهير الشيك، كما يجوز له ان يشترط عدم قابلية الشيك للتداول بأن يضع عبارة " **ليس للأمر**" او اي عبارة اخري تفيد هذا المعني، ولكن لا يترتب علي هذا الشرط حرمان المظهر اليه ن تظهيره مرة اخري بل يحق له ذلك كل ما هنالك ان المظهر الذي اشترط عدم التداول لا يضمن الوفاء للموقعين اللاحقين.

قد نصت المادة ٤٩٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي انه " يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق علي غير ذلك ، ويجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

المطلب الثالث : اثار التظهير التام الناقل للملكية

اولا: نقل ملكية الحق الثابت في الشيك:

١- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الي المظهر اليه، حيث يترتب علي التظهير نقل ملكية الحق الثابت في الشيك من المظهر الي المظهر اليه وملكية الحق الثابت في الشيك ينتقل الي المظهر اليه دون حاجة الي رضا الساحب او المسحوب عليه .

٢- انتقال ملكية الحق الثابت في الشيك من المظهر الي المظهر اليه مشروط بأن يكون هذا الأخير هو الحامل الشرعي للشيك عن طريق سلسلة متصلة من التظهيرات حتي ولو كان اخرها تظهيراً علي بياض، واذا كان هناك تظهيرات مشطوبة فإنها تعتبر كأن لم تكن، واذا اعقب التظهير علي بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الشيك بالتظهير علي بياض.

٣- اذا كان الشيك لحامه، ورغم ذلك تم التوقيع عليه بالتظهير اعتبار الشيك شيكا لأمر بل يظل شيكا لحامه.

٤- اذا انتقل الشيك- سواء كان لحامه او قابلا للتظهير - الي حامل حسن النية فلا يلتزم بالتخلي عنه ورده اذا سرق او فقد من حامله الشرعي طالما اثبت حقه فيه عن طريق سلسلة غير منقطعة من التظهيرات، اما اذا حصل عليه بسوء نية، او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً فإنه يلتزم بالتخلي عنه للحامل الشرعي الذي فقد منه الشيك.

٥- نظرا لأن عملية التظهير مستقلة عن عملية اصدار الشيك وعن باقي العمليات التي تليها فإن الحق الذي يكسبه المظهر اليه ليس هو حق المظهر بما يحمله من عيوب، بل هو حق جديد خاص به ولا يعيبه العيوب التي قد تكون عاقلة بحق المظهر. فهذا الحق خاص بالمظهر اله ومباشر قبل المدين الأصلي والضامنين، ويمكنه من المطالبة بقيمة الشيك ومن هذه الناحية يتميز التظهير عن حوالة الحق حيث ينتقل الحق بذاته وعيوبه ودفعه من المحيل الي المحال له.

٦- انتقال الحق الثابت في الشيك من المظهر الي المظهر اليه يؤدي الي ان يقع علي المظهر اليه نفس الالتزامات التي كانت علي المظهر، حيث يلتزم بتقديم الشيك للوفاء قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه، او تقديمه للاعتماد من المسحوب عليه اذا كان متضمنا هذا الشرط، كما يجب عليه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء .

٧- ينتقل الحق الثابت في الشيك من المظهر الي المظهر اليه في حالة التظهير علي بياض .
ثانياً: الالتزام بالضمان:

١- الالتزام بالضمان الناشئ عن تظهير الشيك تقرر بحكم القانون ولا ضرورة للنص عليه في صيغة التظهير، حيث يترتب علي تظهير الشيك تظهيرا ناقلا للملكية ان يصبح المظهر الي جوار الموقعين السابقين،
ضمانا للوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق علي غير ذلك .

٢- يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد، وذلك بالتأشير عليه بأية عبارة تفيد ذلك .

📌 **مثال ذلك:** لا يجوز تظهيره"، او "محظور تظهيره" وفي هذا الحالة لا يلتزم المظهر الي وضع هذا الشرط بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بعد ذلك بتظهير لاحق وفي ذلك تنص المادة ٢/٤٩٠ تجاري علي انه: "يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق" .

📌 لا يستفيد من هذا الشرط **الا المظهر الذي وضعه فقط**، اما المظهرين السابقين او اللاحقين لهذا التظهير فلا يستفيدون من شرط عدم الضمان ويظل التزامهم بالضمان قائما تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات، لأن كل تظهير مستقل في وجوده وواصفه عن سائر التظهيرات الأخرى.

📌 يجوز للساحب أيضا ان يشترط عدم الضمان **بشرط ان يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه** وان يعتمد هذا الأخير الشيك، في هذه الحالة يفيد من الشرط جميع الموقعين علي الشيك، اما اذا تبين ان الساحب لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ولم يعتمد هذا الأخير الشيك بناء علي ذلك فإن الساحب يظل مسئولا عن الوفاء باعتباره هو المدين الأصلي وظل جميع الموقعين مستفيدين من هذا الشرط.

📌 هذا الشرط اذا تم وضعه في صيغة التظهير علي الشيك فإنه يسري علي المظهر اليه المباشر واي حامل لاحق للشيك، لأنه يعلم بهذا الشرط، لأنه وارد في الشيك، اما اذا كان الحامل لا يعلم بهذا الشرط لأنه وارد في ورقة مستقلة وليس في صيغة التظهير فانه لا يحتج بهذا الشرط في مواجهته، وبالتالي يقتصر هذا الشرط في هذه الحالة علي المظهر والمظهر اليه فقط ، ولكن الغالب ان هذا الشرط يرد في صيغة التظهير ذاتها حتي يستفيد المظهر من هذا الشرط في مواجهة المظهر اليه واي حامل لاحق للشيك.

ثالثاً : تطهير الشيك من الدفع (قاعدة تطهير الدفع):

١- المقصود بقاعدة تطهير الدفع:

📌 ان المدين بالورقة التجارية- سواء كان الساحب المسحوب عليه او احد المظهرين- لا يجوز له ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية للحامل حسن النية مستندا الي دفع كان يستطيع ان يتمسك به في مواجهة دائنة المباشر.

📌 اي ان الحامل حسن النية- الذي لا يعلم بهذه الدفع او كان عالما بها ولكن لم يقصد الأضرار بالمدين- يتلقي الحق خاليا من العيوب التي تشوبه، فلا يستطيع المدين التمسك في مواجهته بالدفع التي كان يستطيع ان يتمسك بها في مواجهة حامل سابق.

📌 مما لا شك فيه ان نتائج هذه القاعدة وآثارها تختلف عن حوالة الحق الذي ينتقل فيها الحق المحال به ومميزاته واوصافه كما هو المحيل الي المحال له، بحيث يحق للمدين ان يتمسك في مواجهة المحال له بالدفع التي كان يستطيع ان يتمسك بها في مواجهة المحيل.

📌 تعتبر قاعدة تطهير الورقة من الدفع من اهم قواعد قانون الصرف واهم اثر من اثار التظهير الناقل للملكية.

📌 هذا ولا اثر لإهمال حامل الشيك في عمل احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقام الاحتجاج علي قاعدة تطهير الدفع.

كما ان قاعدة تطهير الدفع تطبق ايضا علي الصكوك المدنية التي تتضمن شرط الأمر او الأذن .
إذا انشئ الصك بمناسبة عملة تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون او الاتفاق علي غير ذلك. ولا يجوز للمدين ان يحتج علي حامل الصك بالدفع المبني علي علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك او بحاملية السابقين ما لم يكن قصد حامله- وقت حصوله علي الصك- الإضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين.

يتضح من نص هذه الاداة ان المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م عامل الصكوك المدنية معاملة الأوراق التجارية خاصة اذا تم انشاء الصك بمناسبة عملة تجارية ، حيث طبق عليها احكام الاوراق التجارية فيما عدا تحرير احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء وإعلانه ورفع دعوي الضمان في مواعيد معينة.
هذه الأوراق المدنية التي تحتوي علي شرط الأمر او لحاملها يترتب علي التطهير الناقل للملكية لها او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الي الحامل الجديد بدون اتباع اجراءات الحوالة المدنية وفي حالة التطهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفا بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق وليس فقط وجود الحق وقت التطهير كما هو الحال في حوالة الحق، اذا انشئ الصك بمناسبة عملة تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن فيما بينهم ، حيث يستطيع الحامل الأخير الرجوع علي اي منهما منفردا او مجتمعين دون ان يستطيع اي منهما التمسك بالتجريد والتقسيم الموجود في الديون المدنية، كما تطبق علي هذه الصك قاعدة تطهير الدفع.

التطهير التام للورقة التجارية له اثار ثلاثة، الضمان ونقل الملكية وتطهير الورقة من الدفع، اما تطهير الأوراق المدنية فهو لا يرتب الا اثر نقل الحق الثابت في الورقة.

٢- شروط نطيف القاعدة:

لتطبيق هذه القاعدة لابد من توافر شرطين:

الشرط الأول: ان يكون التطهير ناقلا للملكية:

لكي تطبق قاعدة تطهير الورقة التجارية من الدفع لابد ان تكون الورقة مظهرة تطهيرا ناقلا للملكية، اما التطهير التوكيلي فليس من شأنه تطهير الورقة من الدفع وكذلك انتقال الشيك بطريق الحوالة المدنية او الي حاملها عن طريق الميراث او الوصية.

التطهير التأميني، وهو عبارة عن تطهير الشيك الي الدائن المرتتهن علي سبيل الرهن او علي سبيل التأمين، فمثله في ذلك مثل التطهير الناقل للملكية حيث تطبق قاعدة تطهير الدفع كأثر من آثاره.

الشرط الثاني: ان يكون حامل الشيك حسن النية:

يجب ان يكون حامل الشيك (المظهر اليه) حسن النية عند تلقيه الشيك- وقت التطهير، فإذا كان سيئ النية فإن هذه القاعدة لا تطبق وبالتالي يجوز للمدين بالشيك التمسك في مواجهة الحامل بكل الدفع التي كان يستطيع ان يتمسك بها في مواجهة المظهر.

مفهوم حسن النية في ظل المجموعة التجارية الملغاة:

اختلف الفقه في ظل احكام المجموعة التجارية الملغاة في تحديد المقصود بحسن النية، فقد ذهب الرأي الراجح، الي ان المقصود بحسن النية هو عدم علم الحامل المظهر اليه بوجود العيب الذي يدفع به في مواجهته، ويعتبر سيئ النية اذا كان يعلم وقت تلقيه الورقة بوجود هذا العيب او الدفع، فإذا تم إثبات هذا العلم فإنه لا يعتبر حسن النية ويمكن التمسك في مواجهته بالدفع الذي كان يعلم به ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر، اي ولو لم يثبت قصد الإضرار بالمدين وقت حصوله علي الورقة التجارية، لأن علي هذه القاعدة انه لا يجوز مفاجأة المظهر اليه بدفع لم يكن يعلمه عندما تلقي الورقة بالتطهير.

قد ذهب رأي اخر ، الي انه لابد من ثبوت تواطؤ المظهر مع المظهر اليه علي الإضرار بالمدين في الورقة التجارية بحرمانه من الدفع التي يجوز له توجيهها الي المظهر لأن الاكتفاء بعلم المظهر اليه بوجود هذا الدفع وقت تلقيه الورقة التجارية لاعتباره سيئ النية يؤدي الي عرقلة تداول الورقة التجارية وادائها وظائفها الاقتصادية وهذا الاتجاه هو الذي اخذه به قانون جنيف الموحد واخذ به المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م

موقف قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من مفهوم سوء النية:

أخذ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بالاتجاه الذي أخذ به قانون جنيف الموحد ولم يكتفي بمجرد علم الحامل بهذا الدفع وقت تلقيه الورقة التجارية حتي يعتبر سيئ النية وانما اشترط ان يكون الحامل وقت حصوله علي الورقة قاصدا الإضرار بالمدين، ويحدث ذلك اذا صدر غش او تواطؤ او اشتراك في تدليس بين المظهر وحامل الورقة التجارية.

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي فإنه يعتد في خصوص سوء النية من عدمه بشخص الممثل القانوني للشخص المعنوي.

٣- نطاق تطبيق قاعدة نظهر الدفع:

الدفع التي لا يحتج بها علي الحامل حسن النية (دفع يطهرها التظهير)

أ- الدفع بانعدام السبب او عدم مشروعيته:

إذا استند سحب الشيك او تظهيره الي علاقة غير مشرعة، او نتيجة العملية غير مشروعة بين الساحب والمستفيد او بين المظهر والمظهر اليه، كأن يكون تحرير الشيك او تظهيره تسوية لدين قمار، او تبين عدم وجود سبب حقيقي لتحرير الشيك او تظهيره، ففي هذه الحالات لا يجوز التمسك ببطلان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية.

ب- الدفع بعيوب الإرادة:

لا يمكن التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بالدفع بوجود عيب من عيوب الإرادة (كالغلط او الإكراه) الذي لا يعدم الإرادة او (التدليس او الاستغلال)، فهذه العيوب وان جاز التمسك بها في مواجهة من تلقي الشيك مباشرة ممن شاب العيب رضاه فإنه لا يجوز التمسك بها امام الحاملين الذين تلقوا الورقة التجارية وهم حسني النية بأن لم يكن لديهم قصد الإضرار بالمدين وقت حصولهم علي الشيك.

ج- الدفع بفسخ او انقضاء العلاقة الأصلية:

لا يجوز التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بفسخ العقد الذي من اجله حرر الشيك بين الساحب والمستفيد، او الذي من اجله ظهر الشيك بين المظهر والمظهر اليه، كذلك لا يجوز للمدين الاحتجاج بأنه او في الدين لحامل آخر او ان دينه انقضي بسبب مقاصة علي حق له ضد حامل سابق او ان دينه انقضي بالسقوط بالتقادم في مواجهة المظهر اليه المباشر.

الدفع التي يحتج بها علي الحامل ولو كان حسن النية (دفع لا يطهرها التظهير):

أ- الدفع الناشئ عن عيب شكلي:

الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في الشيك يحتج به علي الحامل ولو كان حسن النية لأن ظهور العيب لا يفترض معه حسن نية الحامل، والظهور هنا يفترض لأنه ينبغي التأكد من توافر البيانات الإلزامية قبل استلام الورقة فالعيب الشكلي واضح لأي شخص، فحامل الورقة التي بها عيب شكلي يعتبر حسن النية حتي ولو كان يجهل هذا العيب، وبالتالي يستطيع المدين يدفع في مواجهة الحامل ببطلان الشيك ولا تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا اذا كان الشيك مستوفيا من الناحية الشكلية ومتضمنا البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع، لأن هذا يعتبر شرطا مفترضا لقيام هذه الجريمة.

ب- الدفع بانعدام الإرادة:

انعدام الإرادة ينشأ اذا حرر الشيك او ظهر تحت تأثير اكراه مادي مطلق، او صدر التوقيع من محررها او مظهرها وهو في حالة غيبوبة ودون افعال منه، فالتظهير المصاحب لانعدام الرضا لا يطهر الشيك من الدفع لأن الالتزام الصرفي الذي تعتبر ارادة الموقع مصدره الأول لا يقوم ولا ينشأ، لذلك فإن انعدام الإرادة يحتج به علي الحامل ولو كان حسن النية.

الدفع بتزوير التوقيع او انعدام الإرادة في مواجهة الحامل حسن النية، لا يمنع من رجوع هذا الأخير علي الموقعين الآخرين التي تبقي مع ذلك التزاماتهم صحيحة تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات.

قد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٤٨٠ علي انه " اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او اشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب اخري اولمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقي مع ذلك صحيحة.

ج-الدفع بإنعدام او نقص الأهلية:

رغم ان هذا العيب غير ظاهرة في الشيك الا ان المشرع قدر ان مصلحة عديم الأهلية او ناقصي الأهلية اولي بالرعاية من مصلحة الحامل حسن النية، لذلك يجوز لناقص الأهلية او عديمها ان يحتج بنقص اهليته او انعدامها علي الحامل ولو كان حسن النية، ولا يجوز التمسك بهذا البطلان -من الموقعين علي الشيك- الا عديم او ناقص الأهلية فقط حيث ان هذا البطلان مقرر لمصلحته فقط تطبيقا لنص المادة ٤٧٩ من القانون التجاري و ثم ١٧ لسنة ١٩٩٩م التي تنص علي ان تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجار وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامين احتياطيين او بأية صفة اخري باطلة بالنسبة اليهم فقط.

د-الدفع المستند من علاقة شخصية بين المدين والحامل:

الدفع الناشئة عن العلاقة الشخصية بين المدين والحامل لا يطهرها تظهير الشيك، فيجوز للمدين التمسك في مواجهة الحامل بأي دفع يكون ناشئا عن علاقة شخصية بينهما، فإذا كان المدين باليك- سواء كان الساحب او المسحوب عليه او احد المظهرين- دائما لحامل الصك بناء علي علاقة خارجة عن نطاق الشيك فإنه يستطيع مطالبة الحامل بالمقاصة بدينه.

قد قضت محكمة النقض بأن للمظهر اليه الحق في الرجوع علي المظهر بقيمة السندات الأذنية المظهرة اليه اذا عجز عن تحصيل قيمتها، ويجوز اجراء مقاصة بين قيمة هذه السندات وبين سند كان المظهر اليه مدينا به المظهر.

ه-الدفع بتزوير التوقيع:

يستطيع المدين في الشيك الدفع بأن توقيعه مزورا نظرا لأنه في هذه الحالة لا توجد ارادة بالالتزام علي الاطلاق وهو يقو بهذا الدفع حتي في مواجهة الحامل حسن النية، فالتظهير لا يطهرها الدفع.

و-الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض:

يأخذ نفس الحكم السابق الدفع بحصول التوقيع علي الشيك من شخص غير مفوضا في ذلك فإذا حرر شخص شيك للأمر او ظهره باسم غيره دون ان يكون مفوضا في ذلك منه بوكالة صريحة او ضمنية، فلا يلزم الموكل المدين بالوفاء بقيمة الشيك حتي ولو كان الحامل حسن النية، يأخذ نفس الحكم اذا تجاوز الوكيل حدود وكرالته وقد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م في المادة ٣٨٩ علي ان " من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص اخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا اوفاهها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الي من ادعي النيابة عنه، ويسري هذا الحكم علي النائب اذا جاوز حدود سلطته" ورغم ان هذا النص خاص بالكمبيالة الا انه يسري علي الشيك ايضا لأنه لا يتعارض مع أحكامه (المادة ٤٧٢ تجاري).

ي-الدفع المستند من مضمون الشيك:

إذا ورد في الشيك شرط من الشروط الاختيارية التي يجوز للساحب او احد المظهرين وضعها في الشيك لتعديل احكام الالتزام الصرفي كشرط عدم الضمان، او عدم الوفاء، وغيرها من الشروط، في هذه الحالات يجوز للمدين ان يتمسك في مواجهة الحامل بهذه الشروط ولو كان حسن النية.

المبحث الثاني: التظهير التوكيلي

🔗 **التظهير التوكيلي** يقصد به قيام المظهر بتوكيل المظهر اليه في قبض قيمة الشيك وليس نقل ملكية الحق الثابت به. وكثيرا ما يقع هذا التظهير للبنوك حيث يعهد الحامل الي البنك الذي يتعامل معه بتحصيل قيمة اليك وأدراجه في حسابه.

المطلب الاول: شروط التظهير التوكيلي

(أ) الشروط الموضوعية:

🔗 في التظهير التوكيلي لا يشترط في المظهر ان تتوافر فيه اهلية الالتزام بالأعمال التجارية لانه لا ينقل ملكية الحق الثابت في الشيك، وبالتالي لا يلتزم بالضمان او القبول او غيره في مواجهة المظهر اليه لأنه مجرد وكيل عنه في قبض قيمة الشيك ولكن في التظهير الناقل للملكية يشترط اهلية القيام بالأعمال التجارية، لأن تظهير الشيك يستتبع مسؤولية المظهر والالتزام بأحكام قانون الصرف.

🔗 اما اهلية المظهر اليه فيكفي ان يكون مميزا، لأن الوكالة لا تفترض في الوكيل اهلية الالتزام حيث ينصرف اثار الالتزام الذي ينتج عن عمله الي الموكل ولا ينصرف الي الوكيل.

🔗 ويجوز للولي أو الوصي أو القيم ان يظهر الشيك التي يملكه ناقص الأهلية لتحصيل قيمته، كما يجوز لسنديك التفليسة ان يظهر الشيك المملوك للمفلس لتحصيل قيمته باعتباره وكيل عن المفلس فيحق له تظهير الشيك تظهير توكيليا، وللوكيل العام انابه غيره في تحصيل قيمة الشيك المملوك لموكله بتظهيره تظهيراً توكيلياً.

(ب) التظهير التوكيلي يجب ان يكون صريحا:

🔗 يجب ان يكون التظهير التوكيل صريحا، بان تدل عبارته بوضوح علي ان المظهر موكل المظهر اليه في القبض ، حيث يذكر في التظهير صراحة ان المقصود منه مجرد توكيل المظهر اليه في قبض قيمة الشيك كان يقال مثلاً "القيمة للتحصيل" او "القيمة للتوكيل".

🔗 وقد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م في المادة ١/٤٩٥ علي انه " اذا اشتمل التظهير علي عبارة (القيمة للتحصيل) او القيمة للقبض او للتوكيل او اي بيان اخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولكن لا يجوز له تظهيره الا علي سبيل التوكيل ثم اضاف في الفقرة الثانية من ذات المادة انه " ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج علي حامل الشيك الا بالدفع التي يجوز الاحتجاج بها علي المظهر.

🔗 يتضح من النص المشار اليه ان المظهر اليه توكيليا من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك مثل تحصيل قيمته او اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج واعلانه للملتزمين بموجب الشيك واقامة دعوي الرجوع، كما يكون للمظهر اليه توكيليا اعادة تظهير الشيك ثانيا الي الغير ولكن في هذه الحالة لا يملك سوي تظهيره تظهيراً توكيلياً الي الغير.

🔗 يستفاد ايضا من نص المادة ٤٩٥ ان التظهير التوكيلي لا يكون الا صيحاً، فإذا لم تتضمن عبارة التظهير ما يفيد توكيل او تفويض المظهر اليه في قبض قيمة الشيك اعتبار تظهير للملكية.

🔗 بذلك ألغي قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م التظهير التوكيلي الضمني، وهو تظهير كانت تفترضه المجموعة التجاري الملغاة لعدم توافر البيانات التي تطلبها المشرع في التظهير الناقل للملكية وقد كان يطلق عليه ان ذاك التظهير الناقص او التظهير المعيب او التظهير علي بياض، حيث اصبح بموجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م تظهيراً ناقلاً للملكية.

المطلب الثاني: اثار التظهير التوكيل

📌 اذا تم التظهير التوكيلي فإنه يترتب اثارا تختلف عن التظهير الناقل الملكية. وتختلف اثار التظهير التوكيل في علاقة المظهر بالمظهر اليه وفي علاقة المظهر اليه بالغير.

(أ) اثار التظهير التوكيلي بالنسبة للمظهر والمظهر اليه:

١- يلتزم المظهر اليه بتنفيذ تعليمات المظهر باعتباره وكيلًا عنه فعليه ان يقدم الشيك للاعتماد وان يطالب بقيمته، وان يقدمه للوفاء قبل فوات المواعيد المقررة لذلك ، ويلتزم ايضا المظهر اليه بتنفيذ تعليمات الموكل (المظهر) فيما يتعلق بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج واعلانه والرجوع علي الضامين ويكون المظهر اليه مسؤولا اذا لم تتبع هذه التعليمات حيث يعتبر ذلك اهمالا منه في تنفيذ الوكالة اذا ترتب علي ذلك ضررا بالمظهر.

٢- يلتزم المظهر اليه بتقديم حساب للموكل (المظهر) ، وبالتالي يوفي المظهر بقيمة الشيك التي قام بتحصيلها، كما يلتزم المظهر ان يرد للمظهر اليه الوكيل كافة المصروفات التي انفقتها في سبيل تحصيل الشيك والمحافظة علي حقوق المظهر بالإضافة للفوائد من وقت الإنفاق ، وتقوم البنوك عادة بخصم عمولة من مبلغ الشيك نظير تحصيلها لحساب المظهر.

٣- يجوز للمظهر ان يعزل المظهر اليه (الوكيل) في كل وقت ولو بعد حلول ميعاد الاستحقاق ما دام ان الوفاء بقيمتها لم يتم بعد واذا افلس المظهر اله (الوكيل)، يجوز للمظهر (الموكل) استرداد الشيك اذا كان لم يحصل بعد، فإذا كان المظهر اليه قد قبض قيمته فإن المظهر ليس امامه الا الدخول في التفليسة كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء

📌 لكن اذا قام المدين بالشيك بالوفاء بقيمته للوكيل المظهر اليه دون ان يعلم بوفاة المظهر او فقده لاهليته، هل يعتبر وفائه الشيك صحيحا ام يجبر علي الوفاء مرة اخري؟

📌 وضع قانون جنيف الموحد حلا لهذا وقرر بأن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاة الموكل او فقده اهليته، واتبعه في ذلك قانون التجارة حيث نصت المادة ٣/٤٩٥ علي ان " لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه" وبالتالي يعتبر وفاء المدين بالشيك بقيمته للمظهر اليه تظهيرًا توكيليا وفاء صحيحا اذا لم يعلم بوفاة المظهر الموكل او الحجر عليه.

(ب) اثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر اليه بالغير:

📌 يعتبر ايضا المظهر اليه في مواجهة الغير وكيلًا عن المظهر لذلك يترتب ماييلي:

١- يجوز للمدين والضامين في الشيك التمسك في مواجهة المظهر اليه توكيلا بالدفع التي كان يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر، لأن التظهير التوكيلي لا يظهر الورقة من الدفع. وقد قرر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ذلك عندما نص في المادة ٢/٤٩٥ علي انه " ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج علي حامل الشيك الا بالدفع التي يجوز الاحتجاج بها علي المظهر".

٢- للمظهر اليه ان يتخذ في مواجهة الغير- المسحوب عليه او الموقعين المظهرين- كافة الإجراءات التي يتطلبها قانون الصرف ومنها توقيع الحجز التحفظي علي المدين بالشيك وله ان يطلب شهر افلاسه.

٣- لا يجوز للمظهر اليه تظهير الشيك الا علي سبيل التوكيل وقد نص علي ذلك قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١/٤٩٥، وهذا يخالف ما كان متبع في ظل احكام المجموعة التجارية الملغاة التي كانت تجيز للمظهر اليه تظهيرًا توكيليا ان يظهر الشيك تظهيرًا ناقلا للملكية الي الغير حيث نصت المادة ١٣٥ من المجموعة التجاري الملغاة علي ان للمظهر اليه توكيلا الحق في نقل ملكية الورقة لشخص اخر علي ان يكون مسؤولا في هذه الحالة بصفته مظهرًا.

٤- في علاقة المظهر اليه بالغير يعتبر التظهير المعيب الناقص او التظهير علي بياض الصادر من المظهر اليه الوكيل في حكم التظهير التوكيلي لانه لا يجوز له تظهير الشيك الا علي سبيل التوكيل.

الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي في الشيك

المبحث الأول: ماهية الضمان الاحتياطي وشروطه

أولاً: ماهية الضمان الاحتياطي:

قد يقدم أحد الملتزمين بالشيك كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمته، وسبب طلب أحداً من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الشيك علي الوفاء فيطلب منه تقديم كفيل وعلي ذلك.

- ١- يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة الالتزام ثابت في الشيك يقدمها شخص يضمن دفع قيمة الشيك.
- ٢- يعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً علي ورقة تجارية.

ثانياً: شروط الضمان الاحتياطي في الشيك:

هناك شروط موضوعية تتعلق بأشخاص الضمان الاحتياطي، وشروطه شكلية تتعلق بكيفية اجرائه.

١- الشروط الموضوعية:

أ- الملتزمون الذين يجوز ضمانهم احتياطياً:

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم بالشيك كالمساحب أو المظهر أو المسحوب عليه البنك أ. ويعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون، وإذا أوفي الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك فليس له الرجوع إلا علي المضمون وعلي من يضمنوه من الملتزمين السابقين وهم الموقعين السابقين عليه.

ب- شخص الضامن الاحتياطي:

الضمان الاحتياطي في الشيك جائز من أي شخص ولو كان ممن وقعوا علي الشيك وأصبح ملتزماً به فيما عدا المسحوب عليه.

٢- الشروط الشكلية:

الضمان الاحتياطي يجب أن يتم كتابة علي الشيك وبذلك لا يجوز الضمان الاحتياطي شفاهة أو علي ورقة مستقلة عن الشيك.

المبحث الثاني: آثار الضمان الاحتياطي في الشيك

١- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون:

أ- للضامن الاحتياطي ذات الحقوق المقررة الملتزم المضمون وعليه التزاماته، فإذا أوفي الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك كان من حقه الرجوع علي المضمون بإحدى دعويين، أما بالدعوي الشخصية الناشئة عن الكفالة، وأما بدعوي الحلول وهي دعوي صرفية يحل فيها الضامن الاحتياطي محل الحامل.

ب- من المفروض أن يكون التزام الضامن الاحتياطي للالتزام تابعا لالتزام المضمون في الصحة والبطان لان الضامن كفيل، فلا يكون التزام الكفيل صحيحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحيحاً ومع ذلك فإن التزام الضامن الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص اهليته أو انعدام إرادته أو غير ذلك عد البطان لعيب في الشكل تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات.

٢- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل:

أ- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج علي الحامل إلا بالدفع التي يجوز للمضمون الاحتجاج بها.

ب- الضامن الاحتياطي للمظهر يستطيع أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطره بالاحتجاج شخصياً.

ت- في مواجهة الحامل بالدفع بالتجريد، أي بوجوب الرجوع علي المضمون قبل الرجوع عليه، كما يمنع عليه التمسك بالدفع بالتقسيم، أي تقسيم الدين بينه وبين الملتزم المضمون، لأنه متضامن بالوفاء.

٣- علاقة بين الضامن الاحتياطي وبالملتزمين الآخرين:

إذا أوفي الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك، كان له الرجوع علي الموقعين علي الشيك علي النحو التالي:

- إذا كان ضامناً للمساحب فلا رجوع للضامن الاحتياطي إلا علي المساحب أو البنك المسحوب عليه الذي تلقى مقابل للوفاء.
- إذا كان ضامناً لأحد المظهرين كان له الرجوع علي هذا المظهر وغيره من المظهرين السابقين الضامين لهذا المظهر دون المظهرين اللاحقين، ويرجع علي المساحب والمسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.
- إذا كان ضامناً للمسحوب عليه فليس له الرجوع إلا علي المساحب في حالة عدم إثبات المساحب وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه.

الفصل الرابع:

احكام الوفاء بقيمة الشيك والامتناع عن الوفاء المبحث الأول: احكام الوفاء بالشيك

ميعاد تقديم الشيك للوفاء:

الشيك اداة وفاء، اي واجب الدفع بمجرد الاطلاع، حيث يجوز تقديمه للوفاء في اي وقت بعد انشائه، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولو تضمن تاريخا اخر بصلبه .

اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم البين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقدمه وذلك باستثناء الشيكات المسطرة والشيكات الحكومية فلا يتكون مستحق الوفاء الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها" والواقع ان استثناء الشيكات الحكومية في هذا المجال سببه أن الدولة تحرر شيكات اجله للمرتبات واصحاب المعاشات حتي يتم تسهيل عمل الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية وتسهيلا لصرف هذه المرتبات والمعاشات بما لا يعوق صرفها في اليوم المحدد لها.

لكن لا يوجد مبرر لاستثناء الشيك المسطر .

ولكن يبدو لنا انا المشرع استهدف من هذا الاستثناء استخدام الشيك المسطر لتلبية حاجات الصناع والتجار الي اداة ائتمان مستحقة الدفع في التاريخ المبين بها وتتمتع في الوقت ذاته بمزايا الشيك وفقا لأحكام قانون التجارة واهمها الحماية الجنائية، وذلك وصولا لاستقرار والمعاملات التجارية التي تتم تسويتها بشيكات آجلة. والاصل في الشيك انه اداة وفاء ، ومن يدعي خلاف هذا الأصل عليه اقامة الدليل علي ما يدعيه.

ويذهب جانب من الفقه **تعريف الشيك المسطر** بأنه ، الشيك الذي يتضمن خطين متوازيين علي صدر الشيك بينهما فراغ دون اشتراط اتجاه معين لهذين السطرين، ويقصد من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه الي ضرورة ان يكون المستفيد من الشيك احد البنوك .

ونري ان الشيك المسطر هو شيك يشتمل علي البيانات التي نص عليها القانون ويميزه انه يوضع علي صدره من الساحب او الحامل خطان متوازيات دون اشتراط اتجاه معين لهذين الخطين، ولا يجوز وفاء الشيك المسطر الا في التاريخ المبين به كتاريخ لأصداره وتدفع قيمته بالقيد في حساب العميل.

والتسطير قد يكون عاما او خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما كلمة (بنك) او اي عبارة اخري بهذا المعني كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .

ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك الا الي البنك المكتوب اسمه بين الخطين.

يتضح مما تقدم ← ومن حكم المادة ٢/٥٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ انه اذا كان الشيك المسطر يحتوي علي تاريخ مؤجل باعتباره تاريخ لإصداره وجب علي البنك المسحوب عليه الانتظار لحين حلول التاريخ الوارد به ولا يجوز الوفاء بقيمته في يوم تقديمه.

ونري ان النظام الخاص بهذا الشيك المسطر لا يتعلق الا بوفائه دون تداوله الذي يظل خاضعا للقواعد العامة، فيجوز تظهير الشيك المسطر لشخص اخر، علي ان من ينتقل اليه الشيك المسطر يلتزم بتحصيله عن طريق البنك.

هذا وقد حدد المشرع التجاري في المادة ٥٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م مواعيد يتعين تقديم الشيك خلالها للوفاء بقيمته حيث فرق بين الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها، حيث يجب تقدمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر وبين الشيك المسحوب في اي بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها حيث يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر.

موضوع الوفاء:

يتم الوفاء بقيمة الشيك بالكامل، وعادة ترفض البنوك الوفاء الجزئي اذا كان الرصيد لا يغطي قيمة الشيك بالكامل ولكن جاء قانون التجارة وقرر بأن يكون للحامل علي المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له علي المقابل الكامل، واعطي للحامل حرية رفض المقابل الناقص او قبضه، واذا قبض المقابل الناقص يؤشر المسحوب عليه البنك علي الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي، وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين او الضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به .

العملة الواجب الوفاء بها:

- العملة المشروط الوفاء بها في صلب الشيك هي التي يجب الوفاء بها، ويلتزم المسحوب عليه بالوفاء بالعملة المتفق عليها اذا كان للساحب طرف المسحوب عليه ذات العملة.
- اذا حدث واشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجني معين دون ان يكون للساحب لدي المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن لدي المسحوب عليه البنك وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد لدي البنك المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة، هذا ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء .
- واذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف الساري يوم التقديم او وقت الوفاء (المادة ٣/٥١٠ تجاري) واذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت.
- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركا مثل الدولار الأمريكي والدولار الكندي، وتختلف قيمته في بلد الاصدار عن قيمته في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء

شروط صحة الوفاء:

حتى يعتبر الوفاء صحيحا يجب توافر الشروط الاتية:

- الشرط الاول :- ان يتم الوفاء للحامل الشرعي ← ويعتبر حاملا شرعيا للشيك المستفيد الاول او المظهر اليه او من الت اليه ملكية الشيك عن طريق الميراث او الوصية .
- الشرط الثاني :- يجب ان يتوافر في الشيك الشروط الشكلية لصحته ← وعلي المسحوب عليه التحقق من ذلك حيث يمتنع علي المسحوب عليه الوفاء اذا كانت بيانات الشيك ناقصة او معيبة او اذا لاحظ بالفحص العادي وجو كشط او شطب او تحشير بين الكلمات او السطور في الشيك، ويميل الاتجاه الحديث الي مسألة البنوك دائما عن الوفاء بشيك مزور مهما بلغت درجة اتقان التزوير علي اساس تحمل تبعة مخاطر المهنة .
- الشرط الثالث :- الا تحدث معارضة في الوفاء لدي المسحوب عليه ← لا تقبل هذه المعارضة الا في حالة ضياع الشيك او افلاس الحامل او الحجر عليه، ويندرج تحت حالة الضياع سرقة او فقده .

الاعتراض في الوفاء:

حالات الاعتراض في الوفاء:

- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة صياغة او افلاس حاملة او الحجر عليه .
- بناء علي ذلك باستثناء حالة ضياع الشيك او افلاس الحامل او الحجر عليه لا يجوز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك سواء وقعت المعارضة بإعلان عادي بالامتناع عن الدفع للحامل او اتخذت صورة حجز ما للمدين لدي الغير.
- يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة التي تجيز لكل دائن بدين محقق الوجود وحال الاداء أن يحجز تحت يد الغير علي المبالغ المستحقة لمدينة ولو كان مؤجلة او معلقة علي شرط وتسمي هذه القاعدة بحجز ما للمدين لدي الغير، لذلك يمتنع علي دائن الحامل ان يحجز تحت يد المسحوب عليه عن مبالغ مستحقة للحامل لان حجز ما للمدين لدي الغير يعتبر معارضة في الوفاء منعها المشرع التجاري الا في حالة ضياع الكمبيالة وإفلاس الحامل او الحجز عليه.
- قد اراد المشرع التجاري تمكين الشيك من اداء وظيفته كأداة وفاء، واطمئنان الحامل في الحصول علي قيمة الشيك بمجرد الاطلاع، لذلك حرم المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك الا في حالات استثنائية.

الحالة الاولى: افلاس الحامل او الحجز عليه:

أ- افلاس الامل :

- ينترتب علي افلاس الحامل غل يده عن ادارة امواله والتصرف فيها، فيمتنع عليه استيفاء حقوقه ويحل امين التفليسة محل المدين المفلس في ادارة اموال المفلس وتحصيل حقوقه لدي الغير والتصرف في الاموال.
- لذلك يحق لأمين التفليسة المعارضة في وفاء البنك المسحوب عليه للحامل المفلس وتقع المعارضة بإخطار امين التفليسة للبنك للمسحوب عليه بالامتناع عن الوفاء للحامل واذا لم يعارض أمين التفليسة في الوفاء جاز للبنك للمسحوب عليه الوفاء للحامل المفلس بقيمة الشيك، وفي ذلك تنص المادة ١/٥٩٠ من قانون التجارة قم ١٧ لسنة ١٩٩٩م انه لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق" وازادت الفقرة الثانية انه" ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق الا اذا عارض امين التفليسة في هذا الوفاء .
- يتضح من ذلك او الوفاء للحامل المفلس بقيمة الشيك في حالة عدم اعتراض امين التفليسة امر جوازي للبنك المسحوب عليه بمعنى ان البنك المسحوب عليه قد يمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك حتي ولو لم يصله اعتراض من امين التفليسة اذا علم بصدور حكم بشهر افلاس الحامل.

نحن نري ان إجبار البنك المسحوب عليه علي الامتناع عن الوفاء بمجرد علمه بصدر حكم شهر الإفلاس حتي ولو لم يصله اعتراض من امين التفليسة مخالفة لحكم المادة ٢/٥٩٠ من القانون التجاري التي تعطي للمسحوب عليه الحق في الوفاء او الامتناع فالمسألة جوازيه للمسحوب عليه لأنه قد تكون من مصلحته الوفاء للحامل المفلس طالما لم يصله اعتراض من امين التفليسة لكي يتخلص من عبء الوفاء بقيمة الشيك.

ب- الحجر علي الحامل:

يأخذ حكم إفلاس الحامل صدور قرار بالحجر عليه سواء في حالة نقص الاهلية او انعدامها.

الحالة الثانية: ضياع الشيك:

في هذه الحالة نفرق بين الشيك لأمر والشيك لحامله

ضياع الشيك لأمر:

ضياع الشيك يعني فقدته او سرقة او هلاكه او تلفه او اوي حالة يفقد فيها الحامل صك الشيك دون ارادته. في هذه الحالة يتعين علي حامل الشيك الذي حدث له ذلك اخطار البنك المسحوب عليه بالامتناع عن الوفاء لمن يتقدم له حاملاً الصك ويجب علي البنك المسحوب عليه بمجرد اخطاره بذلك الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لمن يتقدم له حاملاً الصك لحين الانتهاء من النزاع بين حامل الصك ومن يدعي ملكيته ويتحمل المسؤولية في حالة الوفاء رغم اخطار المعارضة. اذا قام الحامل بإخطار البنك المصحوب عليه بالمعارضة في الوفاء لمن يتقدم له للوفاء حاملاً الصك كان عليه ان يثبت بعد ذلك انه المالك الشرعي للصك للحصول على حقه. نفرق في ذلك بين علاقة مالك الشيك الحقيقي والحامل الجديد وعلاقة مالك الشيك الحقيقي والبنك المسحوب عليه.

١- علاقة مالك الشيك بالحائز له:

اذا تعرف مالك الشيك الحقيقي علي حائزه- الذي سرقة او عثر عليه او انتقل اليه من هؤلاء- كان له حق استرداده . في هذه الحالة نفرق بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية فإذا كان الحائز سيئ النية بأن عثر عليه او سرقة او انتقل اليه وهو يعلم بضياعه او سرقة كان من حق مالك الشيك الحقيقي استرداده اما اذا كان الحائز حسن النية فإن اغلب الفقه يفضل مصلحة الحائز حسن النية عن المالك الشرعي للشيك حماية لاستقرار التعامل بالأوراق التجارية ولأن الشيك يتداول بالتظهير.

٢- علاقة مالك الشيك بالبنك المسحوب عليه:

اذا ضاع الشيك فإنه يجوز لمالك الشيك الضائع الحصول علي نسخة منه ويكون ذلك بالرجوع الي الساحب اذا لم يتم تظهيره او الي من ظهر اليه ويلتزم هذه المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر الي مظهر حتي يصل الي الساحب واضافت الفقرة الثانية بأن " ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره علي نسخة الشيك المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد يقوم المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعارض وعنوانه في احدي الصحف اليومية، ويكون باطلا كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر (المادة ٣/٥١٢ تجاري).

من ناحية اخري راعي المشرع مصلحة حائز الشيك لحامله في حالة الاعتراض حيث قد يكون صاحب حق علي هذا الشيك لذلك اعطي له المشرع حق المنازعة لدي المسحوب عليه في الاعتراض الذي قدم لمنع الوفاء بقيمة الشيك، وفي هذه الحالة يلتزم البنك المسحوب عليه بأن يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه

تحقيقاً لذلك يلتزم حائز الشيك بإخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوي استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وذلك حتي لا يظل امر الشيك معلقاً ويشتمل الإخطار علي اسباب حيازة الشيك وتاريخها فإذا لم يقيم المعارض برفع دعوي الاستحقاق خلال الثلاثين يوماً المذكورة تعين علي قاضي الامور المستعجلة بناء علي طلب حائز الشيك أن يقضي بشطب الاعتراض ويعتبر بالنسبة للمسحوب عليها مالكة الشرعي.

الزم المشرع في هذه الحالة البنك المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك الا لما يقدم له من الخصمين حكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقرر له بالملكية

اذا أنقضت ستة اشهر من اريخ الاعتراض في حالة ضياع الشيك لحاملة دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك

المبحث الثاني : الامتناع عن الوفاء وآثاره

إثبات الامتناع عن الوفاء ومدته:

- ❖ إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته أو لإفلاسه أو نتيجة تلقيه معارضة في الوفاء أو يمتنع عن الوفاء لعيب في شكل الشيك أو لعدم مطابقة التوقيع الوارد علي الشيك للتوقيع المودع في البنك في حالات الامتناع هذه يحق للحامل الرجوع علي الضامنين الموقعين السابقين لأنهم ضامنين للوفاء علي وجه التضامن، وقبل هذا الرجوع عليه اثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج واجاز له المشرع عوضا عن هذا الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك ويكون هذا البيان مذيلا بتوقيع من اصدره .
- ❖ يتضح من ذلك ان المشرع لم يقتصر علي تحرير الاحتجاج لإثبات الامتناع عن الوفاء، وذلك يرجع الي ان الشيك يعتبر اداة وفاء خالصة تجري مجرد النقود فيكون من العنت والإرهاق التمسك بتحرير احتجاج عدم الوفاء لذلك اجاز المشرع في قانون التجارة اثبات الامتناع عن الدفع ببيان يصدر من البنك المسحوب عليه، وهذا البيان لا يمنع الحامل من تحرير احتجاج عدم الدفع اذا فضل هذا الطريق.
- ❖ تحقيقا لذلك قرر المشرع انه لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل شرط الرجوع بلا مصاريف- الذي يعفي الحامل بمقتضاه من عمل الاحتجاج- وقد اعطي المشرع للبنك المسحوب عليه لإصدار البيان حرية طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
- ❖ هذا وقد وضع المشرع جزاء جنائيا اذا امتنع موظف البنك المسحوب عليه من تسليم الحامل البيان المشار اليه هذا الجزاء ه هو الغرامة التي لا تقل من ثلاثة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه مع تضامن البنك في القضاء بقيمة الغرامة (المادة ٥٣٣/ج ٢).
- ❖ يجب علي حامل الشيك إثبات الامتناع عن الوفاء المشار اليه قبل انقضاء مدة تقديم الشيك واذا قدم الشيك في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له والا اصبح الحامل مهما لا يحق له الرجوع الا علي الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء الي المسحوب عليه .

الرجوع علي الملتزمين في الشيك في حالة الامتناع عن الوفاء:

أ- طريقة الرجوع:

- ❖ عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، كان للحامل الرجوع علي الملتزمين بموجب الشيك، فإذا كان الشيك لحامله كان للحامل الرجوع علي الساحب وحده لأنه الوحيد الموقع علي الشيك اما اذا كان الشيك للأمر كان للحامل الرجوع علي الساحب وجميع المظهرين.
- ❖ يجوز ان يكتب في الشيك شرط (الرجوع بلا مصاريف) حيث يجوز اضافة شرط الرجوع بلا مصاريف الي الشيك وفي هذه الحالة يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج دون ان يترتب علي ذلك سقوط حقه في الرجوع علي الضامنين ودون ان يعتبر حاملا مهما .
- ❖ هذا الشرط لا يعفي الحامل من مطالبة المسحوب عليه في ميعاد تقديم الشيك للوفاء ولا من عمل الإخطارات اللازمة .
- ❖ اذا ادرج الساحب هذه الشرط فإنه يسري في مواجهة جميع الموقعين علي الشيك اما اذا ادرجه احد المظهرين فإنه لا يسري الا بالنسبة لمن وضعه فقط .
- ❖ الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله.
- ❖ رجوع الحامل علي الموقعين علي الشيك يكون اما من خلال رفع دعوي امام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون التجارة او من خلال نظام اوامر الاداء الذي اخذ به في قانون المرافعات المصري .
- ❖ فإذا اراد الحامل الرجوع علي الساحب كان له اختيار طريق استصدار امر اداء طبقا ولا يسقط حق الحامل في الرجوع علي الساحب لعدم وجود مقابل الوفاء لدي البنك المسحوب ولو لم يقيم بعمل احتجاج عدم الدفع او ما يقوم مقامه في الميعاد المحدد قانونا وذلك ما لم يثبت الساحب وجود مقابل الوفاء حتي تاريخ انقضاء ميعاد التقديم وان زوال المقابل لا يرجع الي سبب منه .
- ❖ اذا اراد الحامل الرجوع علي الضامنين الموقعين او علي الموقع جميعا اي الساحب والمظهرين فيكون عن طريق رفع دعوي الرجوع وفقا للقواعد العامة .
- ❖ المظهر او الضامن الاحتياطي، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفس ذلك نص قانون التجارة علي ان للحامل الرجوع علي هؤلاء الملتزمين منفردا او مجتمعين دون ان يلتزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم ويثبت هذا الحق لكل ملتزم في الشيك اذا دفع قيمته .

ب- موضوع الرجوع:

١- لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

- 🔴 اصل مبلغ الشيك غير المدفوع
- 🔴 العائد مسحوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي
- 🔴 مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها

٢- كما يحق لمن اوفي قيمة الشيك لمن رجع عليه مطالبة ضامنية بما يأتي :

- 🔴 المبلغ الذي اوفاه
- 🔴 عائد هذا المبلغ مسحوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي
- 🔴 المصاريف التي تحملها .

٣- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفاً للمطالبة بها ان يطالب في حالة قيامه بالوفاء بتسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومخالصة بما اوفاه ولكل مظهر اوفي قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له

حـ نوبية الحجز التحفظي:

🔴 يجوز لحامل الشيك توقع الحجز التحفظي علي منقولات المدني تطبيقاً للمادة ٥٢٥ من قانون التجارة حيث نصت علي انه لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه ان يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة علي اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطي

شروط نوبية الحجز التحفظي:

🔴 من هذا النص يتضح انه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي الشروط الآتية:

١ - الشرط الاول :- ان يكون طالب الحجز هو الحامل للشيك:

🔴 لا يقصد بذلك الحامل الأصلي للشيك فحسب، بل ايضاً كل ضامن دفع قيمة الشيك للحامل وثبت له بذلك حق الرجوع علي الملتزمين الآخرين كذلك قد يكون الحامل مظهراً اليه تظهيراً توكليلاً لتحصيل قيمته.

٢ - الشرط الثاني :- ان يكون الدين ثابتاً في شيك صحيح شكلاً:

🔴 يجب ان يكون الشيك صحيحاً بأن يكون متضمناً جميع البيانات الإلزامية التي نص قانون التجارة فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي اذا كان الشيك معيباً ويعتبر الشيك الصحيح عملاً تجارياً مطلقاً.

٣ - الشرط الثالث :- القيام بإجراء احتجاج عدم الوفاء:

🔴 يجب ان يكون الشيك قد حرر عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه ويلزم تحرير الاحتجاج لتوقيع الحجز التحفظي ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف ويتحمل الحامل في هذه الحالة مصاريف الاحتجاج وحده ويجب ان يتم هذا الاحتجاج في الميعاد القانوني ما لم يكن المدين بالشيك المطالب الرجوع عليه وحجز منقولاته هو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او المسحوب عليه الذي قام باعتماد الشيك حيث يكفي عمل احتجاج عدم الوفاء ولو بعد الميعاد القانوني.

٤ - الشرط الرابع :- ان يكون المحجوز عليه ملتزماً بالوفاء بقيمة الشيك:

🔴 يجب ان يكون المحجوز عليه مديناً في الشيك اي احد الموقعين عليه والملتزم التزاماً صرفياً فيه كالساحب او احد المظهرين او الضامن الاحتياطي وبالتالي لا يكون الحجز اذا وقع علي منقولات شخص غير المدين بالشيك مثل البنك المسحوب عليه الذي لم يوقع علي الشيك بالاعتماد او البنك الذي لم يحصل علي مقابل الوفاء.

٥ - الشرط الخامس :- ان تتبع في اجراءات الحجز احكام قانون المرافعات:

🔴 يجب ان تتبع اجراءات توقيع الحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات فيجب علي الدائن ان يحصل علي اذن من قاضي التنفيذ لتوقيع الحجز طبقاً للمادة ٣١٩ مرافعات غير انه يجب ملاحظة ان نص المادة ٢١٠ مرافعات تعقد تقرير الحجز التحفظي لاختصاص القاضي المختص باستصدار امر الاداء في الاحوال التي يجب علي الحامل فيها ان يسلك هذا الطريق كما هو الحال في الرجوع علي الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او الضامن الاحتياطي.

القوة القاهرة واثرها علي احكام الوفاء بقيمة الشيك:

- ❖ " اذا حالت قوة القاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
- ❖ قد قرر المشرع ان وجود ظرف القوة القاهرة لا يجعل الحامل عندئذ مهملاً لأنه لا دخل لإرادته في توافر هذا الظرف ومما لا شك فيه ان تقدير توافر القوة القاهرة مسألة موضوعية يترك تقديرها للقاضي الذي يحكم الموضوع لذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه.
- ❖ اذا توافرت القوة القاهرة علي الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك وتسلسل الاخطارات .
- ❖ اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة الي تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا اذا كان حق الرجوع موقوفاً بموجب القانون لمدة اطول.

المبحث الثالث

التحريف في متن الشيك ومسؤولية البنك المسحوب عليه

- ❖ اذا وقع تحريف في متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي مما لا شك فيه ان المشرع قرر ذلك للحفاظ علي الشيك باعتباره ورقة تجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت به ومضمونه دون الاعتماد علي عوامل خارجية اخري حيث ان متلقي الشيك يكتفي بما هو مدون به من بيانات دون البحث عن اصل او اساس العلاقات السابقة عليه تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
- ❖ البنك المسحوب عليه يحتفظ لديه بنموذج لتوقيع الساحب يجب عليه قبل صرف الشيك مضاهها هذا النموذج علي التوقيع الموجود لديه علي الشيك ولا يوجد ما هو افضل من البنك وموظفيه للتحقيق من تزوير توقيع الساحب او التحريف في بيانات الشيك والبنك المسحوب عليه يكون مسئولاً عن ذلك علي اساس تحمل التبعة لذلك نصت المادة ١/٥٢٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي ان يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب علي وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يكن نسبة اي خطأ الي الساحب وكل شرط علي خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
- ❖ تبعاً لذلك يسأل البنك المسحوب عليه دائماً عن الوفاء بشيك مزور او التحريف علي اساس تحمل مخاطر المهنة وهذه المخاطر مهما بلغت اعبائها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود علي البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدي جمهور المتعاملين ولكن تحمل البنك المسحوب عليه تبعه المخاطر هذه مشروط بعدم وقوع خطأ من جانب الساحب الوارد اسمه بالشيك والا تحمل هذا الساحب تبعه خطئه.
- ❖ يعتبر من اخطاء الساحب التي يسأل عنها عدم بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة علي دفتر الشيكات المسلم اليه من البنك المسحوب عليه .
- ❖ اذا كان البنك المسحوب عليه يلتزم بالتحقق من صحة توقيع الساحب والا كان مسئولاً عن الوفاء بقيمة الشيك رغم تزوير توقيع الساحب ولو كان التزوير متقناً الا ان البنك لا يلتزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها .
- ❖ يعتبر القبول الصريح او الضمني من العميل لكشف الحساب الدوري الذي يرسله اليه البنك ابراءاً لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او الإضافة من مبالغ الشيكات ويكون قبولاً ضمناً علي وجه الخصوص عدم اعتراض العميل علي كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الي العميل الشيكات التي دفعها خصماً من الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه

الفصل الخامس: انقضاء الالتزام في الشيك (السقوط او التقادم) المبحث الأول: السقوط

حالات السقوط:

المشرع لم يفرض علي حامل الشيك الا واجبا واحدا للحفاظ علي حقه في الرجوع علي الساحب والملتزمين الموقعين في الشيك هذا الواجب هو تقديم الشيك للوفاء بقيمته في المواعيد المحددة فإذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته عليه اثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج او ما يقوم مقامه. بالرجوع لأحكام المادة ٥٠٤ تجاري نجد انها تقرر بأن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر والشيك المسحوب في اي بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر ويبدأ سريان هذه المواعيد من التاريخ المبين في الشيك ويعتبر تقديم الشيك الي احدي غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.

وبالتالي يعتبر الحامل مهملًا ويتعرض حقه للسقوط :

١. اذا اهمل في تقديم الشيك خلال المواعيد المحددة
٢. اذا قدم الشيك خلال المواعيد ولم يقيم بإثبات الامتناع عن الدفع

نطاق السقوط:

السقوط لا يتعلق الا بدعوي الصرف فاذا كان للحامل قبل احد الملتزمين رجوع يقوم علي اساس علاقات قانونية اخري غير العلاقات المصرفية فلا يسقط هذا الرجوع بعدم اتباع الاجراءات التي قررها قانون الصرف وايضا نجد ان السقوط لا يتعلق بحق الحامل في الرجوع علي المدين الاصلي حيث لا يسقط هذا الرجوع الا بالتقادم الصرفي.

في ذلك تقول محكمة النقض « ان تحرير الاحتجاج شرط لرجوع الحامل علي المظهرين والضامن الاحتياطي وليس شرطا لمطالبة المدين الاصلي الملتزم بالاداء في ميعاد الاستحقاق **علة ذلك** ان المشرع جعل السقوط جزاء الاهمال في اتخاذ اجراءات تحرير الاحتجاج او الإخلال بمواعيده لا يفيد منه الا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي.

يختلف اثر السقوط حسب علاقة الحامل بالساحب او المظهرين او المسحوب عليه وذلك علي التفصيل التالي:

اولا: علاقة الحامل بالساحب:

لا يجوز للساحب التمسك بسقوط حق الحامل المهمل الا اذا اثبت انه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وظل موجودا لديه حتي انقضاء ميعاد تقديم الشيك اما اذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء او قدمه واسترده قبل ميعاد تقديم الشيك فلا يجوز له الاحتجاج علي الحامل بالسقوط للإهمال حتي لا يثري علي حساب الغير .

وليس لحامل الشيك في هذه لحالة الا الرجوع علي البنك المسحوب عليه بدعوي ملكية مقابل الوفاء التي لا تسقط الا بالتقادم العادي طبقا لأحكام القانون المدني او التجاري طبقا لطبيعة العملية وذلك سواء كان الحامل مهملًا او غير مهمل.

ثانيا: علاقة الحامل بالمظهرين:

اذا اهمل الحامل ولم يقدم الشيك للوفاء خلال المواعيد المذكورة في المادة ٥٠٤ تجاري او اذا قدمه خلال هذه المواعيد ولم يقيم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في حالة الامتناع عن الوفاء فإنه يجوز للمظهرين التمسك بسقوط حق الحامل في الرجوع عليهم للإهمال.

والجدير بالذكر ان الشيك اذا كان احامه ولا يحمل شرط الامر او الاذن فإنه لا رجوع للحامل الا علي الساحب لان الشيك لا يحمل الا توقيع الساحب.

ثالثا: علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه:

لحامل المهمل مطالبة المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك اذا كان مقابل الوفاء موجودا لديه لان الحامل يملكه اي ان المسحوب عليه يجب ان يدفع قيمة الشيك طالما كان الرصيد موجودا حتي بعد انتهاء ميعاد التقديم.

من ذلك يتضح ان للحامل الرجوع علي البنك المسحوب عليه بدعوي ملكية مقابل الوفاء سواء كان الحامل مهملًا او غير مهمل.

خصائص السقوط:

- ١- انه متعلق بدعوي الصرف فقط دون غيرها من الدعاوي التي قد تكون للحامل قبل احد الملتزمين بالشيك.
- ٢- يجوز التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل ولو كان قاصرا.
- ٣- يجوز التمسك بالسقوط ولو ولم يترتب علي اهمال الحامل ضرر بمن يحتج عليه.
- ٤- لا يعتبر السقوط من النظام العام فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها كما يجوز لصاحب المصلحة التنازل عنه صراحة او ضمنا وسواء وقع هذا التنازل بعد وقوع الإهمال او قبل وقوعه.
- ٥- التمسك بالسقوط حق شخصي فإذا تنازل احد المظهرين عن التمسك بالسقوط فإن هذا لا يمنع الاخرين من التمسك به تجاه الحامل كما ان المظهر الذي يوفي قيمة الشيك دون ان يحتج بالسقوط لا يجوز له الرجوع علي المظهرين السابقين.
- ٦- يجوز التمسك بالسقوط في اي حالة كانت عليها الدعوي

المبحث الثاني : التقادم

📌 **المقصود بالتقادم** ← عبارة عن وسيلة لانقضاء الالتزام في حالة اتخاذ الدائن والمدين موقفا سلبيا خلال مدة معينة ويتمثل موقف الدائن في تقاعسه عن المطالبة بحقوقه وموقف المدين يتمثل في عدم الوفاء.

📌 يرتبط نظام التقادم باستقرار المعاملات لان السماح للدائن بمطالبة مدينة مهما طال الزمن يؤدي الي اضطراب وتزعزع المعاملات كما ان اطالة المدة يؤدي الي صعوبة اثبات الحقوق.

📌 القاعدة ان الالتزامات تتقادم بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد نص خاص في القانون يقرر مدة اخري للتقادم

📌 قد اورد قانون التجارة نصوصا خاصا يقرر مدة اخري للتقادم فيما يتعلق بدعاوي الشركات التجارية حيث جعل مدة التقادم خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الشركة اذا كانت مشهورة او من تاريخ اعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة وقد قرر قانون التجارة مدد اخري خاصة للتقادم مختلفة عن القاعدة العامة الواردة في القانون المدني من هذه النصوص الخاصة ما يتعلق منها بالأوراق التجارية.

📌 قد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م علي تقادم خاص بالشيك في المادة ٥٣١ تجاري.

📌 الحقيقة انه لا يوجد تعارض بين التقادم الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل حيث ان التقادم لا يستفيد منه الا الملتزمون الذين لا يجوز لهم التمسك بإهمال الحامل مثل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء كما يستفيد الملتزمون الموقعون علي الشيك من التقادم في الحالة التي لا يكون من حقهم التمسك بالسقوط لان الحامل قام بالإجراءات التي قررها قانون الصرف في مواعيدها او لان الشيك اشتمل علي شرط الرجوع بلا مصاريف.

📌 قد اسس المشرع التجاري التقادم الصرفي علي قرينة الوفاء حيث ان سكوت الدائن المدة المذكورة في المادة ٥٣١ تجاري دون ان يطالب بحقه يعد قرينة علي انه قد استوفي حقه وذلك حتي تستقر المراكز القانونية.

المطلب الاول : احكام التقادم الصرفي للشيك

اولا: مدة التقادم:

لم يضع المشرع ميعدا واحد لتقادم الدعاوي الناشئة عن الشيك وانما وضع مواعيدا مختلفة تختلف تبعا لما اذا كان هذه الدعوي هي دعوي رجوع حامل علي الساحب او المظهرين او دعوي رجوع حامل علي المسحوب عليه او دعوي رجوع الملتزمين بعضهم علي البعض الاخر.

١-دعاوي رجوع حامل علي الساحب والمظهرين:

تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك علي الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعد تقديمه

٢-دعاوي حامل الشيك علي المسحوب عليه:

تتقادم دعاوي حامل الشيك علي المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعد تقديمه

٣-دعاوي رجوع الملتزمين بعضهم علي البعض الاخر:

تتقادم دعاوي رجوع الملتزمين بعضهم علي البعض الاخر بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفي فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبتة قضائيا بالوفاء

ثانيا: انقطاع التقادم:

ينطبق علي التقادم الصرفي للشيك اسباب الانقطاع العامة المنصوص عليها في القانون المدني وهي المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي الي محكمة غير مختصة ، والتنبيه ، والحجز ، والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدي الدعاوي واقرار المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا.

يترتب علي انقطاع التقادم زوال المدة السابقة علي قيام سبب الانقطاع وسريان مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء الاثر المترتب علي سبب الانقطاع.

قد قرر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأنه "اذا اقيمت الدعوي فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعاوي اي انه اذا انقطعت مدة التقادم برفع دعوي المطالبة فلا تسري مدد التقادم السابق الإشارة اليها في المادة ٥٣١ الا من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعوي.

قد جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ واورد استثنائيين لا يسري عليهما التقادم الصرفي للشيك وانما تكون مدة التقادم الجديد خمسة عشر سنة وفقا للقواعد العامة

وهما حالة صدور حكم بالدين وحالة الاقرار بالدين بسند منفرد وبيانهما كما يلي:

١- صدور حكم بالدين:

اذا كان سبب الانقطاع صدور حكم بالدين وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به فإن الصلة بين الدين والورقة التجارية تنقطع ويصبح الدين مستندا الي الحكم ذاته فلا يتقادم الا بخمسة عشرة سنة.

٢- الاقرار بالدين بسند منفرد:

اذا تم الاقرار بالدين بمقتضي سند منفرد مستقل عن الورقة التجارية يتحول التقادم الصرفي بمقتضي هذا الاقرار في السند المنفرد الي تقادم عادي مدته خمسة عشر سنة من تاريخ الاقرار في السند المنفرد ويشترط في هذا السند ان يكون كاملا ومستقلا عن الورقة التجارية وكافيه لتحديد عناصر الالتزام بحيث لا يحتاج في تحديده الي الرجوع للورقة التجارية وان هذا السند لاحقا لميعاد الاستحقاق حيث يصبح الدين مستحق الاداء.

ثالثا : وقف التقادم

❁ لم يذكر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الأسباب التي تؤدي الي وقف التقادم الصرفي لذلك تطبق القواعد العامة حيث يوقف التقادم اذا وجد مانع يتعذر معه علي الدائن ان يطالب بحقه كالحرب مثلا او صلة الزوجية بين الدائن والمدين.

❁ يترتب علي الوقف عدم حساب فترته ضمن مدة التقادم ولكن تحسب فقط المدة السابقة علي سبب الوقف والمدة التالية له.

❁ اذا انقطع التقادم او وقف بالنسبة لأحد الملتزمين في الشيك فلا يترتب علي ذلك انقطاعه او وقفه بالنسبة الي الملتزمين الآخرين تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات وفي ذلك تنص المادة ٤٦٧ من قانون التجارة علي انه "لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوي اثر الا بالنسبة الي من اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم ورغم ان هذه المادة واردة في احكام الكمبيالة الا انها تنطبق علي الشيك ايضا طالما انها لا تتعارض مع طبيعته.

المطلب الثاني : اثار التقادم الصرفي للشيك

الدفع بالتقادم :

❁ يتم التمسك من قبل المدين في صورة دفع يتمسك به المدين عند رفع الدعوي للمطالبة بقيمة الشيك فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء علي طلب المدين او طلب دائنية او اي شخص له مصلحة في التمسك بهذا الدفع.

❁ يجوز التمسك بالتقادم في اي حالة كانت عليها الدعوي ولو امام المحكمة الاستئنافية ويجوز للمدين التنازل عن التمسك بالدفع بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه ويجوز التنازل ولو ضمينا اما قبل ثبوت الحق فيه فلا يجوز ذلك لذلك يجب فيمن يصدر منه هذا التنازل توافر اهلية التبرع لان هذا التنازل يعتبر من قبل التبرع.

❁ يترتب علي الدفع انقضاء الالتزام الصرفي ولكن يبقي في ذمة المدين التزام طبيعي فإذا قام المدين بالوفاء اختيارا رغم انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم فإنه لا يستطيع ان يسترد ما اداه ولا يترتب علي انقضاء الدين الصرفي بالتقادم انقضاء الدين الاصلي في العلاقة المباشرة بين الملتزمين بالشيك ما لم يكن انقض هو الآخر بسبب من اسباب الانقضاء وفقا للقواعد العامة.

❁ لكن يجب ملاحظة ان انقضاء الدين الصرفي بالتقادم بالنسبة للملتزم المدعي عليه لا يترتب عليه انقضاؤه بالنسبة الي الملتزمين الآخرين المتضامين معه الذي لم توجه اليهم الدعوي فيجوز للحامل مقاضاه هؤلاء الملتزمين علي ان يكون لكل منهم الدفع بالتقادم ان كانت مدته قد اكتملت بالنسبة اليه.

قرينة الوفاء:

❁ تقادم الالتزام الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء حيث افترض المشرع ان سكوت الحامل مدة التقادم قرينة علي انه استوفي دينه حيث انه من غير المألوف في المعاملات التجارية ان يتراخى الدائن في المطالبة بحقه مدة التقادم الا اذا كان قد استوفاه لذلك لا يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة الدائن اذا صدر منه ما يفيد عدم قيامه بالوفاء بقيمة الدين.

الفصل السادس: تجريم الشيك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م

المبحث الأول : الأساس القانوني لجرائم الشيك

الاساس القانوني لجرائم الشيك وعليه التجريم:

نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات علي انه " يحكم بهذه العقوبات علي كل من اعطي بسوء نية شيكا لا يقبله رصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيداقل من قيمة الشيك او سحبه بعد اعطاء الشيك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك او امر المسحوب عليه بعدم الدفع وقد ادخل هذا النص في قانون العقوبات سنة ١٩٣٨م بموجب القانون رقم ٥٨ حيث انه لم يكن له وجود في المجموعة التجارية الصادرة سنة ١٨٨٣م ولا قانون سنة ١٩٠٤م حيث انه لم تكن تقوم جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ما لم تكن هناك طرق احتيالية وهذا ما يفسر الحاق هذه الجريمة بجريمة النصب لعله من التجريم هي حماية الشيك دون غيره من الاوراق التجارية.

مما لا شك فيه ان تدخل المشرع بالنص علي هذه الجرائم انما كان بهدف اعادة هبة الشيك واقرار وظيفته الت خلق من اجلها وهي اعتباره اداة وفاء فحسب بعد ان جري العمل علي اعتباره اداة ائتمان فالحقيقة ان الشيك اداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات التجارية لذلك كان تدخل المشرع بإقرار عقوبات توقع علي جميع اطراف الشيك وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وذلك حماية لحرية التعامل بالشيك .

الحد من العقاب الجنائي في قانون الشيك الفرنسي :

كان قانون الشيك الفرنسي الصادر سنة ١٨٦٥ يعاقب علي اصدار شيك بدون رصيد بإعتباره جريمة نصب وكان النموذج القانوني لهذه الجريمة لا ينطبق في اغلب الاحوال حيث كان يشترط لوقوع الجريمة توافر حالة الغش وهو الشرط الذي يجب توافره في جريمة النصب .

لذلك صدر قانون ١٢ اغسطس ١٩١٧م ونص علي جريمة اصدار شيك بدون رصيد بإعتبارها جريمة خاصة مستقلة فقرر لها عقوبة الحبس من شهرين الي سنتين والغرامة

تبعاً لهذا التطور في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد فقد صدر قانون الشيك رقم ١٣٢٨-٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١م حيث الغي الجزاء الجنائي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد فقرر لها جزاءات مصرفية وجزاء مالية ذات طبيعة مدنية وضريبية ولكن يجب ملاحظة انه اذا صاحب اصدار شيك بدون رصيد استعمال طرق احتيالية كان الفعل معاقبا عليه باعتباره جريمة نصب.

من هذه الجزاءات المالية ما نصت عليه المادة (٧) من قانون ٣٠ ديسمبر ١٩٩١م والمادة (١٠) من المرسوم رقم ٤٥٦/٩٢ الصادر في ٢٢ مايو ١٩٩٢م حيث يتضح ان قيمة الجزاء المالي الذي يتحمله الساحب في حالة اصدار شيك بدون رصيد هو ١٢٠ فرنك لك ١٠٠٠ فرنك هذا الجزاء المالي يدفع للخزانة العامة الفرنسية ويضاعف الجزاء المالي في حالة تكرار الساحب ارتكاب هذا الفعل لعدد ثلاث شيكات غير شيك المساءلة ويعفي الساحب من الغرامة المشار اليها اذا ثبت عدم ارتكاب الشخص لهذه الجريمة خلال السنة السابقة بشرط ان يوفي قيمة الشيك محل الفعل المخالف خلال شهر من تاريخ الإخطار المرسل من البنك المسحوب عليه الي الساحب بعدم وجود رصيد.

يلتزم البنك طبقا للمادة ٦ من قانون ٣٠ ديسمبر ١٩٩١م والمواد ٦ الي ١٥ من المرسوم بالقانون الصادر في ٢٢ مايو ١٩٩٢م بأن يصدر امره للساحب برد جميع دفاتر الشيكات طرفه سواء المسلمة اليه منه او من بنوك اخري ويلتزم البنك بإعلامه ذلك لجميع وكلاء الساحب بالإضافة الي اصداره امر بمنع الساحب من اصدار شيكات اخري .

- ❖ إذا لم يقيم البنك بالالتزامات المشار إليها تعرض لجزاء مالي قدره ٢٠٠٠ فرنك الس ٨٠٠٠٠ فرنك بالإضافة الي تحمل قيمة اي شيك يسحب من عميله واذا قام البنك بالوفاء فإنه يحل محل الحامل في حقوقه.
- ❖ كما يلتزم بنك الساحب الذي اصدر شيكا بدون رصيد بإخطار جميع البنوك التي للساحب حسابات فيها بقرار منعه من اصدار شيكات واذا امتنع الساحب عن رد جميع دفاتر الشيكات واصدر شيكات رغم المنع المصرفي تعرض الي جزاء جنائي وهو الحبس من سنة الي خمس سنوات والغرامة من ٣٦٠٠ فرنك الي ٢.٥ مليون فرنك او احدي هاتين العقوبتين.
- ❖ بهذا الاتجاه التشريعي الفرنسي يتضح ان الجرائم الناشئة عن الشيك منحصرة في جنحة اصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة الحظر البنكي او عند مخالفة المنع القضائي وجنحة سحب او اغلاق الرصيد بقصد الاعتداء علي حقوق الغير او قبول او تحويل شيك ممن يعلم انه بدون رصيد او المعارضة في دفع الشيك بقصد الاعتداء علي حقوق الغير.
- ❖ فيما عدا هذه الجرائم التي ابقى عليها قانون الشيك الفرنسي الصادر سنة ١٩٩١م تطبق الجزاءات المالية والمصرفية التي سبق ذكره.

المبحث الثاني

المشكلات العملية التي اثارها تطبيق قانون الشيك عند صدوره

- ❖ اثيرت مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بعد صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بخصوص احكام الشيك وتطبيقها علي الشيكات الخطية التي لم يعد يعترف بها قانون التجارة لذلك تناقضت واختلفت اتجاهات احكام محكمة النقض في هذا الخصوص.
- ❖ اتجاهات محكمة النقض في مدي تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في خصوص جرائم الشيك بعد صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م

الاتجاه الاول:

- ❖ تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم اعتبارا من يوم صدور قانون التجارة في ١٧ مايو سنة ١٩٩٩م وليس من يوم نفاذ وسريان احكامه بالنسبة للشيك في اول اكتوبر عام ٢٠٠٠ م .
- ❖ وقد صدر حكمان من محكمة النقض مؤيدان لهذا الاتجاه .
- ❖ **الاول** قضت المحكمة بناء علي هذا الحكم بالبراءة لمصدر شيك خطي بدون رصيد تأسيسا علي قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم اعتبارا من تاريخ صدور قانون التجارة تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات والمادتين ٦٦، ١٨٧ من الدستور المصري.

الوقائع

- ❖ اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح قويسنا (قيدت بجدولها برقم ١٦٢٠ لسنة ١٩٩٢) ضد الطاعن بوصفه انه في يوم ٢١ من اكتوبر ١٩٩١م بدائرة قويسنا محافظة المنوفية اعطاها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين رقمي ١/٣٣٦، ٣٣٧ من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت.
- ❖ المحكمة المذكورة قضت حضوريا في ٢٦ من ابريل سنة ١٩٩٢م عملا بمادتي الاتهام بحبسة ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والغرامة بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيها علي سبيل التعويض المؤقت استأنف وقيد استئنافه برقم ٨٥٥٢ لسنة ١٩٩٢م ومحكمة شبين الكوم الابتدائية- بهيئة استئنافية- نصت غيابيا في ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٢م بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف عارضه وقضي في معارضته في ٢٥ من يناير سنة ١٩٩٣ م بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأيد الحكم المعارض فيه فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٣ م وقدمت اسباب الطعن في ٢٧ الشهر ذاته وبجلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٩٦م وما تلاها من جلسات اليوم وفيها قررت احواله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداول (انه لما كان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م سالف الإشارة قد نص في المادة ٤٧٥ منه علي ان الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه الا علي بنك والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا ومفاد النص سالف الإشارة ان القانون الجديد قد الغي ما كان يعتد به العرف من قبل من جواز ان يسحب الشيك علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لما كان ذلك وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة في المادة ٦٦، ١٨٧ مفادها عدم رجعية نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بقولها: " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها الا ان المستفاد- بطريق مفهوم المخالفة- من هذا النص الدستوري ان القوانين الجنائية الأصلح للمتهم تسري علي الماضي بل ان قاعدة عدم الرجعية للقوانين الجنائية تكملها وتقوم الي جانبها قاعدة اخري هي قاعدة القانون الأصلح للمتهم، وان القاعدة الأخيرة التي يركز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة ٤١ من الدستور التي تقرر ان الحرية الشخصية حق طبيعي وانها مصونة لا تمس وعلي تقرير ان هذه الرجعية ضرورة حتمية يقتضيها الحرية الفردية وهو ما سجلته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في قولها وعلي هذا اذا صدر بعد الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

ومفاد ما سلف ايراده ان قاعدة القانون اصلح للمتهم وان لم ينص عليها الدستور صراحة الا انها تركز علي دعامة دستورية لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات يجب ان تنزل عند احكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام احكام الدستور واهدار ما سواها وكان من المقرر ايضا ان القانون اصلح للمتهم والذي ينشئ له من الناحية الموضوعية مركزا او وضعه يكون اصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة اليه او يلغي بعض عقوباتها او يخففها او يقرر وجهها للإعفاء من المسؤولية الجنائية أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر في فعل المتهم او يتطلب للعقاب شرطا او عنصرا لم يكن لازما في القانون القديم اي ان القانون اصلح هو الذي يوجب من حيث التجريم او العقاب مركزا او وضعه اصلح للمتهم علي اي وجه من الوجوه فيكون من حق المتهم في هذه الحالات ان يستفد لصالحه من ذلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها لما كان ما تقدم وكان قانون التجارة قد اخرج الصك المسحوب في صورة شيك والمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه من عداد الشيكات لما كان ذلك وكان شرط العقاب في قانون التجارة الجديد علي اعطاء شيك بدون رصيد وهو ان تتوافر في الصك المقومات الاساسية التي وضعها قانون التجارة فإن لازم ذلك ان كل محرر لا تتوافر فيه شروط اعتباره شيكا بهذا المفهوم تنحصر عنه الحماية الجنائية لما كان ما تقدم وكان البين من المفردات المضمومة ان الشيك محل الدعوي الراهنة غير محرر علي نماذج البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م يكون هو الأصلح بالنسبة للطاعن في هذا المجال لما كان ذلك وكان الدستور في المادة ١٨٨ منه قد نص علي نشر القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ألا اذا حددت لذلك ميعاد اخر وسواء كان سريان القانون الجديد بعد شهر من اليوم التالي لنشره او اذا اضيفت نفاذ القانون الي اجل اخر فإن ذلك لا يغير مما هو مقرر من ان القانون اصلح للمتهم من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به وذلك اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات اذ يكفي لكي يستفيد المتهم من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م اصلح له ان يكون هذا القانون قد صدر ولو كان موعدا سريانه لم يحن بعد اذا لا يسوغ القول باتصال التأثيم طوال الفترة من صدور القانون وتاريخ العمل به .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوي المدنية والزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

تعليقا علي الحكم:

الواضح من حكم النقض المشار اليه ان قاعدة تطبيق القانون اصلح للمتهم تعني تطبيقه فور صدوره ولو كان تاريخ نفاذه لم يحل بعد وهي قاعدة اصولية لها جذور دستورية علي ذات المستوي والسمو لقاعدة عدم رجعية القوانين في المواد الجنائية وان كل من القاعدتين يكمل بعضهما بعضا.

❖ عدم تطبيق احكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م باثر رجعي حتي ولو كان اصلح للمتهم علي الشيكات التي وقعت طبقا لنص المادة ٣٣٧ عقوبات.

❖ قد تبين هذا الاتجاه قضاء محكمة النقض في حكم نقض في الشيك الصادر يوم الاثنين الموافق ١٤ من يونيه ١٩٩٩م -وسوف نقوم بسرد وقائع وحيثيات هذا الحكم واسانيد القانونية كما جاء بالحكم.

الوقائع

❖ اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ٢٢٠٤ لسنة ١٩٩٢م سمسطا بانه في يوم ١٢ من ابريل سنة ١٩٩٢م بدائرة مركز سمسطا محافظة بني سويف اعطي بسوء نية لبنك التنمية شيكا لا يقبله رصيد قائم وقابل للساحب وطلبت عقابه بالمادتين ٣٣٧، ٣٣٦ من قانون العقوبات ومحكمة جنح سمسطا قضت غيايبا في ٢١ من مارس ١٩٩٣م عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عارض وقضي في معارضته في ٢٠ من يونيه سنة ١٩٩٣م باعتبار المعارضة كأن لم تكن استئناف وقيد استئنافه برقم ٨٤٢٦ لسنة ١٩٩٣م ومحكمة بني سويف الابتدائية مأمورية بالاستئنافية قضت غيايبا في ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٩٣م بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته في ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٩٣م باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

❖ فطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٤ من يناير سنة ١٩٩٤م وقدمت اسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من المحامي وبجلستي ٦ من يناير سنة ١٩٩٧م ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها احالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المدكمة

❖ بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافقة وبعد المداولة.. ولما كان ذلك مؤدي ما اورده القانون في مواد اصدارها علي النحو المتقدم ان المشرع قدر انه يتعين ان تكون هناك فترة انتقالية بين صدور القانون وتطبيق احكامه فيما يتعلق بالشيك افرد لها نظاما تشريعييا خاصا يلتزم اتباعه خلال تلك الفترة الانتقالية حرصا علي استقرار المعاملات التجارية وحماية للاقتصاد القومي لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاصل انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتل وانه متي كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل ايا كان الباعث عن ذلك ولا الخروج عن النص متي كان واضحا جل المعني قاطعا في الدلالة علي المراد منه اذ انه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه وكأن من المقرر- ايضا - ان مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب ان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم اي ان تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ احكامه وهذا ما قننته الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي ان يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها اما ما اوردته الفقرة الثانية من المادة المشار اليها من انه وقع هذا اذا صدر بعد وقوع وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فهو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت الي تقريره لان المرجع في نص التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه ولما كان هذا الاستثناء لا يتعلق بقاعدة دستورية وان كان يبرر صالح المتهم لعوامل انسانية الا انه يجب في هذه الحالة عدم المغالاة في ضمان حقوق المتهم بأن يتعين تحقيق التوازن بينها وبين مصلحة المجتمع.

ان الشارع او القانون وحده هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب باعتباره تعبيراً عن الإرادة العامة من السلطة التشريعية وهي وحدها التي تستطيع تقدير الاضطراب الاجتماعي الذي تحدثه الافعال وتحديد العقوبات التي توقع علي مرتكبيها ويترتب علي ذلك كله ان القانون الذي يقرر الجرائم والعقاب يطبق من لحظة صدوره حتي لحظة الغائه علي كافة الافعال او الوقائع التي ترتكب بعد صدوره دون ان يكون له سلطة علي تلك التي ارتكبت قبل ذلك سواء بتجريمه فعلاً مباحاً او تغليظ العقوبة علي فعل معاقب عليه وذلك استناداً لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية المقرر في الدستور كما يترتب علي ذلك ايضاً انه يجوز للمشرع عند اصداره نصوص جديدة اصلح للمتهم ان ينص علي استمرار سريان النصوص القديمة في التطبيق علي الجرائم المرتكبة في ظلها حتي ولو كانت المحاكمة قد تمت بعد سريان القواعد الجديدة الأصلح للمتهم.

إرادة المشرع يجب ان ترجح طالما عبر عنها بوضوح وهو ما لا يخالف او يتعارض مع احكام الدستور علي النحو انف البيان كما كان ما تقدم وكانت المادتان الاولى والثالثة من مواد اصدار قانون التجارة الجديد قد حددتا الغاء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات والعمل بأحكام الشيك الواردة اعتباراً من اول اكتوبر سنة ٢٠٠٠م وان يطبق علي الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الاحكام القانونية المعمول بها في تاريخ اصداره اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل اول اكتوبر سنة ٢٠٠١م وكان عبارات الشارع في هاتين المادتين واضحة المعني لا غموض فيها ولا مخالفة فيها لأحكام الدستور ومراد الشارع لا يحتمل التأويل ولا يمكن ان ينصرف الي غير المعني الذي يقصده الشارع في ان الشيكات التي صدرت قبل اول اكتوبر سنة ٢٠٠٠م تظل خاضعة لأحكام المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات وكذلك الشيكات الصادرة قبل التاريخ المشار اليه وتلك التي ثبت تاريخها قبل اول اكتوبر سنة ٢٠٠١م تظل هي الاخرى محكومة فيما يتعلق بالاعتداد بها كشيك بالقواعد السارية وقت اصدارها فلا تسري عليها قاعدة القانون الأصلح للمتهم- وهذا هو المعني الذي قصدت اليه المادتان المشار وهو المستفاد من سياق نصيهما وعبارتهما وهو الذي كان قائماً في ذهن الشارع حين اجري هذا التعديل وما يجب ان يجري عليه العمل باعتباره التفسير الصحيح للقانون- وهو ما اكدته المناقشات التي جرت في هذا الصدد في مجلس الشعب قبل صدور القانون ولا يقدر في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الاولى من مواد الإصدار بإلغاء كل حكم يتعارض مع احكامه اذ ان بالمادتين الاولى والثالث من مواد اصداره فالغي تطبيق اي قانون اخر في شأنها اعتباراً من ذلك التاريخ ومن ثم فإن جرائم اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي وقعت طبقاً لنص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تظل قائمة خاضعة لأحكامها حتي بعد صدور قانون التجارة الجديد ولا يمتد اليها احكام هذا القانون بأثر رجعي حتي ولو كان اصلح للمتهم لتخلف مناه اعمال هذا الاثر علي ما سلف بيانه.

انتهي حكم النقض المشار اليه بصدد موضوع الاتهام الي انه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان واقعات الدعوي بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ومؤداة ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق الطاعن كما اغفل بحث امر الرصيد في المصرف وجوداً وعدمه واستيفاء شرائطه واطلق القل بثبوت التهمة في عبارات مجهولة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة الي بحث الوجه الاخر من الطعن.

الانجاء الثالث: رأي الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض:

اعتبار الشيكات المستوفاة لصفة الشيك طبقاً لمواد قانون التجارة الجديد خاضعة للتجريم سواء اكانت هذه الشيكات خطية ام بنكية واعتبار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م اصلح للمتهم فيما يتعلق بالعقوبات التخيرية والتصالح.

قد حسمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الخلاف بين دوائر النقض بخصوص الشيك.

سوف نقوم بسرد وقائع وحجثيات هذا الحكم واسانيده القانونية كما جاء بالحكم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم السبت ٢٦ من ربيع الاول سنة ١٤٢٠هـ الموافق من يوليو سنة ١٩٩٩م.

اصدرت الحكم الاتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم ٩٠٩٨ لسنة ١٩٩٤م وبجدول المحكمة برقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ القضائية.

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ٢١٧٦ لسنة ١٩٩٢م دسوق بأنه في اليوم الاول من فبراير سنة ١٩٩٢م بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ اصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين ٣٣٦، ٣٣٧ من قانون العقوبات ومحكمة جنح دسوق قضت غيابيا في ٢١ من يونيه سنة ١٩٩٢م عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم وكفالة عشرة جنيهاات لوقف التنفيذ.

عارض وقضي في معارضته في ١٨ يناير سنة ١٩٩٣م باعتبارها كأن لم تكن استأنف وقيد استئنافه برقم ١٤٠٥ لسنة ١٩٩٣م ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية- بهيئة استئنافية " قضت غيابيا في ١٨ من مارس عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته في ٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٣م بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المعارض فيه.

طعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٣م وقدمت اسباب العن في ٢٠ من يناير سنة ١٩٩٤م موقعا عليها من المحامي وبجلستي ١ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م ، ١٠ من فبراير سنة ١٩٩٨م نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة الاول من يوليو سنة ١٩٩٩م واذا رأت انه جدير بالذكر فقد أحالته للمرافعة في الجلسة العلنية بذات التاريخ وفيها أحالته الي الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيها.

الهيئة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانونا من حيث انه يبين من الاوراق ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضي غيابيا بحبسه شهرا ثم قضي باعتبار معارضته في هذا الحكم كأن لم تكن فاستأنف وقضي غيابيا بقبول استئنافه شكلا ورفضه موضوعا واذا عارض قضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض واذا رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قرره حكم سابق من ا الحماية الجنائية انحسرت عن الشيكات التي لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليها في المواد ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣ من قانون التجارة الصادر في ١٧ من مايو سنة ١٩٩٩م بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م منذ صدوره وذلك بحسبانه اصلح للمتهم فقد أحالت الطعن المائل للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائي ومن حيث انه علي اثر صدور قانون التجارة المشار اليه صدرت احكاما عدة عن بعض الدوائر الجنائية بهذه المحكمة كان لكل منها منحي في مدي اعتبار نصوص هذا القانون اصلح للمتهم في شأن العقوبة عن تلك المنصوص عليها في المواد ٣٣٧ من قانون العقوبات مما ادي علي تضاربها علي نحو يوجب علي الهيئة العامة حسمه وهو ما يتسع له سبب احالة الطعن اليها.

قد ذهب الحكم الصادر في الطعن رقم ٧٣٦٠ لسنة ٦٣ القضائية الي ان المادة ٤٧٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م نزع صفة الشيك عن الصك المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه وبذلك يكون القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م قد اخرج فعل اعطاء مثل هذا الصك بدون رصيد من دائرة التجريم ومن ثم فهو اصلح للمتهم من القانون الذي كان يجرم هذ الفعل وان ما تضمنه نص المادة الثالثة من مواد اصدار القانون المشار اليها من اعتداد بهذا الصك ومثله من الصكوك التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالمادة ٤٧٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م لا يصح ان يعطل تطبيق قاعدة سريان القانون الإصلح للمتهم بأثر رجعي اذ انها ترتكز علي دعامة دستوري لا يملك المشرع العادي مخالفتها بينما ذهب حكم اخر صدر في الطعن رقم ٣٣٠٥ لسنة ٦٤ القضائية الي ان قاعدة القانون الأصلح هذه هي من وضع المشرع العادي وله ان يرسم حدود تطبيقها او ان يعطله لمصلحه يقدرها وان نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من مواد اصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م وقد جعل لسريان المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات مدي من الزمان ممتدا حتي اول اكتوبر سنة ٢٠٠٠م فقد عطل بذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح علي جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد بحيث تنطبق المادة ٣٣٧ المشار اليها سواء في التجريم او العقوبة في حين بنيت احكام اخري علي ان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م وان ابقى علي التجريم الا انه في شأن العقوبة علي الجريمة المشار اليها انشأ للمتهم مركزا قانونيا اصلح عما نصت عليه المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حين اجاز الحكم علي مرتكبها بعقوبة الغرامة وحدها بعد ان كان معاقبا عليها بالحبس وجوبا كما رتب علي الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوي الجنائية مما يتعين معه تطبيق احكامه في هذا الصدد اعمالا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

حيث انه من المقرر ان مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب ان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من الجرائم

الي ان تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ احكامه وهذا هو ما قننته الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي ان يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وما اورده المادة المشار اليها في فقرتها الثانية من انه ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيها نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره انما هو **استثناء من الأصل العام** يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت الي تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادره فيه لما كان ذلك وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك ان المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد ان ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد القانونية السارية وقت اصدارها وعمد الي تأكيد سلامتها وصحتها فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار علي انه تطبق علي الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الاحكام القانونية المعمول بها في تاريخ اصداره اذا كان ثابت التاريخ قبل اول اكتوبر سنة ٢٠٠١م ومن ثم فإنه متي اعتبرت الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م

ذلك طبقا لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار فإن اعطاء شيك دون ان يكون له رصيد قائم للسحب يشكل فعلا مجرما ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم اذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة السابق ذكرها لما كان ما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائي الي العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن رقم ٧٣٦٠ لسنة ٦٣ القضائية.

وكان من المقرر ان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الي ان تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ احكامه الا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فإن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق علي الوقائع التي تحدث حتي زوال القوة الملزمة عنها الا فيما نصت عليه المادة ٥٣٤ من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة علي الجاني خلافا لما نصت عليه المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح بحسبان ان كلا الأمرين ينشئ مركزا قانونيا اصلح للمتهم ومن ثم تعد في هذا الصدد قانونا اصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورهما طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي ايضا بالأغلبية سالفه الذكر الي العدول عن الحكم الصادر في الطعن رقم ٣٣٠٥ لسنة ٦٤ القضائية فيما اورده في شأن وجوب توقيع عقوبة الحبس علي خلاف هذا النظر ومن حيث ان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال اليها ومن حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث ان ما يبغاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان اسباب قضائه بالادانة حيث انه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة علي بان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقص من مراقبة صحة التطبيق القانونية علي الواقعة كما صار اثباته بالحكم والاركان قاصرا وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع التي قام الطاعن بها واطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون ان يورد الدليل علي ذلك فإنه يكون قاصرا البيان مما يوجب نقضه وإعادة دون حاجة الي بحث الوجه الآخر من الطعن وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة ٥٣٤ من قانون التجارة باعتبارها اصلح للمتهم من شأن توقيع عقوبة الحبس او الغرامة وانقضاء الدعوي بالتصالح.

فلهذه الاسباب

حكمت الهيئة العامة للموارد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخري.

تعليقا علي الحكم:

بهذا الحكم حسمت الهيئة العامة الخلاف في الرأي بين بعض دوائر النقض الجنائية وحددت نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم وجعلها قاصرة علي العقوبة التخيرية المقررة بمقتضي حكم المادة (١/٥٣٤) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م والتصالح المقرر بالفقرة الرابعة من ذات المادة.

أكدت الهيئة العامة في اسباب حكمها المشار اليه ان تقتضي قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الي ان تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ احكامه وان المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد المشرع الذي لا يجوز مصادرته فيه.

من وجهة نظري اري ان الهيئة العامة للموارد الجنائية لمحكمة النقض راعت ان تطبيق قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بما يتضمنه من احكام الشيك بصفته اصلح للمتهم سيؤدي الي اهدار حقوق كثيرة وضياح ثروة اقتصادية كبيرة لذلك رجحت الهيئة الضرورية العملية علي الوجه القانونية.

المبحث الثالث : جريمة اصدار شيك بدون رصيد

النص القانوني الذي يحكم جريمة اصدار شيك بدون رصيد:

تنص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م علي انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية:

- ا- اصدار شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف.
- ب- استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
- ت- اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
- ث- تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه

اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد:

يتضح من نص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م ان الافعال التي نصت عليها تمثل اخلافا بالثقة في الشيك لانها جميعا تؤدي الي عدم امكان سحب مقابل الشيك سواء وقعت هذه الافعال وقت اعطاء الشيك او بعد الاعطاء.

بالتالي يشترط لقيام هذه الجريمة توافر شرط مفترض وركنين الركن المادي ويتمثل في واقعة اصدار شيك مع عدم وجود رصيد او عدم امكان سحب مقابلة والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي وسوف نقوم ببيان ذلك كما يلي:

الشرط المفترض (المحل القانوني للجريمة):

يعد الشيك شرطا مفترضا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد والمحل القانوني الذي تقع عليه الجريمة ويقصد بمفترضا الجريمة بوجه عام تلك العناصر او المراكز او الصفات او الوقائع القانونية او المادية التي تكون سابقة علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة ويترتب علي تخلفها عدم وجود الجريمة ويقصد بالمحل القانوني للجريمة المحل المادي الذي ترد عليه الجريمة وهو الشيك.

علي ذلك لا تقع جريمة اصدار الشيك بدون رصيد الا اذا كان الصك محل الجريمة شيكا في مفهوم قانون التجارة لذلك يجب التأكد من استكمال الشيك لمقوماته الاساسية ومطابقته لما جاء بالمواد (٤٧٥/٤٧٣، ٤٧٤) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م حتي يخضع للجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة ١/٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م فلا ينطبق هذا الجزاء الجنائي اذا كان الفعل واقعا علي كميالة او سند لأمر او غير ذلك من الاوراق المديونية الاخرى ففي هذه الحالات لا ينطبق نص المادة ١/٥٣٤ من قانون التجارة حيث ان المشرع قصد حماية الشيك بهذه الجريمة دون غيره من الاوراق التجارية الاخرى.

لذلك يجب التأكد من ان الشيك يتضمن البيانات الإلزامية بالإضافة الي كونه مسحوبا علي احد البنوك وعلي نماذج البنك المسحوب عليه لذلك لا تنطبق هذه الجريمة اذا كانت الشيكات خطية غير مكتوبة علي نماذج البنوك او الشيكات المسحوبة علي غير البنوك.

لذلك يجب علي المحكمة ان تشير في حكمها الي طبيعة الورقة فإن كانت شيكا قضت بقيام الجريمة علي فرض توافر بقية الأركان وان لم تكن حكمت بالبراءة.

لكن اذا كان الشيك مكتوبا علي نماذج البنك المسحوب عليها ولكنه لم يتضمن تاريخا علي الإطلاق او وقع علي بياض فإن ذلك لا يحول دون ان يعد شيكا يخضع لنطاق التجريم ذلك ان اعطاء شيك بغير تاريخ او موقع علي بياض يعني ان الساحب قد فوض المستفيد في وضع التاريخ وتكملة باقي البيانات التي تعطي للشيك مظهر صحته طالما تم تكملة هذه البيانات وحتى لو كان التاريخ سوريا او كان غير حقيقي كما لو كان لاحقا علي تاريخ تحريره فإن ذلك لا يحول دون اخضاع هذا الشيك لنطاق التجريم واضفاء الحماية عليه

لان المشرع صرح بانه اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه تاريخ لإصدار اي اذا كان الشيك يحمل تاريخا سوريا وجب وفاؤه في يوم تقدمه فيما عدا الشيكات الحكومية والشيك المسطرة طالما ان هذا الشيك يحمل اسم وتوقيع الساحب.

لكن اذا لم تتوافر في الشيك العناصر الموضوعية اللازمة لصحته كما لو كان احد طرفيه ناقص الأهلية او كان سحب الشيك بدون سبب او بسبب غير مشروع او كان رضا احد طرفي الشيك معيبا كان وقع في غلط او اكراه لا يعدم الإرادة او تدليس فإن هذه العيوب الموضوعية لا تجرد المحرر من صفة الشيك المكملة البيانات الإلزامية وبالتالي يخضع للتجريم ويتمتع بحماية المشرع طالما ان هذه العيوب الموضوعية لا تظهر في بيانات الشيك ولا يكشف عنها مظهره بمعنى ان الشيك يتمتع بالكفاية الذاتية فطالما ان الورقة كافية بذاتها لبيان مضمون الحق الثابت بها وفقا للبيانات التي حددها المشرع فهي تتمتع بالحماية.

الركن المادي:

يشتمل الركن المادي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد علي عنصري العنصر الاول واقعة اصدار شيك والعنصر الثاني عدم امكانية سحب مقابلة لسبب يرجع الي الساحب.

وسوف نتناول هذين العنصرين كما يلي:

العنصر الاول: واقعة اصدار الشيك:

يتضح من نص المادة ١/٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م ان المشرع يشترط فعل اصدار شيك اي واقعة اصدار شيك بطرحه للتداول وتسليمه للمستفيد او وكيله او ارساله اليه

لذلك يختلف اصدار الشيك عن انشائه لان انشائه هو كتابته وتحريره فلا تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد علي مجرد انشاء الشيك واحتفاظ الساحب به طالما انه لم يطرحه للتداول ويسلمه للمستفيد.

يري بعض الفقهاء ان المقصود بإصدار الشيك تخلي الساحب نهائيا عن حياته وتسليمه للمستفيد مباشرة او عن طريق وسيط ويؤدي هذا القول الي ان لاصدار الشيك عنصران اولهما مادي يتمثل في المناولة المادية وثانيها معنوي ويتمثل في ارادة التخلي عن الحيازة لدي الساحب وارادة اكتسابها لدي المستفيد.

يجب اولا ان يقوم الساحب بتحرير الشيك وتضمينه البيانات القانونية المطلوبة فإن احتفظ به كان فعله هذا من قبيل الاعمال التحضيرية التي تخرج عن دائرة التجريم اما اذا قام بتسليمه للمستفيد او وكيله فقد خرج من حوزته واصبح مطروحا للتداول.

معني ذلك ان فعل اصدار الشيك يتم بمناولة الشيك من الساحب او من وكيله الي المستفيد او وكيله يدا بيد او بإرساله بالبريد والعبرة عندئذ بوصول الشيك فعلا الي المستفيد او الي وكيله اذ تظل ملكية الرسالة لصاحبها وفقا لقواعد القانون المدني الي اللحظة التي يتسلمها فيها المرسل اليه.

يشترط ايضا لتحقيق فعل الاصدار الذي تقع به الجريمة ان يكون الساحب قد توافر لديه ارادة التخلي عن الحيازة الكاملة للشيك الي المستفيد فإذا كان الشيك قد فقد او سرق او زور انهار الركن المادي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد وفي ذلك تقول محكمة النقض ان الاصل ان اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون علي وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف ارادة الساحب الي التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب او فقده او تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الاعطاء.

☺ إذا كان الساحب قد حرر الشيك ووقعه ثم سلمه الي وكيله علي سبيل الامانة بمعنى ان تسليمه له لم يكن مصحوبا بنية التخلي نهائيا عن حيازته فلا تقع الجريمة واساس ذلك ان اعطاء الشيك وتسليمه علي سبيل الامانة انما قصد به حفظ الشيك وعدم التنازل عن حيازته كاملة او الحق الثابت به علي سبيل التمليك الامر الذي تنتفي معه وظيفة الشيك الاساسية كأداة وفاء اما اذا خان المودع لديه الامانة وسلم الشيك للمستفيد فلا تقع بفعله الجريمة ايضا لانه ليس هو الساحب.

☺ إذا كان الساحب قد سلم الشيك للوكيل مع ارادة التخلي نهائيا عن حيازته لكي يقوم بتسليمه الي المستفيد فالوكيل في هذا الفرض يعتبر شريكا بالمساعدة في جريمة الساحب اذا كان عالما بأن الشيك لا يقبله رصيد اما اذا كان الوكيل قد استغل صفة الوكيل فحرر الشيك بوصفه وكيلًا عن صاحب الحساب وسلمه للمستفيد دون ان يكون للشيك رصيد قائم وقابل للسحب فإنه يعتبر فاعلا اصليا للجريمة لان وكالته عن صاحب الحساب لا تنفي انه هو الذي ارتكب الجريمة التي ادين من اجلها.

☺ لا تقع جريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا حرر الساحب شيكا لمصلحته وقدمه للمسحوب عليه البنك لصفه وكان يعلم بعدم وجود رصيد لان الجريمة لا تقع بتحرير الشيك وتوقيعه ولا بتقديمه الي البنك المسحوب عليه وانما تتم بفعل الإصدار الذي يتمثل في تسليم الساحب او من ينوب عنه الشيك للمستفيد او من ينوب عنه تسليما ناقلا لملكية الشيك واذا كان هناك ضمان احتياطي في الشيك وكان الضمان الاحتياطي عن احد المظهرين وتم الرجوع علي الضامن واوفي بقيمة الشيك ولم يستطع استرداد قيمته من المضمون فإنه يحق للضامن الاحتياطي في هذه الحالة تحريك الدعوي الجنائية بالأدعاء المباشر ضد الساحب لإصداره شيك بدون رصيد لان الضامن الاحتياطي في هذه الحالة يحل محل المضمون ولان هذه الدعوي مجردة ليس لها علاقة بشخص المستفيد من الشيك لان القانون لا يهدف بالعقاب الي حماية المستفيد وحده وانما يرمي اساسا الي حماية الثقة العامة اي انه ينظر الي الشيك علي انه تصرف قانوني مجرد.

☺ إذا كان الضمان الاحتياطي عن الساحب وكان الضامن الاحتياطي يعلم بأن الشيك ليس له رصيد وامتنع هو الآخر عن الوفاء بقيمة الشيك عند الرجوع عليه فإنه يعتبر شريكا في جريمة اصدار شيك بدون رصيد ويعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي اما اذا كان لا يعلم بأن الشيك ليس له رصيد فإنه يحق له تحريك الدعوي الجنائية اذا قام بالوفاء بقيمة الشيك للحامل ولم يستطع تحصيل قيمته من الساحب.

☺ تقديم الضمان الاحتياطي في الشيك كقاعدة عامة لا يمنع من قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا توافرت اركانها ولكن من الناحية العملية والقانونية اذا تم الرجوع علي الضامن الاحتياطي للساحب وتم الوفاء والصلح تنقض الدعوي الجنائية ولو كان مرفوعة بطريقة الإدعاء المباشر وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد ضرورة الحكم باتا.

العنصر الثاني: عدم امكانية سحب مقابل الشيك لسبب يرجع الي الساحب:

☺ لا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد ان يقع فعل الاصدار علي صك له مظهر الشيك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وانما يجب فضلا عن ذلك ان تتوافر احدي الحالات التي حددها المشرع في المادة ١/٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م والتي تجعل من المتعذر سحب قيمة الشيك.

وهذه الحالات هي كما يلي:

- ١- اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
- ٢- استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
- ٣- اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
- ٤- تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صفه.

☺ الحالة الاولى والرابعة ← وهما حالة عدم وجود مقابل وفاء قابل للصرف وتحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية يمكن ان يقع تحت اعطاء ساحب الشيك الي المستفيد ويمكن ان يقع وقت التظهير او التسليم الحاصل من المستفيد او الحامل اذا كان يعلم ان الشيك ليس له مقابل وفاء يفي بقيمته او غير قابل للصرف حيث ان الفقرة الثانية من المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م جعلت من التظهير او التسليم جريمة مساوية لجريمة الساحب التي تتمثل في اعطاء الشيك الي المستفيد او لحامله.

☺ الحالة الثانية والثالثة ← وهما استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك واصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا هذين الحالتين تقع بعد اعطاء الشيك.

المقصود بالرصيد:

- مقابل الوفاء، لان الرصيد هو ناتج العملية الحسابية بين جانبي الدائن والمدين للساحب في ذمة المسحوب عليه.
- تنظم احكام مقابل الوفاء في الشيك المواد ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م والتي
- تعرف مقابل الوفاء** بأنه مبلغ من النقود مستحق الاداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني بين الساحب والبنك المسحوب عليه.

حالات عدم امكان سحب مقابل الوفاء:

الحالة الاولى: اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف:

- يشترط طبقا لنص الفقرة الاول(أ) من المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م لارتكاب جريمة اصدار شيك بدون رصيد اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

هذه الحالة تفترض احدي صور ثلاثة:

١- الصورة الاولى ← عدم وجود رصيد مطلقا:

- تتحقق جريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا كان الساحب لم يكن لديه رصيد مودع لدي البنك المسحوب عليه مطلقا فيجب ان يكون للساحب وقت اصدار الشيك رصيد يكفي لتغطية قيمته ولا يشترط ان يكون الرصيد مملوكا للساحب ما دام له حق السحب منه كأن يكون رئيساً لجمعية او الشركة صاحبة الحساب المودع بالبنك طالما له الحق في ذلك ولا يغني عن وجود الرصيد ان يكون الساحب قد اودع لدي المسحوب عليه بعض السندات لبيعها ودفع قيمة الشيك من ثمنها اذ لا يعدو ان يكون ذلك مجرد احتمال لوجود رصيد.
- اذا انعدم وجود الرصيد مطلقاً تقع الجريمة ولو كان المستفيد يعلم وقت اعطائه الشيك بأنه لا يقبله رصيد بل ان المشرع عاقب المستفيد علي ذلك ونص في المادة ٥٣٥ من قانون التجارة علي ان "يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا لان المشرع يهدف من جريمة اصدار شيك بدون رصيد الي حماية الثقة في الشيك باعتباره اداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات.

٢- الصورة الثانية ← ان يكون الرصيد غير كاف:

- تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد لو كان للساحب رصيد في البنك المسحوب عليه لكنه غير كاف للوفاء بقيمة الشيك حتي لو حصل المستفيد علي هذا الرصيد الموجود واذا كان الفرق بين قيمة الشيك والرصيد تافها كان ذلك دليلا علي عدم توافر القصد الجنائي لدي الساحب وهذا امر يدخل في تقدير قاضي الموضوع ويرى البعض ان النقص اليسير في الرصيد لا يؤثر علي المسؤولية الجنائية للساحب

٣- الصورة الثالثة ← ان يكون الرصيد موجودا وكافيا ولكنة غير قابل للسحب:

- تتوافر جريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا كان للساحب رصيد لدي البنك المسحوب عليه وكافيا للوفاء بقيمة الشيك ولكنه غير قابل للسحب.
- لانه محجوز عليه لدي المسحوب عليه او لان الساحب انتفت لديه اهلية الاداء كما لو كان قاصرا غير ماذون له بإدارة امواله او كان الساحب تاجرا واشهر افلاسه.
- يشترط لوقوع الجريمة ان يكون الرصيد غير قابل للسحب وقت اصدار الشيك فإذا تحقق عدم القابلية للسحب بعد اعطاء الشيك انتفت الجريمة لذلك يجب لكي تقوم مسؤولية الساحب ان يعلم وقت اعطاء الشيك بعدم قابلية الرصيد للصرف اما اذا كان يجهل ذلك سواء لم يعلم به مطلقا او علم به في تاريخ لاحق لإعطاء الشيك فلا يتوافر القصد الجنائي ولا تقوم الجريمة.
- اذا كان الرصيد غير موجود مطلقا او كان موجودا وغير كاف او غير قابل للسحب فإنه لا يشترط قيام المستفيد بتحرير بروتستو عدم الدفع حتي تقوم المسؤولية الجنائية للساحب.

الحالة الثانية: استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك:

- رأي المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م انه لا يكفي لتحقيق الهدف من جريمة اصدار شيك بدون رصيد كافيا وقابلا للسحب وقت اصدار الشيك وانما يجب ان يظل هذا الرصيد تحت تصرف المستفيد الي حين الحصول علي مقابل الشيك والحكمة من التجريم في هذه الحالة هو كفالة المشرع الثقة في الشيك منذ لحظة اصداره حتي ميعاد تقديمه للوفاء به.
- الغبرة بضرورة توافر الرصيد الكافي للوفاء بقيمة الشيك لحظة اصدار الشيك وبقائه حتي يتمكن المستفيد من الحصول علي قيمته.
- لابد ان يظل مقابل الوفاء تحت تصرف المستفيد ولا يجدي الساحب ما يثيره حول الظروف التي احاطت به والتي ادت الي سحب الرصيد.

لا يحول دون قيام الجريمة ان يكون المستفيد قد قدم الشيك بعد انقضاء المواعيد التي تحددها المادة ٥٠٤ من قانون التجارة التي تجعل المدة ثلاثة اشهر اذا كان الشيك مسحوبا في مصر واربعة اشهر اذا كان الشيك مسحوبا في الخارج او المدة التي جري عليها العمل في البنوك لان الشيك لا تتغير طبيعته بانتهاء هذه المواعيد بل تظل له صفة الشيك وبناء عليه يمتنع علي الساحب استرداد الرصيد الا اذا اثبت الساحب ان مرور مدة طويلة علي اعطاء الشيك وكثرة الشيكات التي اصدرها لم تمكنه من العلم بأن هذا الشيك لم يتم صرفه حيث ينتقي لديه في هذه الحالة القصد الجنائي.

يجب ملاحظة ان اثبات الساحب ان مقابل الوفاء قد قدم للبنك المسحوب عليه وان المقابل ظل موجودا لدي المسحوب عليه حتي انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يعفيه من المسؤولية طالما ان هذا المقابل قد زال بفعله هو اما اذا كان هذا المقابل قد زال بفعل غير منسوب الي الساحب فإنه لا تقوم المسؤولية كما لو الغي البنك الاعتماد المفتوح لصالح الساحب.

لا اهمية للوسيلة التي يلجأ اليها الساحب لاسترداد الرصيد بعد اصدار الشيك.

الحالة الثالثة: اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.

هذه الحالة تفرض علينا اولا الكلام عن اصدار امر من الساحب الي المسحوب عليه بعدم صرف الشيك والتي يترتب عليها قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد وتفرض علينا ثانيا بيان الحالات المقررة قانونا والتي يجوز فيها للساحب اصدار امر للمسحوب عليه بالامتناع عن الصرف وهي حالات وان لم تقع بها جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا انها تعطي الحامل الحق بالقيام بإجراءات اخري لشطب الاعتراض علي الصرف والتزام البنك بالصرف والا تعرض للمسؤولية.

اولا: اصدار امر للمسحوب عليه بعدم الصرف.:

تعتبر في حكم عدم وجود رصيد وبالتالي قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد قيام الساحب بإصدار امر للمسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك وتقع الجريمة بمجرد صدور هذا الامر ولو كان الساحب يستند الي اسباب مشروعة لفسخ او انقضاء العلاقة التي بينه وبين المستفيد اذ لا تعدو هذه الاسباب ان تكون من قبيل البواعث التي لا تأثير لها علي قيام المسؤولية.

من المفروض وفقا لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م الا يلتزم البنك بأوامر عملائه بعدم الصرف الا في حالات المعارضة الصحيحة التي نصت عليها المادة ٥٠٧/أ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م حيث لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجر عليه لان البنك يسأل حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الآتية: ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزئي ولم يقدر بشأنه اعتراض صحيح ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها مما لا شك فيه ان قيام البنك بالوفاء رغم صدور الامر بالامتناع عن الصرف في غير حالات الاعتراض الصحيح انما يتم ذلك تنفيذا لالتزامه القانوني لان عدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا من شأنه اهدار الثقة في التعامل بالشيكات واهدار الحماية التي يستهدفها المشرع من تحقيق التجريم مما يخل بالثقة الواجب توافرها في التعامل بالشيكات ولو لم يتحقق ضرر من جراء ذلك الفعل المادي الصادر من الساحب لذلك يتحقق الاعتداء علي المصلحة محل الحماية القانونية رغم قيام البنك بالوفاء تنفيذا لالتزامه القانوني.

ثانيا: الحالات المقررة قانونا لإباحة الأمر بعدم الصرف:

نص المشرع في المادة ٥٠٧/أ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م علي حالات الاعتراض الصحيحة في الوفاء بقيمة الشيك حيث نصت علي انه "لا يقبل الاعتراض في وفاء قيمة الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجر عليه.

علة عدم العقاب في حالات الاعتراض الصحيحة هي ان المشرع راعي ان للساحب مصلحة مشروعة فيجب ان يصون ماله بغير انتظار حكم من القضاء.

لكن المشرع راعي من ناحية اخري انه في حالة الاعتراض في غير الحالات المقررة قانونا اي بالرغم من الحظر المنصوص عليه في المادة ٥٠٧/أ ولأسباب اخري وقام البنك بالامتناع عن الصرف واحترم اوامر عملائه لان البنك قدر ان نص المادة ١/٥٣٣ لا ينطبق لعدم وجود سوء نية فإن المشرع حرص في هذه الحالة علي حقوق المستفيد واعطي له الحق في اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة بشطب هذا الاعتراض فقد قرر المشرع في الفقرة الثانية من المادة ٥٠٧ انه: اذا حصل الاعتراض علي الرغم من هذا الحظر لاسباب اخري تعين علي محكمة الأمور المستعجلة بناء علي طلب الحامل ان تقضي بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوي اصلية.

بناءً على ذلك، إذا قام الحامل الذي صدر الأمر من الساحب بعدم صرف قيمة الشيك له لأسباب أخرى غير المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٥٠٧ بالالتجاء إلى قاضي الأمور الوقفية متظلماً من أمر الساحب بعدم صرف قيمة الشيك، تلتزم المحكمة بالقضاء بشطب الاعتراض ولو كان هناك دعوى أصلية قائمة بين الساحب والمستفيد في أحقية صرف قيمة الشيك.

يلتزم البنك في هذه الحالة بصرف قيمة الشيك التزاماً بأمر المحكمة ورغم اعتراض الساحب وإصدار أمره إلى البنك بعدم الصرف.

الحالة الرابعة: تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية بصورة تحول دون صرفه:

هذه الحالة تتوافر إذا قام الساحب بتحرير الشيك على غير النماذج المطبوعة من البنك المسلمة له أو قيام الساحب بتوقيع غير مطابق للتوقيع المدرج في البنك كأن تعمد التوقيع بصورة غير مبرورة أو بصورة فورمة مختلفة عن الفورمة الموضوعية لدى البنك أو تعمد الساحب تضمين الشيك بعض الأخطاء أو الشطب أو الحشر قاصداً أو متعمداً من ذلك عدم صرفه.

هذه الحالات تجعل الرصيد غير قابل للصرف بفعل الساحب على الرغم من وجود مقابل وفاء يغطي قيمة الشيك.

قد جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م ونص على تجريم هذه الحالة صراحة وذلك في الفقرة (د) من المادة (١/٥٣٤).

الركن المعنوي

القصد الجنائي

طبيعة القصد الجنائي في الشيك:

يكفي توافر القصد العام لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد حيث يكفي توافر عنصري الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل الذي يتكون منه الركن المادي للجريمة وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً أي مميزة ومدرّكة ومختارة كذلك يجب أن يكون الجاني عالماً بعناصر الجريمة.

علي ذلك فإن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره أو بعدم كفاية المقابل أو بعدم قابليته للسحب وينتقي القصد إذا كان الساحب يعتقد خطأً وقت إصدار الشيك بوجود الرصيد وكفايته وقابليته للسحب كما يتوافر القصد الجنائي إذا سحب المتهم الرصيد بعد إعطاء الشيك وهو يعلم بأنه يترتب على ذلك عدم وجود مقابل للوفاء بالشيك أو كفاية ما تبقى من الرصيد بعد السحب للوفاء بقيمته كذلك يتوافر القصد في حالة أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك بعد إعطائه في غير حالات الاعتراض الصحيحة المنصوص عليها في المادة ٥٠٧/أ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م فإذا كان الساحب يعتقد وقت إصدار الأمر بتوافر حالة من حالات الاعتراض الصحيحة كضياع الشيك أو تفليس حامله أو الحجر عليه انتقي لديه القصد الجنائي إذا كان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

إذا توافر القصد الجنائي بهذا الشكل فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت إلى إصدار الشيك بدون رصيد وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه لا عبرة بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية وأن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.

لا يشترط لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر قصد جنائي خاص وهو نية الإضرار بالمستفيد بحرمانه من قيمة الشيك أو نية الإثراء على حسابه بل يكفي توافر القصد الجنائي العام بالتحديد السابق ذكره وقد استقرت أحكام القضاء على الاكتفاء بالقصد العام لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

أبواب القصد الجنائي:

يفترض توافر القصد الجنائي لدى الساحب ولا يعفيه من المسؤولية إلا أن يثبت انتقاء العلم لديه وقت إعطاء الشيك بعدم وجود رصيد وله في ذلك كافة طرق الإثبات.

الأمر بعدم الدفع بعد إعطاء الشيك فإن إصدار هذا الأمر للبنك المسحوب عليه ينطوي في حد ذاته على توافر القصد الجنائي أي كانت الأسباب أو البواعث التي دفعت إلى إصدار هذا الأمر طالما أنها خارجة عن الحالات المقررة قانوناً في المادة ٥٠٧/أ وهي حالات الاعتراض الصحيحة.

حالة تحرير الشيك أو توقيعه على نحو يحول دون صرفه فإن الساحب عليه أن يثبت أنه لم يكن سيئ النية وأنه لم يتعمد ذلك.

العقوبات التكميلية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد:

- ☉ نص المشرع في المادة ١/٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م علي ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الافعال الآتية.
- ☉ واذف في الفقرة الثالثة من ذات المادة انه اذا عاد الجاني الي ارتكاب احدي هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
- ☉ المشرع شدد العقوبة في حالة العود وجعل الحبس اجباريا للقاضي وليس اختياريا كما ضاعف من الحد الاقصى للغرامة الي مائة ألف جنيه.
- ☉ للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم السابق الإشارة اليها وهي جريمة اصدار شيك بدون رصيد ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفي اية حالة كانت عليها الدعوي اثبات صلحة مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشرة وتأمّر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها لو بعد صيرورة الحكم باتا.
- ☉ يجب ان يكون هناك صلح بين الساحب والمستفيد من الشيك لانقضاء الدعوي الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة فلا يكفي الوفاء بقيمة الشيك اذا لم يترتب علي هذا الوفاء قيام تصالح بين الساحب والمستفيد وذلك اعمالا لصراحة نص المشرع.
- ☉ لكن ما الحل اذا قام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك ورفض المستفيد التصالح مع الساحب او رفض المستفيد وفاء الساحب بقيمة الشيك وبالتالي رفض التصالح مع الساحب تعنتا منه لتوقيع العقوبة علي المتهم او استمرار تنفيذها اذا تم توقيعها وقام الساحب بعرض مبلغ الشيك وتم رفض العرض ثم وضع المبلغ في خزانة المحكمة.
- ☉ نري في هذه الحالة انه علي المتهم او وكيله الخاص ان يطلب من النيابة العامة اذا كانت العقوبة قد صدرت او المحكمة اذا كانت الدعوي الجنائية منظورة امامها اثبات صلحه مع المتهم لانه قام بوضع مبلغ الشيك في خزانة المحكمة والمجني عليه متعنتا في التصالح الرضائي
- ☉ إذا كان من حق المجني عليه او وكيله الخاص ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفي اي حالة كانت عليها الدعوي اثبات صلحه مع المتهم وفقا لنص المادة ٤/٥٣٤ من قانون التجارة فمن باب اولي اعطاء هذا الحق للمتهم او وكيله الخاص في حالة تعنت المجني عليه التصالح مع المتهم الذي قام بتقديم قيمة الشيك.

المبحث الرابع: الجرائم الملحقّة بالشيك

المطلب الاول: جرائم المستفيد

قام المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بتجريم بعض الافعال التي تقع من المستفيد او الحامل هذه الافعال تبدو في صورتين:

- ١- الصورة الاولى ← تظهير شيك تظهيرا ناقلا للملكية او تسليمه للحامل مع العلم بعدم وجود رصيد
- ٢- الصورة الثانية ← تلقي شيك ليس له مقابل مع علمه بعدم وجود رصيد

اولا: جريمة تظهير او تسليم الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد:

- ☉ كان تظهير او تسليم الشيك الحاصل من المستفيد او الحامل لا يعتبر بمثابة اصدار شيك وبالتالي كان لا يقع مظهر او مسلم الشيك الي الغير تحت طائلة العقاب ولو كان يعلم وقت التظهير او التسليم بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما ان المظهر او المسلم لا يعتبر وفقا للقواعد العامة شريكا للساحب لان الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهي عمل سابق علي التظهير او التسليم الا اذا ثبت انه قد اشترك معه بطريقة من طرق الاشتراك وكان عدم العقاب علي التظهير او التسليم بوصفه جريمة شيك بدون رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا اذا توافرت أركان الجريمة.
- ☉ نظرا لان تظهير الشيك او تسليمه للغير مع عدم وجود رصيد يمثل تهديدا للثقة الواجب توافرها في الشيك قام المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م بتجريم مظهر الشيك جنائيا اذا قام بتظهيره تظهيرا ناقلا للملكية او تسليمه شيكا مستحق الوفاء لحامله مع علمه بعدم وجود رصيد حيث قرر المشرع مسئولية الجنائية بذات عقوبة اصدار شيك بدون رصيد.

لذلك نصت المادة ٢/٥٣٤ تجاري علي انه " يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع كامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يكفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.

تقرر الفقرة الاولى من المادة ٥٣٤ عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

يتضح من ذلك انه يجب لقيام هذه الجريمة او انعقاد المسؤولية توافر الركن المادي والركن المعنوي

١-الركن المادي:

يشترط المشرع لانعقاد المسؤولية ان يكون التظهير ناقلا للملكية، والتظهير الناقل للملكية يقصد به نقل ملكية الحق الثابت في الشيك الي شخص اخر او نقله بإرادة التخلص نهائيا عن حيازته.

يتم بالتظهير تداول الشيك سواء كان الشيك صادرا لحامله او لشخص مسمى.

شيك الصادر لحامله اذا كان يتداول بمجرد التسليم الا انه لا يوجد ما يمنع من تداوله بالتظهير ايضا فقد قضت محكمة النقض بأن الشيك اذا صدر لحامله او صدر لامر شخص معين واذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحا ان ينقل قيمته الي المظهر اليه ويخضع لقاعدة تظهير الدفوع بما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة علي الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الي المظهر اليه الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره فالشيك المسمى او لأمر شخص معين يجوز ان يتحول الي شيك لحامله اذا تم تظهيره علي بياض حيث يمكن ان يتداول بالمناولة ويمكن اعادة تظهيره مرة اخري.

الشيك المسمى فقد نصت المادة ٢/٤٨٦ علي ان: "الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ولكن هذا الشيك المسمى اذا ذكر فيه صراحة عبارة ليس للأمر او اية عبارة اخري بهذا المعني فإنه لا يجوز تداوله بالتظهير وانما ينقل الحق الثابت به عن طريق الحوالة المدنية علي ما يترتب علي هذه الحوالة من اثار

اذا كان المستفيد قد ظهر الشيك تظهيرا توكيليا لمجرد توكيل المظهر اليه في قبض مبلغ الشيك لحساب المظهر فإنه لا يعد مرتكب ولو كان الشيك بدون مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف والعلة من ذلك هي ان المظهر اليه لم يتخلى نهائيا عن ملكيته للشيك والمظهر اليه يتلقى الشيك بوصفه وكيل في تحصيله لحساب المظهر وليس بوصفه مستفيدا جديدا فيه لان التظهير المعاقب عليه هو التظهير بمعناه القانوني الذي يؤدي الي نقل ملكية الشيك من المظهر الي المظهر اليه وليس التظهير التوكيلي الذي يستفاد من عبارة القيمة للتحويل او القيمة للقبض او القيمة للتوكيل او اي بيان اخر يفيد التوكيل.

التظهير التأميني او للرهن او الضمان فإنه يأخذ حكم التظهير التام الناقل للملكية لذلك تقوم الجريمة به حيث ذهبت محكمة النقض الي ان التظهير التام والتظهير التأميني الذي يعد في حكم التظهير الناقل للملكية اثره نقل ملكية الحق الثابت في الورقة الي المظهر اليه وتظهيرها من الدفوع وللمظهر اليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان هذا التظهير صحيحا.

ب-تسليم الشيك:

يأخذ حكم تظهير الشيك مجرد تسليم شيك مستحق الدفع لحامله ويخضع لحكم المادة ٢/٥٣٤ اذا كان من سلم الشيك يعلم بعدم وجود رصيد له.

المقصود بتسليم الشيك ← المناولة دون حاجة الي توقيع ينقل الحق او القيام بأي اجراء اخر ويتم التسليم بالنسبة للشيك الذي يصدر لحامله وقد نصت المادة ١/٤٨٦ علي ان: "يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم كما ان التظهير علي بياض يجعل الشيك قابلا للتداول بمجرد التسليم لان المادة ٤٨٩ نصت علي انه اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل ان يسلم الشيك الي شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره.

المقصود بالتسليم الذي تقع به الجريمة التسليم الذي يفيد التخلي نهائيا عن ملكية الشيك ونقل الملكية للحامل الجديد وان يكون علي سبيل التملك اما اذا كان التسليم علي سبيل الوديعة او الوكالة فإنه لا يفيد معني التخلي عن الحيازة لانه يكون محازا لحساب المستفيد.

المستشار

٢- الركن المعنوي (القصد الجنائي)

عبر المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م عن الركن المعنوي المتطلب في جريمة التظهير او التسليم بعبارة مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او أنه غير قابل للصرف وهذه العبارة يستفاد منها ان ركن الجريمة المعنوي هو القصد الجنائي فهي جريمة عمدية حيث يشترط المشرع لانعقاد المسؤولية الجنائية ليس فقط مجرد تظهير شيك تظهيراً ناقلاً للملكية او تسليمه اذا كان مستحق الدفع لحامله بل ان يكون المظهر عالماً بعدم وجود رصيد للشيك محل التظهير التام او محل التسليم اذا كان مستحق الدفع لحامله.

العبرة في توافر الجريمة ان يتوافر العلم وقت تظهير الشيك او تسليمه للغير اما اذا كان المظهر للشيك او المسلم له لا يعلم وقت التظهير او التسليم ان الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف فلا يمكن بداهة ان يعاقب علي تظهيره او تسليمه للغير فهو يستخدم حقاً له من طبيعة الشيك كأداة وفاء ولا عبرة بالعلم الذي يتحقق له بعد التظهير او التسليم لعدم معاصرته للقصد الجنائي. لا عبرة بالأسباب التي دعت الي تظهير الشيك او تسليمه للغير.

٣- العقوبة:

يعاقب المستفيد بذات العقوبة المقررة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد وهي الحبس او بغرامة لا تتجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كما يعاقب ايضاً بذات العقوبات التكميلية لجريمة اصدار الشيك بدون رصيد.

ثانياً: جريمة تلقي شيك ليس له مقابل مع علم المستفيد بعدم وجود رصيد:

نصت المادة ٥٣٥ من قانون التجارة رقم ١٧ سنة ١٩٩٩م علي انه " يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً.

الحكمة من التجريم:

جاءت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م تبين علة التجريم حيث وضحت ان المشرع بهذا التجريم واجه استغلال العاملين في السوق حاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود مقابل وفاء لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما تحمله هذه الشيكات من حماية جنائية.

الركن المادي:

السلوك المادي المكون لهذه الجريمة يتمثل في فعل الحصول اي حصول المستفيد علي شيك يعلم انه ليس له مقابل وفاء ولا يتحقق الحصول الا اذا كان الساحب سلم الشيك للمستفيد اي تسليم ناقلاً للحيازة الكاملة بشقيها المادي وهو السيطرة الفعلية والشق المعنوي وهو نية التملك ويستوي في ذلك ان يكون الشيك باسم المستفيد او لحامله.

سواء حصل المستفيد علي الشيك بالتظهير او التسليم تقع الجريمة تامة لانها جريمة تتكون من جوهر واحد غير قابل للتجزئة هو الحصول علي الشيك ولا يتصور الشروع فيها.

تقع هذه الجريمة من مستفيد تلقي او حصل علي شيك من صاحبه وهذه هي اول حركات تداول الشيك حيث يتم اصداره ثم يتم تسليمه للمستفيد اسماً كان الشيك او لحامله.

اذا حل وكيل المستفيد محل المستفيد في الحصول علي الشيك فإن الجريمة تقوم بمجرد حصول الوكيل علي الشي وبعتبر المستفيد هو المسئول عن الجريمة لان الوكيل يحوز الشيك لحساب موكله فيعتبر الموكل قد حصل علي الشيك حكماً ولا يسأل الوكيل جنائياً وهنا يعتد بإرادته وإرادة موكله في العلم بعدم وجود رصيد حيث يستوي اي منهما.

يرتكب الجريمة من يتلقي الشيك بطريقة التظهير التأميني او للرهن لانه يأخذ حكم التظهير الناقل للملكية .

يراعي ان نص المادة ٥٣٥ تساوي في الجزاء الجنائي للمستفيد بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

الركن المعنوي:

تعد هذه الجريمة عمدية لهذا يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي ويتطلب المشرع في هذه الجريمة القصد الجنائي الخاص وهو سوء نية المستفيد.

يقصد بسوء النية في هذا الخصوص علم المستفيد الأكيد بعدم وجود رصيد للشيك المحرر لصالحه وعبارة سوء النية يستخدمها المشرع عادة للتعبير عن القصد الخاص.

يجب ان يتعاصر القصد مع لحظة الحصول علي الشيك او يكون قد سبقها واستمر حتي لحظة الحصول عليه اما اذا لم يكن يعلم بذلك في هذا الوقت ثم علم بعد هذا التاريخ بعدم وجود رصيد فلا ينصرف حكم المادة ٥٣٥ تجاري في شأن المستفيد والقاعدة هي حسن نية المستفيد الي ان يثبت العكس.

يعاقب المستفيد او الحامل او المظهر اليه الذي حصل علي شيك مع العلم بأنه ليس له مقابل وفاء بغرامة لا تجاوز الف جنيه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ونري انها عقوبة بسيطة لا تتناسب علي ما يقوم به المستفيد عادة من تحريض الساحب علي سحب شيكات ليس لها رصد مستغلاً حاجته اليه.

يعاقب علي هذه الجريمة كل من ارتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في هذه الجريمة متعلق بشيك مسحوب علي بنك في مصر ولو كان الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها.

المطلب الثاني : جرائم المسحوب عليه (البنك)

تضمن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م عدة افعال تمثل جرائم تقوم بشأنها المسؤولية الجنائية لموظفي البنك المسحوب عليه وقد وضع المشرع ذلك في المادة ٥٢٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م حيث نصت علي:

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الآتية:

- التصريح علي خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته.
 - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
 - الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة ٤١٨ من هذا القانون.
 - تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل علي البيانات المنصوص عليها في المادة ٥٣٠ من هذا القانون.
 - ج- يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
- يتضح من نص هذه المادة ان جرائم المسحوب عليه تتخذ اربعة صور سوف نتناول ايضاحها ثم نبين العقوبة المقررة لها.

اولا: التصريح علي خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته:

عاقب المشرع هذا الفعل الصادر من موظف البنك المسحوب عليه لانه ينطوي علي اخلال بالثقة في الشيك ويعطل ادائه لوظيفته الأساسية باعتباره يقوم مقام النقود في الوفاء وهذا يعد اضرار بالمستفيد واخلالا بالثقة التي يودعها المتعاملين مع البنك.

القصد من تجريم هذا الفعل هو حث موظفي البنك علي الالتزام بأداء وظائفهم بحرص وجدية طبقا لاحكام القانون حفاظا علي مصالح جميع اطراف الشيك.

ويقوم الركن المادي لهذا الفعل اذا ما صرح موظف البنك المسحوب عليه علي خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او التصريح علي خلاف الحقيقة بوجود رصيد اقل من قيمة الشيك.

هذا التصريح لا يتصور وقوعه الا من موظف في البنك المسحوب عليه مختصا ببيان حالة مقابل الوفاء حيث يعد هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة ويجوز ان يعتبر ساحب الشيك شريكا للموظف المختص اذا كان علي اتفاق معه علي التصريح بعدم وجود مقابل وفاء او بعدم كفايته خلافا للحقيقة حتي يتمكن بذلك من عدم صرف قيمة الشيك.

يستوي ان يكون التصريح كتابة او ان يكون شفاهه ولكن في هذه الحالة الاخيرة يقع علي المستفيد عبء الإثبات لأن الاصل في المعاملات المصرفية الكتابة كما يستوي ان يكون التصريح وليد خطأ او اهمال.

تعتبر هذه الجريمة عمدية حيث عبر المشرع عن ذلك بعبارة ارتكب عمدا ويتمثل القصد الجنائي في اتجاه ارادة موظف البنك المسحوب عليه الي التصريح بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته مع علمه بأن تصريحه مخالفا للحقيقة ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الموظف الي هذا التصريح المخالف للحقيقة.

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الغرامة بما لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة الاف جنيه ويكون البنك مسئولا بالتضامن عن سداد هذا المبلغ مع موظف البنك.

يتعدد الجزاء في كل واقعة علي حدة ولو كان الساحب واحدا طالما تعلق الامر بعدة شيكات.

ثانياً: رفض موظف البنك بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح:

- ❖ حماية المشرع للشيك لا تكتمل الا بتجريم رفض البنك بسوء نية وفاء شيك مسحوب عليه له مقابل وفاء كامل او جزئي ولم يقدم بشأنه معارضة صحيحة لان هذا السلوك الصادر من البنك يتكافأ مع السلوك الصادر من صاحب الشيك الذي لا مقابل له وكلا الفعلين ينطوي علي اضرار بالمستفيد.
- ❖ هدف المشرع من تجريم هذا الفعل حث موظفي البنوك علي الالتزام بأداء وظائفهم بحرص وجدية وتوفير الثقة في الشيك لان الامتناع عن الوفاء بالشيك دون مبرر يؤدي الي الإضرار بالساحب ويخل بالثقة الواجب توافرها للشيك ويعطل ادائه لوظيفته الأساسية باعتباره يقوم مقام النقود في الوفاء.
- ❖ يتحقق الركن المادي للجريمة برفض موظف البنك المسحوب عليه الوفاء بالشيك المسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء كامل او جزئي ولم تقدم بشأنه اي اعتراض صحيح ويقصد بالرفض امتناع موظف البنك المسحوب عليه القيام بالتزامه القانوني الذي يفرض عليه الوفاء بقيمة الشيك المسحوب عليه سحبا صحيحا.
- ❖ ويشترط حتي يتحقق الامتناع ان يكون الشيك مستوفيا لجميع الشروط التي تسبغ عليه هذا الوصف وانتفاء اي من الاسباب التي تبرر الامتناع عن دفع قيمة الشيك بأن يكون المحرر المقدم شيكا مستوفيا جميع البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع وان يكون مسحوبا سحبا صحيحا وان يكون له مقابل وفاء كاف او جزئي وقابل للسحب وقت تقديم الشيك للوفاء ولم يقدم بشأنه اي اعتراض صحيح في الاحوال التي اجاز المشرع فيها ذلك وفقا لنص المادة ٥٠٧ تجاري التي تنص علي انه لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او إفلاس حامله او الحجر عليه.
- ❖ إذا توافر سبب من اسباب الرفض فلا تتوافر الجريمة ويلاحظ ان تقديم الشيك بعد انقضاء مواعيد تقديمه لا يبرر الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك .
- ❖ كما انه لا يجوز للبنك الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك حتي لو كان ميعاد استحقاقه لم يحل بعد اذا كان الشيك مؤرخ التاريخ فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع واذا قدم للوفاء قبل اليوم المبين به كتاريخ اصداره وجب الوفاء به في يوم تقديمه فإذا امتنع البنك عن الصرف فإنه يعد مرتكبا لجريمة رفض الوفاء بالشيك الا اذا كان الشيك من الشيكات المسطرة او الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ اصدارها
- ❖ هذه الجريمة تعتبر عمدية ولم يكتفي المشرع بالقصد الجنائي العام وانما تطلب قصدا خاصا هو سوء نية الموظف فالمشرع تطلب بالإضافة الي تعمد موظف البنك لعدم الوفاء رغم وجود رصيد كافي او جزئي قصد هذا الموظف الإضرار بالحامل او الساحب حيث قد يصيب الضرر اي منهما في مثل هذه الحالات.
- ❖ العقوبة المقررة هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبة المالية المحكوم بها باعتبار الموظف تابعا للبنك

ثالثاً: الامتناع عن وضع بيان عدم الدفع:

- ❖ طبقا لحكم المادة ٥١٨ تجاري لحامل الشيك الرجوع علي الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديمه ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا علي الشيك نفسه ومذيلا بتوقيع من اصداره ويجوز ان يصدر هذا البيان علي نموذج خاص او من غرفة مقاصة علي ان يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته وازادت الفقرة الثانية من المادة ٥١٨ تجاري انه لا يجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه في الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل علي شرط الرجوع بلا مصاريف ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.
- ❖ حرصا من المشرع علي التزام البنك بإصدار البيان البديل عن احتجاج عدم الدفع حتي لا تسقط حقوق الحامل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين وحتى يستطيع الرجوع عليهم قرر معاقبة موظف البنك الذي يمتنع عن اصدار البيان المشار اليه.
- ❖ يتحقق الركن المادي للجريمة بامتناع الموظف عن اصدار بيان اثبات عدم لدفع وسببه وهذا البيان يشترط ان يضعه علي الشيك نفسه ويكون مؤرخا ومذيلا بتوقيع من اصداره وقد يصدر البيان علي نموذج خاص او في غرفة المقاصة.

هذه الجريمة عمدية يكتفي فيها بالقصد الجنائي العام وهو قيام للموظف بالامتناع اراديا عن وضع بيان الامتناع عن الدفع وسببه وان يعلم انه لا مبرر لعدم الاستجابة لطلب الحامل الحصول علي هذا البيان ولا عبرة بالأسباب التي دعت الي امتناع المسحوب عليه.

العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه ويجوز المطالبة بالتعويض اذا توافر سببه.

رابعاً: تسليم موظف البنك احد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل علي البيانات المنصوص عليه في المادة

٥٣. من هذا القانون:

المادة ١/٥٣٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م تنص علي انه علي كل بنك يسلم عميله دفتر يشتمل علي نماذج شيكات علي بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب علي كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه.

كما يجب ان يتضمن كل نموذج عبارة شيك .

قد تطلب المشرع هذه البيانات حتي يكون المحرر كافيا بذاته لإيضاح بياناته الأساسية.

حرصاً من المشرع علي التزام موظف البنك بتضمين نماذج الشيكات هذ البيانات قرر معاقبة موظف البنك الذي يعتمد تسليم العميل دفتر يشتمل علي نماذج شيكات علي بياض لم تتضمن البيانات المشار اليها.

يتوافر الركن المادي للجريمة بقيام موظف البنك بتسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يحتوي علي البيانات المشار اليها في المادة ٥٣٠ من قانون التجارة.

وهذه الجريمة عمدية يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي العام وهي اتجاه ارادة الموظف الي تسليم العميل دفتر شيكات لا يحتوي علي البيانات المشار اليها مع علمه بذلك.

العقوبات هي الغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ويسأل البنك فيها بالتضامن مع الموظف باعتبار هذا الاخير تابعا للبنك.

المطلب الثالث : جريمة الإدعاء بسوء نية تزوير شيك

هناك العديد من الدفوع التي يمكن دفع الاتهام بها في جريمة متعلقة بالشيك مثل الدفع بانتقاء وصف الشيك والدفع بتحرير شيك تحت تأثير الإكراه ولكن من اهم واكثر الدفوع شيوعاً من الناحية العملية الدفع بتزوير شيك.

الحكمة من التجريم:

تمثل هذه الحكمة في الضرب علي يد صاحب الشيك او مظهره الذين كثيرا ما التجئوا الي الطعن في الشيكات بالتزوير سعياً منهم للتسويق والمماطلة من اجل وضع العراقيل امام القضاء قبل ان يقضي بصحة الشيك وقيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد واطالة الاجراءات لأن الادعاء بالتزوير يؤدي الي احوالة الشيك الي خبير للتحقق من صحة الشيك وبالتالي يفقد الشيك وظيفته كأداة وفاء لدي الاطلاع عليه مما يضر بالمستفيد مع علم مدي التزوير بصحة الشيك صلباً وتوقيعا ولأنه متأكد من انه في منجي من كل عقوبة جنائية عند صدور حكم او اقرار بعدم وجود تزوير وكانت لا توقع عليه سوي غرامة ذات طبيعة مدنية او ادارية مقدارها خمسة وعشرين جنيها طبقاً للمادة ٢٩٨ من قانون الاجراءات الجنائية او تتراوح بين خمسة وعشرين جنيها ومائة جنيها طبقاً للمادة ٥٦ من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

ولا شك في ان هذا الجزاء كان غير رادع ولا يتناسب مع ما حققه صاحب الشيك من تعطيل دور الشيك كأداة وفاء فعالة فضلاً عن الإضرار بالمستفيد لذلك قد احسن المشرع صنعا عندما قام بتجريم هذا الفعل حيث قرر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م اعتبار الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ثم يتضح عدم صحة هذا الادعاء بحكم نهائي فعلاً مؤثماً معاقباً عليه بالحبس والغرامة التي لا تجاوز نصف قيمة الشيك او بإحدي هاتين العقوبتين.

تنص علي ذلك المادة ٥٣٦ تجاري بقولها يعاقب بالحبس والغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او بإحدي هاتين العقوبتين كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء.

الشرط المفترض لقيام الجريمة:

يقصد بالشرط المفترض تلك العناصر او المراكز او الصفات او الوقائع القانوني او المادية التي تكون سابقة علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة ويترتب علي تخلفها عدم وجود الجريمة والشرط المفترض لجريمة الادعاء بتزوير شيك هو وجود شيك صحيح فبذلك يتوافر النموذج القانوني لهذه الجريمة عند توافر الشروط الاخرى حيث لا تقع الجريمة الا بالإدعاء بتزوير شيك صحيح فإذا ثبت ان الورقة ليست شيك فلا مجال لقيام هذه الجريمة كما لو كان كمبيالة او سند اذني او غير ذلك من اوراق المديونية .

الركن المادي:

الركن المادي لهذه الجريمة هو الادعاء بتزوير شيك اي الدفع بأنه قد وقع في الشيك تغيير في الحقيقة صلبا او توقيعا سواء اكان تزويرا ماديا وهو الذي يحصل فيه تغيير الحقيقة بطريقة مادية بحيث يترك اثرا يدركه الحس وتقع عليه العين او تزويرا معنويا والذي يكون بتغيير الحقيقة في موضوع المحرر او ظروفه وملابساته اثناء التحرير.

يكون الادعاء بالتزوير في دعوي قائمة اصلا سواء اكانت دعوي جنائية ثم رفعها عن احدي الجرائم الناشئة عن الشيك او دعوي تتعلق بالشيك تنظر امام المحكمة المدنية والتجارية.

الطعن بالتزوير في الشيك يكون عن طريق الادعاء بدعوي التزوير الفرعية او بطريقة التبعية لدعوي اصلية وفقا لنص المادة ٢٩٥ من قانون الاجراءات الجنائية .

يلزم ان يكون الادعاء بتزوير الشيك امام جهة التحقيق او المحاكمة وجهة التحقيق هي الجهة المنوط بها اجراء التحقيق الابتدائي وهي من اختصاص النيابة العامة بصورة اصلية وقاضي التحقيق بصورة ثانوية او مستشار التحقيق بناء علي ندب وزير العدل وجهة المحاكمة هي المحاكم علي اختلاف درجاتها .

يلزم لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة ان يحكم نهائيا بعدم صحة الادعاء بتزوير الشيك.

الجدير بالذكر ان اشتراط صدور حكم نهائي بصحة الشيك يؤدي الي وجود ثغرة يستغلها البعض في تحقيق المماطلة والإضرار بالمستفيد وتعطيل قيام الشيك بدوره كأداة وفاء وذلك بالحيلولة دون صدور حكم نهائي بصحة الشيك بالتنازل عن الادعاء بالتزوير في اية مرحلة قبل صدور الحكم بقيمة الشيك نهائيا فيدعي بسوء نية تزوير شيك ويستمر في اجراءات ادعائه وتحقيقه وايقاف سير الدعوي الاصلية للتحقيق في دعوي التزوير الفرعية حتي اذا ما تبين له ان مصير ادعائه هو الرفض تنازل عن ادعائه سواء قبل صدور حكم او بعد صدوره وقبل صيرورته نهائيا بعد الطعن فيه بالاستئناف تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوي الاصلية وبالتالي لا يتوافر الركن المادي للجريمة ويحقق المدعي بتزوير الشيك غرضه في المماطلة وكسب الوقت وإفلاته من الوقوع تحت طائل التجريم والعقاب وقد قضت محكمة النقض بأن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنه في اي وقت.

لكن حكم محكمة النقض يجب ان يفهم في اطار سلطة القاضي التقديرية لانه اذا كان الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن التنازل عنه في اي وقت الا ان الامر متروك للقاضي في قبول هذا التنازل او عدم قبوله.

الادعاء بالتزوير يعد من وسائل الدفاع المقررة لسائر الخصوم في الدعوي لهم ان يستعملوه او ان يلتفتوا عنه الا انه متى تم استعماله فإنه لم يعد حق التنازل عنه خالصا للمدعي فقد يري القاضي غير ذلك وضرورة السير في تحقيق الادعاء بالتزوير اذا قدر ضرورته لإظهار وجه الحق في الدعوي.

الركن المعنوي:

تعد هذه الجريمة عمدية والقصد الجنائي المتطلب هنا ليس القصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة وانما يجب ان يتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في سوء نية مدعي التزوير ويقصد بسوء النية ليس فقط علم مدعي التزوير بعدم صحة ادعائه بل قصده الإضرار بالحامل وحرمانه من الحصول علي قيمة الشيك والمماطلة وكسب الوقت ووضع العراقيل امام القضاء للافلات من التجريم والعقاب.

العقوبة:

العقوبة كما هو واضح من نص المادة ٥٣٦ من قانون التجارة الجديد هي الحبس والغرامة والقاضي مخيرا بأن يوقع احدهما.

امتحانات الاعوام السابقة

امتحان دور مايو (٢٠١٦) دبلوم القانون الخاص

اجب عن السؤال الآتي:

🌟 اشرح الآثار المترتبة علي تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية مبيناً الفرق بين النتائج المترتبة علي هذا التظهير وحوالة الحق.

امتحان دور مايو (٢٠١٧) دبلوم القانون الخاص

اجب عن الاسئلة التالية مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية:

١. ما الاثر المترتب علي التوكيل في سحب الشيك والتوكيل في تظهيره والتظهير التوكيلي من الناحية التجارية والتجريمية.
٢. بين اثر الضمان الاحتياطي علي الشيك من الناحية التجارية والجنائية مع بيان الفرق بينه وبين الالتزام بضمان .
٣. ما الفرق بين سقوط حامل الشيك والتقدم.
٤. عدم توافر الاهلية التجارية لإصدار الشيك تمنع تظهيره وتسقط جريمة اصدار شيك بدون رصيد .

امتحان دور مايو (٢٠١٨) دبلوم القانون الخاص

اجب عن السؤال الآتي

🌟 اشرح الفرق بين سحب الشيك لحساب شخص اخر والتوكيل في التظهير والتظهير التوكيلي من الناحية التجارية والجنائية.

امتحان دور مايو (٢٠١٩) دبلوم القانون الخاص

اجب عن الآتي

- أ- ما هو اثر التوكيل في سحب الشيك وتظهيره وكذلك الضمان الاحتياطي علي الشيك من الناحية التجارية والجنائية .
- ب- ما الأحكام المستحدثة الجديدة التي اضافها المشرع الفرنسي والمصري علي الجرائم المتعلقة بالشيك

امتحان دور اكتوبر (٢٠١٩) دبلوم القانون الخاص

اجب عن الآتي :

١. متي يعتبر الحامل مهماً ويتعرض حقه للسقوط في الشيك .
٢. ما الذي يترتب علي ملكية الحامل لمقابل الوفاء في الشيك وما هي الحالات التي تعطيه الحق في الرجوع علي البنك المسحوب عليه

امتحان دور مايو (٢٠٢٠) دبلوم القانون الخاص

اجب عن السؤال الآتي

- 🌟 في ضوء ما تم دراسته في احكام الشيك وضح كيف حقق المشرع التوازن بين المدين والدائن في الشيك.

امتحان دور مايو (٢٠٢٢) دبلوم القانون الخاص

اجب عن السؤال التالي مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية

- 🌟 تكلم عن التظهير التوكيلي في الشيك موضحاً الفرق بينه وبين التوكيل في التظهير والتوكيل في سحب الشيك من الناحية التجارية والجنائية؟